

다차원적인 법적 추론에서 관행의 규범적 위상 및 효력*

이현경**

【목 차】

I. 문제의 제기: 법과 관행 사이	IV. 사례 적용 및 분석: 다차원적인 법적 추론과 관행의 실천력
II. 법원으로서의 관행: 기초 개념들	1. 관행과 사법추론: ‘법의 흠결’
1. 법적 관행의 개념 및 성립·강화조건	2. 관행과 입법추론: ‘관행의 법제화’
2. 법의 원천의 개념 및 본성	3. 다차원적 법적 추론 간의 상호 관계 및 규제적 이상
III. 다차원적인 법적 추론에서 관행의 역할 및 효력	V. 성찰적 법관행주의를 향하여
1. 법적 추론의 다차원성과 법의 원천	1. ‘반성적 관행으로서의 법’과 ‘반성적 추론’
2. 관행의 규범력과 ‘나쁜 관행’의 문제	2. ‘성찰적 법관행주의’
3. 법적 추론에서 법원으로서 관행의 역할 및 효력	3. 근대 법학의 이념과 성찰적 법관행주의, 그리고 법의 지배 정신
4. 법원 간의 충돌 문제와 그 해결	

【국 문 요 약】

이 글은 다차원적인 법적 추론에서 관행이 갖는 규범적 위상 및 효력을 논하고, 그것이 법본성론과 법적 추론이라는 법철학의 두 분야에서

*이 글은 「The 31st World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy(IVR) (2024.7.7.-7.12.)」에서 개최된 Special Workshop 21(The Legal Methodology in Korea)에서 발표한 원고 “Taking Conventions Seriously - The Normative Status of Conventions in Multidimensional Legal Reasoning and The Problem of ‘Bad Conventions’” 중 일부를 한글로 옮기고 수정·보완한 것이다. 귀중하고 유익한 심사 의견을 주신 익명의 심사위원님들께 지면을 빌려 깊이 감사드립니다.

**서울대학교 법학연구소 책임연구원, 서울대학교 법학전문대학원 강사, 한국연구재단 학술연구교수

어떠한 의미를 갖는지를 밝히고 핵심 논제들을 제안한다. 이를 위한 이론적 자원의 두 축으로 ‘법원론’과 ‘법적 관행 이론’을 각기 다루고, 두 이론의 결합을 통해 그 타당성을 논증한다. 결론적으로 이 글은 법개념 및 법 본성론의 차원에서는 ‘법원(法源)으로서의 관행’[제1논제]와 ‘반성적 관행으로서의 법’[제2논제]을 주장하고, 법적 추론 모델로는 ‘반성적 추론’을 제안한다. 그리고 두 차원을 통합하여 포괄적인 법이론 모델로서 ‘반성적·성찰적 법관행주의’[제3논제]를 제창하고자 한다.

이러한 목표와 구상 아래, 제1장에서는 ‘법보다 관행이 더 가깝다?’라는 물음을 던지면서 법실천의 장에서 법과 관행 사이의 다양한 면모를 확인하고 상호관계에 대한 관심을 촉구한다. 제2장에서는 ‘법원으로서의 관행’을 구성하는 핵심 개념인 ‘법원’과 ‘관행’의 개념 및 본성에 관해 논한다. 이를 기초로 제3장은 다차원적인 법적 추론에서 관행의 역할과 효력을 고찰한다. 첫째, 법적 추론의 다차원성을 강조하면서 ‘사법 추론 일원주의’를 넘어 ‘다차원적인 법적 추론’으로의 확장 필요성을 주장한다. 둘째, 관행의 규범력 및 효력과 관련하여 ‘관행 존중의 원칙’과 ‘추정적 효력 테제’를 제안한 후, 소위 ‘나쁜 관행’의 문제를 다각도로 검토하고 이에 대한 특별한 고려와 이론화의 필요성을 역설한다. 셋째, 법원의 규범력 정도 차에 따라 세 유형을 구분한 후(‘법원-삼분법’), 각 유형에 규범적 관행을 대응시키고 ‘법원으로서의 관행’의 삼분법 대응이 갖는 의의와 한계를 논한다. 넷째, ‘법원으로서의 관행’을 둘러싼 심화 논점으로 법원 간의 규범적 충돌 문제를 논한다. 이 과정에서 관행과 실정법의 충돌, ‘나쁜 관행’에 대한 규범적 통제 문제 등을 다루면서, 전통적인 법학방법론적 해법이 갖는 한계를 지적한다. 이를 바탕으로 제4장에서는 법적 사례에 이론을 적용·분석하고, 주요 논제들의 의미와 실천력을 확인한다. 특히 입법 및 사법 추론의 영역을 나누고 대표적 사례를 선정하여 분석·논평한다. 그 과정에서 ‘법의 흠결’ 문제, ‘관행의 법제화’ 문제, ‘나쁜 관행’의 문제를 다루면서 다차원적인 법적 추론 간의 상호작용과 협업의 중요성을 역설한다. 제5장에서는 ‘반성적 관행으로서의 법’과 ‘반성적 추론’ 모델을 제안하고, 이를 통합한 ‘성찰적 법관행주의’를 제창한다. 그리고 이런 논의가 근대법학의 이념 및 법의 지배 정신에 갖는 함의를 논하면서 미래법모델로서 ‘성찰적 법관행주의’를 향한 길을 그려본다.

I. 문제의 제기: 법과 관행 사이

법과 관련한 진부한 표현 중 하나로 “법보다 주먹이 더 가깝다.”는 표현이 있다. 이는 법전화(法典化)를 통한 근대 법체계가 형성되기 이전의 전근대사회에나 적합할 수 있을 명제인데, 많은 이들의 공감을 얻곤 했다. 그런데 ‘지금 여기’ 우리에게 종종 더 가깝게 와닿는 문장은 다음이 아닐까. “법보다 관행이 더 가깝다.”

법학자나 법실무자들 사이에서 ‘관행(convention; 慣行)’¹⁾은 실정법이 아니라는 이유로 그 가치나 역할을 간과해온 경향이 있지만, 위 문장에서 드려나듯이 우리 삶의 규범적 영역에서 법과 관행은 매우 긴밀한 상관관계를 보인다. 법의 세계에서 관행은 여러 차원에서 중요한 역할을 하는데,²⁾ 최근에는 다양한 국면에서 관행의 문제가 법적 분쟁으로 이어

- 1) 영어 단어 ‘convention’의 번역어 선택은 학문 분야나 세부 영역별로 차이가 있다. 일반적으로 ‘관행’ ‘관례’ ‘협약’ ‘관습’ 등의 용어가 사용되곤 하는데, 이 글에서는 ‘관행’으로 통일한다. 참고로 한자어 관행(慣行)의 어원을 살펴보면, ‘관(慣)’은 마음(忄)과 관(貫)으로 이뤄진 형성자다. 이 중 관(貫)은 꿰뚫을 관(冊)과 조개 패(貝)로 이뤄진 한자로, 고대 중국에서 화폐로 쓰이던 조개를 뚫어 엮었던 의미다. 즉 돈 꾸러미가 ‘관(貫)’을 뜻하며 여기서 시간이 연속되고 장소가 관련 있다는 뜻으로 발전했다고 한다. 설문해자(說文解字)는 습(習)으로 풀이했으며, 관(貫)과 마찬가지로 시간상 관통·연속·장구(長久)의 뜻으로 확대됐다고 한다. (중앙일보, 2018.4.21. <https://www.joongang.co.kr/article/22555977>) 필자는 한자어 관행에 부착된 ‘습관’의 의미를 분리하고 그 필수성을 제거하여 기존의 용례를 수정하는 “‘관행(convention)’ * ‘습관화(habitation)’ ≍ ‘관습(custom)’”의 대안식을 제안한다. 이 점은 이 글 <표1>에서 제시하는 “법적 관행 정식”의 조건(6)에도 반영되었다. ‘관행-관습’의 개념적 상관관계를 설명하는 위 관계식에 대한 상세한 설명은 이현경, “법철학에서 관습이 왜 중요한가? 관습의 본질과 법규성에 대한 새로운 이해”, 법철학연구 제24권 제2호, 한국법철학회(2021). ; 이현경, “관습법 회의론에 대한 비판적 고찰 및 관습법의 현대적 변용 - 관습법철학 I”, 연세법학 제 42권, 연세법학회(2023). 참고.

T1	“관행으로서의 법”		‘포괄적 법본성론’
T2	“법원(法源)으로서의 관행”		
T3	“법의 토대에 있어서의 관행”		‘토대 관행주의’
	T3-㉠	“LAW”: 궁극적 토대 관행	하트(Hart) 버전
	T3-㉡	“laws”: 비궁극적 관행	풀러(Fuller) 버전
※ T1 ≡ T2 ∪ T3			

- 2) 이를테면 ‘법에 있어서 관행(Conventions in Law)’이란 논제 하에 법리학(jurisprudence)에서 관행이 고찰될 수 있는 다양한 지평과 차원을 간단히 표로 정리해 보면 다음과 같다.

지기도 한다.³⁾ 재판 변론 과정에서 “관행에 따랐을 뿐이다.”라는 식의 이른바 ‘관행 항변’도 종종 목격할 수 있다.⁴⁾ 이렇듯 오늘날 법질서와 법실무의 한복판에 들어와 있는 관행 관련 사안은 법이론적으로도 진지하게 다룰 필요가 있으며, 근본적인 기초법학적 연구 주제가 될 자격이 충분하다.⁵⁾ 법이론의 차원에서 ‘관행을 진지하게 생각한다는 것(Taking Conventions Seriously)’⁶⁾은 법 개념론이나 법 본성론, 또는 규범이론의 면에서 중요한 의미를 가지며, 그 실천적 의의까지 고려한다면 법적 추론의 맥락에서도 함께 탐구할 필요가 있다. 물론 이들 간의 관계에 대해서는 논쟁이 있을 수 있지만,⁷⁾ 법 본성론과 법적 추론 간에는 상호 소통과 교호작용을 통한 지평 융합이 필요하다.⁸⁾ 이 글에서는 바로 이 주제

이현경, “법학적 관행 이론 소묘(素描)-관행규범성에 대한 다각적 고찰을 중심으로”, 법철학연구 제20권 제3호, 한국법철학회(2017), 10-11면, 각주7. 이 표는 기본적으로 법의 본성에 관한 법철학 담론을 중심으로 정리된 것이다. 본 연구는 이를 토대로 ‘다차원적인 법적 추론’ 및 ‘광의의 법학방법론’ 차원으로 시선을 옮겨 논의 지평을 확장해 보고자 한다.

- 3) 근래 우리 사회에서 언론을 통해 알려진 대표적 사례로는, 조영남 대작 사건에서의 미술계 관행, 법조계에서의 전관예우 관행, 건설업계의 담합 및 월례비 관행 등이 지적된 바 있다. 이러한 예들은 대부분 일종의 병리 현상인 소위 ‘나쁜 관행’의 문제에 해당한다. 우리 사회에서 만연한 나쁜 관행의 대표적 사례들을 소개하고, 이는 범죄로 연결될 수 있음을 지적함으로써 관행의 문제가 법적 차원에서도 중요한 의미를 가짐을 보여주는 기사로는, “관행과 범죄 사이: 관행에 관대한 당신께 묻는다”(2016.6.3.) 참고. (<https://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=10100>)
- 4) 가장 최근에는 헌법재판소 2025헌라1 결정(‘대통령 권한대행의 국회 선출 재판관 임명부작위 사건’) 공개 변론 과정에서도 “헌법재판관 선출과 관련한 ‘여·야 합의’ 관행”의 존재 여부와 효력을 둘러싼 논쟁이 있었다.
- 5) 관행이라는 개념이 법철학적 사고와 만나게 되는 두 지점으로 ‘사회적 관행’과 ‘관행주의’ 문제를 구분하고 양자가 긴밀하게 연결될 수 있는 가능성과 경로를 논하는 중요한 연구로는, 박준석, “관행과 법의 지배”, 법철학연구 제16권 제3호, 한국법철학회(2013).
- 6) 이 표현은 로널드 드워킨(Ronardl Dworkin)의 주저 중 하나인 *Taking Rights Seriously* (Harvard University Press, 1978) 제목을 참고하여 붙인 것이다. 참고로 국내에서는 이 책의 번역서 제목이 법과 권리(한길사, 2010)로 옮겨졌고, 법철학계에서는 ‘권리 존중론’으로 일컫기도 한다. 이 글 제3장에서 ‘관행 존중의 원칙’으로 제시한 내용의 최소한이자 출발점은 바로 ‘Taking Conventions Seriously’라고 볼 수 있다.
- 7) Frederick Schauer, “On the Relationship between Law and Legal Reasoning”, *New Essays on the Nature of Legal Reasoning*, Mark McBride · James Penner · George Pavlakos (Eds.), Hart Publishing, 2022. 참고로, 그린버그는 ‘법에 관한 이론’과 ‘법해석 이론’ 간의 분기 가능성을 말한다. Mark Greenberg, “Legal Interpretation”, chap.5.2, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2021. 이는 이 글의 방법론적 전제 중 하나인 ‘법원-법규범 구별’ 및 ‘법원-법해석론-법규범’ 관계식[Ⅲ-2-(1).]에 의하면 큰 틀에서는 같은 문제의식을 공유한다고도 볼 수 있다.

를 다각도로 고찰하고자 한다. 논의 과정에서 논증을 위한 핵심 개념이자 전환 기제로서 ‘법의 원천(source of law; 源泉)’ 관념에 의존한다.⁹⁾ ‘관행’만큼이나 ‘원천’ 개념도 간과되어 온 경향이 있는데¹⁰⁾, 이러한 기본 개념들은 재조명될 필요가 있다. 이를 기초로 법적 의사 결정 혹은 다차원적인 법적 추론-입법 추론(legislative reasoning), 사법 추론(judicial reasoning), 일반 시민들의 법생활을 이루는 실천적 추론-에서 ‘법원으로서 관행’의 역할과 효력에 관한 고찰도 중요하다. 요컨대 이 글은 ‘법원론(法源論)’¹¹⁾과 ‘관행 이론’¹²⁾의 결합을 통해 ‘법적 추론’의 실체에 대한 더욱 풍부한 이해를 도모하고, 이를 토대로 개선된 법 개념 및 법적 추론 모델을 제시하고 궁극적으로 대안적인 일반법이론 모델을 그려본다.

이러한 목표하에, 제2장에서는 본격적인 논의에 앞서 ‘법원으로서의 관

8) ‘법 본성론’과 ‘법적 추론’에서의 법이론적 견해가 일관적이어야 하는가를 놓고도 논쟁이 있다. 대부분의 논자는 둘 간의 일관성을 유지하려 하지만 꼭 그런 것만은 아니다. 가령 법본성론에서 법과 도덕의 엄격한 개념적 분리를 주장하는 배제적 법실증주의자 라즈(Joseph Raz)는 법적 추론 영역에서는 법적 판결에서 법관의 적극적인 도덕 참조를 허용·권고하기도 하면서, 법적 추론에 있어서 일반이론의 정립은 불가능하다고 주장한다.

9) 필자는 ‘법의 원천(source of law)’과 ‘법규범(legal norm)’을 개념적으로 구별하며, 이 글에서 제안하는 ‘법원으로서의 관행’ 및 ‘반성적 관행으로서의 법’ 논제는 전자의 차원에 초점을 둔 것이다. 법의 원천에 관한 기본적인 설명은 이어지는 제2절(II-2.)에서 제공되며, 법원과 법규범의 구별에 관한 자세한 논의는 이현경, “법원(法源)-법규범의 구별과 메타-법철학”, 법철학연구 제27권 제1호, 한국법철학회(2024). 참고

10) 이런 경향은 실정법학이나 법실무에 한하지 않는다. 법철학에서도 ‘법의 원천’이란 주제는 지금까지 큰 관심을 받지 못했다. 사이너는 “법의 원천이라는 주제는 법철학의 전통적 주제이다. 그러나 놀랍게도 최근의 분석법철학에서는 이 주제에 대해 거의 관심을 기울이지 않는다. 현대의 많은 분석법철학은 ‘법의 원천’이라는 개념을 전혀 고려하지 않는다.”고 지적한다. Roger Shiner, *Legal Institutions and the Sources of Law*, Springer, 2005, p.1. 솔름(Lawrence Solum)도 자신의 법이론 블로그에서 다음과 같이 밝힌다. “이상하게도 현대 법철학에서 법의 원천에 대한 진정한 법철학적 주제에 대한 언급은 매우 드물게 이루어지고 있다. 하지만 ‘법의 원천’이라는 개념의 법철학적 중요성은 상당히 보인다. 법의 원천은 어떤 것을 ‘법’으로 만드는 것, 즉 법은 법의 원천에 의해 생성되거나 법의 원천으로부터 파생되는 것이다. 물론 법의 원천은 법실증주의의 핵심을 이루지만 자연법론적 법률가나 반-실증주의자조차 그 중요성을 부인하지 않는 법의 한 측면 즉 실정법의 ‘실정성(positivity)’을 전형적으로 보여준다.” <https://lsolum.typepad.com/legaltheory/2022/03/pino-on-sources-of-law.html> (2022.3.14.)

11) ‘법원론’에 관한 포괄적인 국내 법철학 연구로는 김대휘, “法源論에 관한 研究”, 박사학위 논문, 서울대학교(1992). 참고. 물론 여기서 말하는 ‘법원론’은 이 글에서 고유한 것이다.

12) 이 글에서 이론적 토대의 한 축을 담당하는 ‘관행 이론’은 ‘법학적 관행 이론’을 기본으로 한다. 이현경, “법학적 관행 이론 소묘(素描) - 관행규범성에 대한 다각적 고찰을 중심으로”, 법철학연구 제20권 제3호, 한국법철학회(2017) 참고.

행' 논제를 구성하는 핵심 요소인 '법원'과 '관행'의 개념 및 본성에 관해 논한다. 이를 바탕으로 제3장에서는 다차원적인 법적 추론에서 관행의 역할과 효력을 규명한다. 첫째, 법적 추론의 다차원성을 강조하면서 '사법 추론 일원주의'를 넘어 '다차원적인 법적 추론'으로의 확장 필요성을 주장한다. 둘째, 관행의 규범력 및 효력과 관련하여 '관행 준중의 원칙'과 '추정적 효력 테제'를 제안한 후, 소위 '나쁜 관행'의 문제를 고찰하고 이에 대한 특별한 고려와 이론화가 필요함을 역설한다. 셋째, 법원(法源)의 규범력 정도 차에 따라 법원을 세 유형으로 구분한 후, 각 유형에 규범적 관행을 대응시킨다. 넷째, '법원으로서의 관행' 논제를 둘러싼 심화 논점으로서 다양한 법원 간의 규범적 갈등 문제를 소개하고 이에 대한 전통적인 법학방법론적 해법이 갖는 한계 지점을 확인한다. 이를 바탕으로 제4장에서는 지금까지의 이론적 논의를 입법 및 사법 추론의 영역에서 대표적인 법적 사례에 적용하고 새로운 시각에서 평석한다. 그 과정에서 '법의 흠결' 사안과 '관행의 법제화' 문제, '나쁜 관행'의 문제를 다루면서, 다차원적인 법적 추론 간의 상호작용과 협업이 중요함을 강조한다. 마지막 제5장에서는 서두에서 제시한 문제의식을 재확인 하면서, 법개념 및 법본성론의 차원에서는 '법원으로서의 관행'[제1논제]과 '반성적 관행으로서의 법'[제2논제]을 주장하고, 법적 추론 모델로는 '반성적 추론'을 제안한다. 제5장에서는 '반성적 관행으로서의 법'과 '반성적 추론' 모델을 제안하고, 이를 통합한 '반성적·성찰적 법관행주의'를 제창한다. 그리고 이런 논의가 근대법학의 이념 및 법의 지배 정신에 갖는 함의를 논하면서 미래법모델로서 '성찰적 법관행주의'를 향한 길을 그려본다.

II. 법원(法源)으로서의 관행: 기초 개념들

서두에서 제시한 “법보다 관행이 더 가깝다?”라는 문장을 다시 살펴보자. 투박하고 거친 이 표현에는 화용론적 차원에서 확인되는 관행의 다양한 의미가 얹혀있는데,¹³⁾ 필자는 굳이 물음표 ‘?’를 부기하여 의문을

13) 글을 열면서 독자의 관심을 촉구하기 위해 제시한 이 문장에서 ‘관행’은 중의적으로 사용되고 있으며 분석적 차원에서 보면 다른 층위의 것들을 한데 묶어 논리 비약이 있다는 지적도 가능하다. 그런데 이 글이 애초에 국제학술대회 발표문으로 기획된 점, 이 주제의 의미와 중요성을 환기하기 위한 취지에서 시도된 방법이라는 점에서 너른 양해를 구한다.

표하였다. 이를 학술적 논의가 가능한 방식으로 다듬고 구체화해 보면 다음과 같은 가능성을 말해볼 수 있겠다.

- (a) 법의 사회적 기원과 원천은 관행이다. [→ “법원으로서의 관행”]
- (b) 법과 관행은 때로는 긴장 및 충돌 관계에 있을 수 있다. [→ 관행의 효력 및 법원 간의 규범적 긴장 문제]
- (c) 법적 추론 맥락에서 때로는 관행이 법보다 더 강한 규범력을 발휘한다.

위의 세 가지 논제는 법적 추론의 관점에서 보면 ① 사법적 추론, ② 입법적 추론, ③ 일반 시민들의 실천적 추론이라는 세 지평에서 모두 유효하며 상호 견련관계에 있다. 이러한 다양한 법적 행위자들에 의해 이뤄지는 다차원적인 법적 추론에서 관행의 규범적 지위를 통합적으로 담아낼 수 있는 명제로 ‘법의 원천(源泉)으로서의 관행’에서 시작해 보자. 본격적으로 이 논제의 의미를 밝히고 그 타당성을 논증하기 전에 우선 논제를 구성하고 있는 두 가지 핵심 개념, 즉 ‘관행’과 ‘원천’에 관한 예비적 탐구가 선행될 필요가 있다. 이러한 접근은 ‘법원으로서의 관행’ 논제의 의미를 밝히기 위한 ‘설명적 정의’¹⁴⁾에 해당한다.

1. 법적 관행의 개념 및 성립·강화 조건¹⁵⁾

가. ‘법적 관행 정식’

관행이란 무엇인가? 일상어로서 관행은 우리에게 매우 친숙한 용어이지만 정작 정확한 의미를 물으면 당황하곤 한다. 그런데 진지한 탐구의 장에서 핵심 개념에 대한 명확한 이해와 설명은 필수적이다. 관행에 관

14) ‘설명적 정의’란 전통적인 유·중·차 방식에 따른 개념 정의나 필요충분조건 제시를 통한 방식과 다르다. 특히나 법현상에 대한 기술적 측면을 부각시키고자 할 때는 설명적 정의 방식이 유용하다. 법리학에서 설명적 정의 기법을 시도한 예로는, Neil MacCormick, *Institutions of Law*, Oxford University Press, 2007. 맥코믹은 이러한 접근법을 통해 ‘제도적인 규범적 질서로서의 법’이라는 법개념 명제를 논증한다. 이에 관해서는 이현경, “제도적 사실로부터 제도적 규범 질서로: 맥코믹의 제도적 법개념 발전과정과 변천에 관한 고찰,” 법학논총 제30권 제2호, 국민대학교 법학연구소(2017). 참고.

15) 이 절의 내용은 필자의 선행 연구에 상당 부분 의존하고 있다. 선행 연구와 중첩되는 내용은 해당 부분에서 각주로 출처를 모두 표기한다.

한 다음의 간략한 정의를 참고해 보자.

관행이란 합리적 주체가 공동의 조정 혹은 협력 문제에 직면하여 실천적 추론 과정을 통해 수립된 균형점으로서, 명시적인 합의나 약속이 없이도 행위자들 간의 사회적인 상호작용을 통해 형성되고 자율적으로 존속하는 묵시적인 규범적 질서이다. 관행은 실천됨을 존재론적 기반으로 삼는 특별한 사회적 규칙으로, 그 자체의 메커니즘 상 참여자에게 행위 이유를 제공하고 행위를 향도하며 준수 의무를 창출할 수 있는 규범이다.¹⁶⁾

관행 개념에 대한 최초의 분석적 정의를 시도한 언어철학자 루이스(David Lewis)도 관행을 전략적 상호작용에 관여된 합리적 행위자의 실천적 추론 안에서 그것이 수행하는 기능을 통해 가장 잘 이해될 수 있다고 설명한다.¹⁷⁾ 관행은 사회적 규범의 요소와 사회적 실천의 요소가 결합된 것으로, 실천적 추론의 과정에서 행위 주체에게 모종의 행위 이유를 제공한다. 다시 말해, 구체적 사안에서 특정 관행이 존재한다는 사실 그 자체가 행위자에게는 행위를 향도하는 역할을 하게 된다. 그런데 관행의 양상은 매우 다양하고 폭넓은 스펙트럼을 갖는다. 사회적 관행 중에서 특히 법과의 관련성이 높고 법적 담론에서 중요하게 고려할 필요가 있는 관행을 ‘법적 관행’이라고 불러보자. 요컨대 ‘법적 관행’은 사회적 관행의 특별한 한 종류로서, 어떤 규범적 질서가 다음과 같은 ‘법적 관행 정식’의 조건들을 충족하면 ‘법적 관행’의 자격이 인정된다.¹⁸⁾

16) 이현경, “조정 관행의 개념적 구조와 요소-관행 개념 재구성과 대안 이론을 위한 분석적 기초”, 법철학연구 제20권 제1호, 한국법철학회(2017), 168-169면. 이 인용문의 마지막 단어인 ‘규범’은 ‘사회적 규범’으로 읽을 필요가 있으며, 이 글의 용법에 따르면 ‘법적 규범’이 되기 이전의 ‘법원(法源)’으로 그 규범적 위상을 재서술할 수 있다.

17) David Lewis, *Convention*, Blackwell Publishing, 1969, p.33.

18) 필자가 제시한 ‘법적 관행 정식’은 루이스의 관행 정식에 두 단계의 수정·보완을 한 것이다. 즉 ① ‘사회적 관행’에 관한 정의 차원에서의 수정, ② ‘법적’에 해당하는 의미 부여를 위한 요건 추가를 통해 ‘법적 관행’ 개념 정식을 완성하였다. 그런데 이 글의 목표가 법적 관행 개념에 대한 엄정하고 상세한 해명은 아니기에, 여기서는 법학적 관행 이론을 일부 소개하는 것으로 만족하고자 한다. 자세한 설명은 이현경, “법적 관행의 개념과 그 요건”, 법학논총 제7권 제2호, 전남대학교 법학연구소(2017), 18면 이하. ; 이현경, “법학적 관행 이론 소묘(素描)”, 18-25면. 참고.

▪ 다음의 조건들이 획득되면, 어떤 규칙 R은 법적 관행이 된다.

- (1) R은 특정한 목표나 가치를 전제로 하는 협력적 실천으로,
- (2) 일정 규모의 집단 P의 구성원들에게는 상황 C 하에서 R을 준수할 이유 혹은 이유들의 조합 A가 존재하지만, R에의 준수 이유나 결의가 참여자들에게 반드시 명확하게 인식/공지될 필요는 없다.
- (3) P의 구성원들은 어떤 상황 C에서 공동체 내 다른 사람들의 일반적 준수를 조건으로 대부분의 사람이 규칙 R의 준수를 선호하리라 기대하며, 일반적 준수에 대한 정당한 기대를 조건으로 대부분의 사람이 R을 준수한다.

[=‘일반적 준수 의존성’]

- (4) 하나 이상의 잠재적인 규칙 R*가 존재하며, 만약 상황 C에서 P의 구성원들이 실제로 R*를 준수한다면, 이 사실은 R 대신에 R*를 준수할 충분한 이유가 된다. 다른 조건들이 동일하다면, 상황 C에서 R과 R*를 동시에 준수하는 것은 불가능하거나 무의미하다. [=‘임의성’]
- (5) 관행에 관여된 행위자 중 일부가 법체계상 공적인 지위를 갖거나 그러한 역할과 연관되는 경우[=①‘법공직자 관행’], 관행이 헌법적 사항을 규율하는 경우[=②‘헌정 관행’], 관행이 법규범에 의해 제도적으로 지지를 받는 경우 [관행이 법규범에 의해 창출되고 인정된 경우][=③‘실정법적 관행’(최협의의 법적 관행)], 그리고 그것이 만약 분쟁화되었을 때 관계인의 직접적인 법적 권리·의무 관계로 전이될 가능성이 큰 경우[=④‘전이된 법적 관행’] 중 하나 이상을 충족하면 이는 ‘법적 관행’으로 인정된다.
- (6) R은 그것의 생성/소멸에 있어 명시적 합의/약속 등의 시점적 절차를 요하지 않으며, 정규성의 경우에도 단선적인 시간 지속성은 요하지 않는다.

<표1> 법적 관행 정식

‘법적 관행’은 사회적 관행의 특별한 한 유형으로서 ‘법적 관행 정식’의 조건을 충족하면 법적 관행으로서의 자격이 인정된다. 각 조건의 요지를 살펴보자. 관행은 기본적으로 단순·반복의 정규성(regularity)을 넘어 모종의 ‘규칙(rule)’을 기본 단위로 하는 질서로, 조건(1)에 따르면 모든 관행은 어떤 목표나 가치를 구현하는 협력적 실천의 성격을 갖는다. 예컨대 선착순이나 한줄서기 관행은 평등 가치를, 우측 주행은 질서유지와

안전보장을 목표로 한다. 조건(2)는 불투명성을 표현한 것인데, 해당 관행을 준수해야 할 명확한 이유에 대한 행위자의 인식 조건을 요하지 않는다. 조건(3)과 조건(4)는 ‘관행성(conventionality)’의 필수 성분으로, (3)은 ‘일반적 준수 의존성’을, (4)는 ‘임의성(arbitrariness)’을 나타낸다.¹⁹⁾ ‘일반적 준수 의존성’이란 해당 관행을 따르는 이유는 공동체 내 대부분의 사람이 그 관행을 준수하고 있다는 사실 자체에 의존하며, 그러한 사실이 행위자로 하여금 해당 관행을 준수할 이유를 제공한다는 것이다. ‘임의성’은 관행 규칙(R)은 같은 목적이나 가치를 실현할 등가적인 다른 대안 규칙(R*)의 존재를 항상 전제하며, 둘 중 규칙 R이 관행으로 성립된 데에는 필연성이 없음을 의미한다. 어떤 우연적 계기를 통해 규칙 R이 관행으로 된 것뿐이며, 만약 공동체 구성원 대부분이 기존의 관행 규칙 R 대신 R*를 준수하게 된다면 그때는 ‘관행의 변경’(R→R*)으로 볼 수 있다. 조건(5)는 관행에 ‘법적’ 의미를 더하고 구체화하는 요건이다. 어떤 사회적 관행이 네 가지 경우 -① ‘법공직자 관행’²⁰⁾, ② ‘헌정 관행’²¹⁾, ③ ‘실정법적 관행’(최협의의 법적 관행), ④

19) 관행 개념에 대한 최초의 분석적 정의를 제안하면서 ‘일반적 준수 의존성’과 ‘임의성’을 관행 개념을 구성하는 핵심 요건으로 논증한 고전적 연구로, David Lewis, *Convention*, Blackwell Publishing, 1969. 참고 루이스 이후에 대부분의 논자들은 루이스의 관행 개념을 준거점으로 삼아 요건을 수정·변경하거나 추가·삭제하면서 각자의 이론을 개발해 왔다. 그런데 필자가 생각하기에 ‘관행성’을 구성하고 보존하기 위한 필요·최소한의 필수요건은 이 두 가지이며 따라서 어떠한 대안 모델을 구상하더라도 관행을 관행이게끔 하는 ‘임의성’과 ‘일반적 준수 의존성’은 쉽게 포기될 수 없을 것이다.

20) ‘법공직자 관행’의 대표적 예로 하트가 제창한 ‘승인율(rule of recognition)’을 들 수 있다. 하트의 설명에 따르면 ‘승인율’이란 해당 사안에서 무엇이 법인지가 불명확할 때 이를 알려주는 궁극적인 2차 규칙으로, 모든 법체계는 하나 이상의 승인율을 반드시 갖고 있으며 그 내용은 법관들의 실무 관행을 관찰함으로써 파악할 수 있다. H.L.A. Hart, *The Concept of Law* 3rd edition, Oxford University Press, 2012 (1961, 1994), chap. IV, pp.100-109. 참고 법이론사적으로 보면, 영미 법철학계에서는 하트 승인율의 본성 해명을 둘러싼 논쟁 중에 포스테마(Gerald Postema)와 콜먼(Jules Coleman) 등이 루이스의 관행 개념에 의존하여 대안적 설명을 제시한다. 다른 한편으로, 드워킨이 법실증주의를 논박하는 과정에서 하트류의 법실증주의를 ‘관행주의(conventionalism)’라고 명명하면서 관행 개념이 법철학 담론 안에 본격적으로 등장하게 되었다. 이후에 ‘법관행주의’라는 이름표를 달고 이뤄지는 대부분의 논의도 하트의 승인율 관련 논쟁을 매개로 한다. 하지만 필자는 두 계기에 대해서도 비판적 검토가 필요하며, 그러한 이론사적 맥락을 초월하여 ‘(법)관행주의’ 자체에 대해 보다 풍부하고 건설적인 대안 모델 개발이 필요하고 가능하다고 생각한다. 이 글의 결론부에서 제시할 ‘성찰적 법관행주의’도 그러한 시도 중 하나로 볼 수 있다.

21) ‘헌정 관행’은 주로 영국의 역사와 전통하에 발전된 개념이다. 한국 정치사에서의 예로는 ‘대통령 국무총리 서리’ 제도에 대한 논쟁이 있다. ‘국무총리서리’ 제도의 본질에 대해 당시 박형오 의원은 “헌법의 규정을 무시한 관행 아닌 관행”으로, 권영성 교수는 “위헌적 관행”으로, 정종섭 교수는 “폐습”이라고 주장하였다. 헌정 관행의 법원성에 대해서는,

‘전이된 법적 관행’- 중 하나 이상을 충족하면 ‘법적 관행’으로 인정된다. 마지막 조건(6)은 조건(1)-(5)와는 달리 그 자체가 ‘(법적) 관행’ 개념의 적극적 구성요건이라기보다는 관행에 대한 기존의 통념이나 일반적 설명법에서 불필요한 점을 제거하기 위한 소극적(negative) 조건으로 기능한다. 조건(6)의 전단은 명시적인 의사 합치를 전제로 한 약속이나 합의가 없더라도 묵시적·자율적으로 형성되는 질서를 관행 개념 안에 포용한다. 조건(6)의 후단은 ‘관습’과의 개념적 구별을 위한 것이다. 이는 특히 관습법 이론과 관련하여 중요한 역할을 한다.²²⁾ ‘법학적 관행 이론’은 (법학계에서 관습법의 객관적 성립 요건으로 제시해 온 관행에 대한 통설이나 일반적 이해로서) “오랜 시간 거듭 반복적으로 행해져 온 사실로서의 관행”이라는 설명 안에 포함된 ‘장기간의 반복·누적성’이 관행의 필수요건이 아님을 주장한다. 가령 어떤 계기로 인해 단기간에 집중적으로 대다수 사람의 준수를 기초로 형성된 공통 질서가 있다면 그 역시 관행 후보가 될 수 있다. 결론적으로 <표1> ‘법적 관행 정식’의 모든 적극적·소극적 조건을 충족한 진성의 법적 관행은 모종의 규범력을 획득하고 법적 추론 과정에서 행위 이유를 제공하며, 따라서 법의 원천으로 기능한다.

나. 관행의 규범적 위계: ‘강화 조건’

법적 관행에는 규범적 위계가 존재한다. 적격의 진성 관행²³⁾이 다음 네 가지 요건 중 하나 이상을 충족하면 ‘강력한 관행’으로 볼 수 있다.

Roger A. Shiner, *Legal Institutions and the Sources of Law*, Springer, 2005, pp.122-124. ;

김기창, “성문헌법과 ‘관습헌법’”, 공법연구 제33집 제3호, 한국공법학회(2005). 등 참고.

- 22) 이현경, “법철학에서 관습이 왜 중요한가? 관습의 본질과 법규성에 대한 새로운 이해”, 법철학연구 제24권 제2호, 한국법철학회(2021). ; 이현경, “관습법 회의론에 대한 비판적 고찰 및 관습법의 현대적 변용 - 관습법철학 I”, 연세법학 제42권, 연세법학회(2023). 참고.

- 23) ‘진성(genuine) 관행’은 일상에서 ‘관행’이란 용어가 무분별하게 오남용되고 있는 현실에서 이론적·실천적으로 진지한 고려가 가능하고 필요한 정제된 관행 개념을 말한다. 가령 ‘할례 관행’ ‘촌지 관행’ 등과 같이 ‘관행’ 개념이 무분별하게 남용되고 있으며, 극단적인 상대주의자이자 도덕 관행주의자인 하만은 살인행위까지도 관행으로 설명한다. Gilbert Harman(김성환 역), 도덕의 본성, 철학과 현실사(2005). 이러한 예들은 ‘관행’이란 용어를 사용하고는 있지만 ‘법적 관행 정식’을 통과하지 못하기에 진정한 의미에서의 관행으로 볼 수 없고, 따라서 법이론적 탐구의 대상이 아니다. 이러한 잘못된 용법은 궁극적으로 인식 및 사회문화의 개선을 위해서라도 표현 교정이 요청된다. 관행 개념의 이론화와 ‘법적 관행 정식’의 제안은 이런 실천적 차원에서라도 도움을 줄 수 있다.

<표1> ‘법적 관행 정식’이 관행의 ‘성립·존재 조건’이라면, 그것이 사실적·규범적으로 더욱 강한 힘을 획득한 ‘강력한 관행’으로 만드는 ‘강화 조건’은 다음과 같다. 첫째, 관행의 존재와 내용이 대다수에게 공지의 사실로 받아들여지거나 공통 지식(common knowledge)으로 존재하는 경우 [=①‘공통 지식과 공식적 표명’], 둘째, 관행이 오랜 기간 지속되고 반복적으로 행해진 경우 [=②‘시간적 지속과 반복’], 셋째, 해당 관행이 실정법규칙 또는 법제도 안에 포함되거나 뒷받침된 경우 [=③‘제도적 지지’], 넷째, 관행을 준수할 바람직하거나 도덕적인 이유가 존재하는 경우 [=④‘도덕적 이유’]가 ‘강화 조건’을 이룬다. 몇 가지 예를 살펴보자. “시간적 지속과 반복”을 충족한 대표적 예로 ‘관습’이 있다.²⁴⁾ 앞서 ‘법적 관행 정식’ 조건 (6) [=“단선적인 시간 지속성은 요하지 않는다”]에 따라 관행의 성립 단계에는 단기간이나 중간 단절이 허용된다. 그런데 어떤 관행이 장기간 거듭 반복됨으로써 시간 지속성과 반복성까지 더해진다면 그 질서는 ‘강력한 관행’으로 승격된다. 강력한 관행으로서의 ‘관습적 관행’²⁵⁾ 혹은 ‘관습’에는 ‘민중 관습’뿐 아니라 ‘법공직자 관습’도 있다. 후자의 예로 법철학에서는 하트(H.L.A. Hart)의 ‘승인율(rule of recognition)’이 있다.²⁶⁾ 강화 조건 중 “제도적 지지”는 어떤 관행이 공식적인 법규범에 의해 제도적으로 지지 되거나 실정법체계 안에 편입되어 법규칙 형태로 제도화된 경우를 뜻하며, ‘법제화된 관행(Codified·legislated convention)’으로 표현할 수도 있다. 비공식적인 규범적 질서로 존재해 온 관행이 법규칙이나 법원칙을 통해 실정법으로 공식화됨으로써 ‘실정법적 관행’이 되는 것이다. 권리금

24) ‘법원으로서의 관습’을 인류학, 문화, 역사, 경제학·사회학·심리학의 관점에서 고찰하고, 국내법체계와 국제법의 영역을 나누어 세부 주제를 탐구한 문헌으로, David J. Bederman, *Custom as a Source of Law*, Cambridge University Press(2010). 참고.

25) ‘관습적 관행(customary convention)’이란 용어는 머피의 표현을 참고한 것이다. James Bernard Murphy, *The Philosophy of Customary Law*, Oxford University Press, 2014, p. 66.

26) <표1> ‘법적 관행 정식’ 조건(5)-①‘법공직자 관행’의 예로 소개한 하트의 ‘승인율’은 엄밀히 말하면 강력한 관행으로서 ‘사법적 관습(judicial custom)’으로 볼 수 있다. 즉 법관들 사이에서 ‘공통 지식’이 되거나 ‘시간적 지속과 반복’도 충족하여, 법적 관행의 ‘존재·성립 조건’과 ‘강화 조건’의 교집합에 속하며, 강한 구속력을 획득한 강화된 위상을 논할 수 있다. 하트의 승인율을 ‘사법적 관습’으로 규정하고 그 본질을 관행 이론의 관점에서 분석하고 있는 글로는, Gerald J. Postema, “Coordination and Convention at the Foundations of Law”, *The Journal of Legal Studies*, 1982, pp.167-172. 및 pp.197-203. 참고.

관행이 법개정을 통해 법제화된 사례²⁷⁾나 ‘관행어업권’의 예가 있다.²⁸⁾ “도덕적 이유들”은 관행이 지시하는 바가 도덕적으로 우월한 내용을 담고 있어 ‘도덕적으로 바람직한 관행’²⁹⁾이 되거나, 그 관행을 따를 명확한 도덕적 이유가 존재하는 경우를 말한다. 이때 해당 관행은 ‘대다수가 따르니까 나도 따른다’는 식의 ‘일반적 준수 의존성’ 이상의 강하고 독립적인 행위 근거가 부착됨으로써 규범력이 강화되고 ‘강력한 관행’으로 변모한다.

‘법적 관행 정식’의 성립 조건을 충족한 진성의 법적 관행은 실천적 추론 과정에서 행위 이유를 제공하는 ‘이유-제공적 규범성(reason-giving normativity)’을 갖는다. ‘강화 조건’을 충족한 ‘강력한 관행’은 법적 행위자에게 행위 이유를 제공할 뿐 아니라 준수 의무까지 발생시킨다. 다시 말해 ‘책무-산출적 규범성(obligation-generating normativity)’도 내포한 강한 구속력을 발휘하게 된다. 관행이 갖는 이런 차등적 규범력은 법적 추론의 맥락에서 ‘법원으로서의 관행’ 논제와 관련해서도 법원의 규범적 위계 문제와 연결된다. 이에 관해서는 제3장 제3절(III-3.)에서 법적 추론의 지평에서 ‘법의 원천’에 관한 언어로 상세히 다시 논한다.

2. 법원(法源)의 개념 및 유형

가. 법원의 개념 및 법원론의 현황

이제 두 번째 기초 개념인 ‘법의 원천’, 즉 ‘법원’의 개념 및 본성에 관해 살펴보자. ‘법원(法源)’이란 법의 연원 내지 원천의 줄임말로 라틴어 *fontes iuris*, 영어 *sources of law*, 독일어 *Rechtsquellen*, 프랑스어

27) 2015년 5월 13일 상가건물임대차보호법 개정(권리금에 관한 규정 신설)을 통해 기존에 비공식적으로 유지되어 온 권리금 관행이 법체계 안으로 편입되었다. 이런 경우 관행 성격은 상실된다는 견해가 있다. Andrei Marmor, *Social Conventions*, Princeton University Press, 2009. 그러나 필자는 권리금 사례는 관행이 법제화되는 여러 유형 중 ‘입법적 체계화’에 해당하며 그 경우 공식성과 제도적 체계성이 강화되었지만, 관행성의 본질은 완전히 소멸하지 않는다고 본다. 이 주제는 ‘IV-2-가’(관행과 입법 추론)에서 상세히 다룬다.

28) 1990년 개정 전 구 수산업법 제40조의 1항(입어의 관행)은 “공동 어업의 어업권자는 종래 관행에 의하여 그 어업장에서 어업하는 자의 입어를 거절할 수 없다.”고 규정하였다. 즉 종래의 입어 관행을 성문화함으로써 입어 관행을 법적 권리로 승격시킨 것이다. 판례도 ‘관행어업권’이라는 표현을 사용한다. 대법원 1999. 11. 12. 선고 98다25979 판결.

29) 이 표현은 오웬이 명시적으로 사용한 바 있다. David Owens, *Bound by Convention*, Oxford University Press, 2022.

Sources de droit 등의 번역어로 비유적인 용어다.³⁰⁾ 이 개념의 본질적 애매성으로 인해 여러 논자들이 관행 개념의 활용에 회의적인 태도를 보여왔다.³¹⁾ 예컨대 켈젠(Hans Kelsen)은 원천 개념은 쓸모없을 뿐 아니라 그 애매성 때문에 폐기하는 것이 낫다고까지 주장했다. 다른 한편으로, 법원 개념에 대한 견해 대립이 심한 근본적 이유 중 하나는 이 개념을 법 이론 일반에서 접근하는지 아니면 법조문의 규정 범위 안에서 그 의미 파악에 집중하는지의 방법론상 차이가 존재하기 때문이라는 분석도 있다.³²⁾ 실정법학에서의 논의가 주로 후자에 속한다면,³³⁾ 이 글에서의 법원론은 전자의 차원으로 볼 수 있다. 또한 법의 원천이라는 주제가 다루기 어려운 또 다른 이유는 이 개념이 입법 및 사법 영역에 모두 관련된 주제일 뿐 아니라³⁴⁾ 일반 시민들의 법생활을 이루는 실천적 추론에서도 사실상 중요한 기능을 하는 중첩성 때문이다. ‘법의 원천’이 갖는 이러한 다차원적인 애매성에도 불구하고 우리는 법원 개념의 역할과 의의에 주목할 필요가 있다.

법원의 본성에 관해서도 다양한 견해가 존재한다. 카르펜티에(Mathieu Carpentier)와 스팍(Torben Spaak)은 법의 원천 개념은 최소한 네 가지 의미-① ‘사실로서의 원천’, ② ‘규범으로서의 원천’, ③ ‘권위있는 텍스트나 자료로서의 원천’, ④ ‘원인으로서의 원천’-로 구별된다고 설명한다.³⁵⁾ 반면

30) 최병조, “第1條(法源),” 민법주해1: 총칙(1) 제2판, 양창수 대표편집, 박영사(2022), 44면.

31) ‘원천(源泉) 개념의 다차원적 애매성(ambiguity)에 대한 상세한 설명은, 이현경, “법원(法源)-법규범의 구별과 메타-법철학”, 법철학연구 제27권 제1호, 한국법철학회(2024). 참고.

32) 최병조, 앞의 논문(주30), 41면.

33) 최병조 교수님은 ‘일반적 의미의 법원의 개념’과 ‘민법 1조 상의 “법원”과의 관계’ 등과 관련한 기존의 견해 대립과 학설 현황을 총 5가지로 유형화한다. ① ‘법원=법의 존재형식’설, ② ‘본조[=민법1조]의 법원=법의 인식근거’설, ③ ‘법원 일반=법의 인식연원’설, ④ ‘법원=법의 인식근거+존재형식’ 포괄설, ⑤ ‘법원=분쟁해결기준’설로 구분한 후, 사건으로서 ⑥ ‘본조의 법원=재판준거’설을 주장한다. 최병조, 위의 논문(주26), 44-48면. 최병조 교수님이 제안하신 ‘재판준거설’은 “본조의 법원이란...재판의 준거가 되는 객관적인 요소들로서, 법원은 이들 요소를 인식함으로써 무엇이 법인가를 확인하여 구체적인 사안에서 적용될 구체적인 법규(Rechtssatz)를 획득하는 것”으로 설명한다. 만약 사법 추론 영역에 국한해서 생각해 본다면 최병조 교수님의 ‘재판준거설’은 이 글에서의 기본 입장과 큰 틀에서는 상당히 유사한 면이 있음을 확인 할 수 있다. 다만 필자는 다차원적인 법적 추론의 모든 영역에서 법원론의 의미 있게 논의되고 기여할 수 있음을 부연하고자 한다.

34) 유사한 견해로는, Giorgio Pino, “Sources of Law”, in *Oxford Studies in Philosophy of Law* Volume 4, John Gardner · Leslie Green · Brian Leiter (eds.), Oxford University Press, 2021.

35) Mathieu Carpentier and Torben Spaak, “Sources of Law”, in *Jurisprudence in the Mirror*, Kenneth

피노(Giorgio Pino)는 주로 법철학에서 법의 원천 개념과 관련하여 다루어졌던 법이론적 논의들-대표적으로 하트가 제시한 2차 규칙들-을 염두에 두면서, 법원에 대한 새로운 설명과 분석을 시도한다. 우선 기존의 주요한 구분법인 ‘형식적(formal) 원천’과 ‘실질적(material) 원천’을 받아들인 후, 형식적 원천 개념에 집중하면서 ① ‘법제화된 원천’ vs. ‘실천-기반적 원천’, ② ‘파생적 원천’ vs. ‘자율적 원천’ 간 대립을 제시해 본다.³⁶⁾

나. 법원(法源)의 유형

전통적으로 법원은 ‘형식적 원천’과 ‘실질적 원천’으로 구분해 왔다. 법의 ‘실질적 원천’은 법적 추론 과정에서 법적 행위자의 의사 결정에 영향을 미치는 모든 요소를 말한다. 다시 말해 실질적 원천은 법적용 기관의 의사 결정이나 법 제정 기관에 의한 법의 창안 활동에서 ‘사실의 문제로서’ 영향을 미치는 모든 요소와 고려사항을 포괄적으로 가리킨다. 예컨대 정의감, 형평, 문화적·정치적인 성향, 정책적 논변 등 다양한 요소들이 실질적 원천으로 기능할 수 있다.³⁷⁾ 이렇듯 실질적 원천은 매우 광범위할 뿐만 아니라 비공식적이고 주관적인 성격도 강하기에, 법원론의 주된 대상으로 삼기에는 어려움이 있다. 반면 ‘형식적 원천’은 법공직자들이 그들의 법 수여적 활동(law-ascertaining activities) 직무를 수행하는 데에 있어 그것을 사용하는 것이 법적으로 요청되는 바를 뜻한다. 여기서 “법적으로 요청된다”는 것은 관련 법공직자들이 법 확인과 법적 의사 결정의 과정에서 규칙적으로 그 원천을 사용한다는 사실뿐 아니라 그들 스스로 그것을 참조해야 한다는 내적 부담을 가진다는 점, 그리고 만약 그렇게 하지 못할 시에는 그러한 사실이 모종의 법적 결과를 초래할 수 있음을 함축한다.³⁸⁾ 이러한 내·외부적인 규범적 반응과 힘을 수반한 것이 형식적 원천의 중요한 특징 중 하나라고 볼 수 있다. 다음의 인용문은 이러한 점을 압축적으로 잘 나타낸다.

실무적 정의에 따르면, 특정 법체계의 공직자(주로 법적용 공직자)가 법

Einar Himma, Giorgio Pino, Luka Burazin (eds.), Oxford University Press, 2024, pp.244-251. 참고.

36) Giorgio Pino, 앞의 논문(주34), pp.12-75.

37) Giorgio Pino, 앞의 논문(주34), p.69.

38) Giorgio Pino, 앞의 논문(주34), p.69.

집행 활동을 수행하기 위해 법적으로 이를 사용하도록 요구되는 경우 해당 법체계에서 이는 법의 원천이 된다. 이미 분명히 밝혔듯이, 여기서 ‘법적으로 요구된다’는 것은 관련 공직자가 법 집행 활동 과정에서 정기적으로 어떤 사실을 확인할 뿐만 아니라 스스로 그렇게 해야 한다고 생각하며, 만약 그렇게 하지 않으면 순전히 도덕적, 정치적, 심지어는 원칙적 근거에 따른 반응과는 달리 법적 결과까지 초래함을 의미한다. 즉 법의 원천으로서의 지위는 궁극적으로 관련 공직자들이 공유하는 인식 관행에 기반한다.³⁹⁾

III. 다차원적인 법적 추론에서 관행의 역할 및 효력

1. 법적 추론의 다차원성과 법의 원천

가. ‘사법 추론 일원주의’를 넘어 ‘다차원적인 법적 추론’으로

법적 추론의 맥락에서 ‘법원으로서의 관행’의 역할과 효력에 관한 본격적인 탐구에 앞서, ‘법적 추론’ 자체와 관련된 학계에서의 논의 현황과 바람직한 상에 대해 간단히 살펴보자. 법학방법론이나 법적 추론에 관한 담론은 대부분 사법 추론이나 재판 이론을 중심으로 발전해 온 경향이 강하다.⁴⁰⁾ 이는 ‘jurisprudence’의 어원을 구성하는 두 라틴어 ‘*juris*’와 ‘*prudencia*’ 중 전자가 ‘재판에 관한’을 뜻하는 데서부터 그 단서를 발견할 수 있다. 이와 달리 입법 행위는 일종의 정치적 타협과 결단의 산물이라는 인식이 강했다. 그런데 최근에는 입법 영역에서도 ‘prudencia’, 즉 분별력과 사려깊음이 요청된다는 문제의식이 대두되면서 현대법철학에서 ‘입법철학(legisprudence)’도 점차 주목을 받고 있다.⁴¹⁾ 사법철학의 특징을 가장 잘 보여주는 법철학자로는

39) Giorgio Pino, 앞의 논문(주34), p.70.

40) 법해석론이나 법학방법론을 주제로 한국법철학회에서 엮은 책에 선별된 글도 대부분 사법 추론에 관한 것이다. 한국법철학회(김도균 엮음), 한국 법질서와 법해석론, 세창출판사(2013). ; 한국법철학회(이계일 엮음), 법학방법론, 세창출판사(2017). 한국에서의 법학방법론의 문제나 한계를 지적하는 논고들도 그 초점은 대부분 사법 추론 영역에 집중되어 있다. 가령 김영환, “한국에서의 법학방법론의 문제점-법발견과 법형성: 확장해석과 유추, 축소해석과 목적론적 축소 간의 관계를 중심으로”, 법철학연구 제18권 제2호, 한국법철학회(2015).

41) 국내에서는 주로 ‘입법학’이라는 이름으로 연구 및 저술이 이뤄지고 있다. 단행본으로는 박영도, 입법학 입문 증보판, 법령정보관리원(2014). ; 홍완식, 입법학논고, 피앤씨미디어

로널드 드워킨(Ronald Dworkin)이 있으며, 반면 론 풀러(Lon Fuller)가 주장한 ‘합법성의 8원칙’⁴²⁾이나 유노믹스(economics)는 입법적 차원의 예로 볼 수 있다.

생각건대, 사법 추론에 편중되어 온 기존의 (좀 과장해서 표현하자면) ‘사법 추론 일원주의’ 경향을 극복하고 ‘다차원적인 법적 추론’을 실현하는 것이 필요하다. ‘사법적 추론’과 함께 ‘입법적 추론’도 담론장에 균형 있는 참여권을 부여받고, 두 영역 간의 시선 왕복을 통해 두 가지 공적·제도적인 법적 추론 간의 교호작용을 강화할 필요가 있다. 입법부와 사법부 간의 이러한 상호작용은 키릿시스(Dimitrios Kyritsis)가 주장한 ‘공유된 권위’⁴³⁾의 구현으로 볼 수 있으며, 이러한 협력적 활동은 궁극적으로 법기관에 대한 공적 신뢰 구축에도 도움이 된다. 물론 사법적 추론이 법적 추론이나 법학방법론 영역의 중심에 있음을 부정하는 것은 아니다. 윤리학·논리학·미학 등과 같은 다른 규범학과 달리 법학은 종국적 판결을 내려야 하는 과제와 실존적 한계 상황을 내포하기에 이에 직접적으로 봉사하는 사법 추론의 중차대함이 있다. 여기서 강조하고자 하는 바는 과도한 편향과 폐쇄적 일원주의 경향은 지양되어야 한다는 것이다. 법학방법론의 중심을 이루는 “법의 해석과 적용은 단지 사법의 영역에 국한해서 논리적인 근거를 찾는 것이 중요한 것이 아니라, 입법과 사법의 맥락 이해를 바탕으로 법이념과 법현실의 조화를 통한 법의 실현이 목표”⁴⁴⁾이다. 따라서 올바르게 이해된 광의의 법학방법론은 “정의의 실현을 위한 입법과 사법의 분업과 협업의 미학”⁴⁵⁾으로 표현할 수도 있다. 요컨대 ‘사법 추론 일원주의’를 극복할 필요가 있다.⁴⁶⁾

(2021). ; 김중철·심우민, 입법의 시간, 박영사(2022). 등 참고.

42) 풀러가 제안한 ‘합법성의 8원칙’은 법의 내적 도덕성을 구현하는 요건으로 다음과 같다.

①법은 일반적이어야 한다. ②법은 공포되어야 한다. ③소급입법과 그것의 적용은 최소화되어야 한다. ④법은 이해할 수 있어야 한다. ⑤법은 모순이 없어야 한다. ⑥법은 불가능한 것을 요구해서는 안 된다. ⑦법은 비교적 지속성을 지녀야 한다. ⑧법은 정해진 대로 집행되어야 한다. Lon L. Fuller(박은정 역), 법의 도덕성, 서울대학교출판문화원(2015). ; 최봉철, “풀러의 합법성론”, 법철학연구 제7권 제2호, 한국법철학회(2004). 풀러의 법이론 일반에 관해 잘 설명된 국내 개론서로는 최봉철, 현대법철학, 법문사(2007), 제5장 참고.

43) Dimitrios Kyritsis, *Shared Authority*, Hart Publishing, 2015.

44) 김학태, 법의 해석과 적용, 한국외국어대학교출판부 지식출판원(2017), 9면.

45) 김학태, 위의 책(주44), 13면.

46) 입법과 사법의 상호 관계에 관한 최근 중요한 연구로는 김재형, “입법과 사법의 경계: 법률해석의 한계”, 민사법학 제108권, 한국민사법학회(2024). 법학방법론에서 양자 간 교호작용을 강조하는 문헌으로 김대휘, 법철학과 법이론 입문 제2판, 성안당(2023). ; 오세혁, “법학방법론의 현대적 의미”, 중앙법학 제25권 제3호, 중앙법학회(2023). ; 오세혁, 법학방법론, 박영사(2024). 참고.

다른 한편, 국가법기관에 의한 공식적인 법적 추론은 아니지만 실제 법현실과 일상적 삶 속에서 더 가깝게 영향을 미치는 법적 추론 유형이 있다. 일반 시민들의 일상적 법생활 속에서 이뤄지는 시민들의 실천적 추론이다. 입법 및 사법 추론과 함께 일반 수범자들이 행하는 법적 추론에 대한 진지한 고려는 궁극적으로 강건한 법치주의의 안착 및 ‘법(학)의 민주화’ 실현을 위해 꼭 필요하다. 또한 사안에 따라서는 특정 분야나 전문 영역과 관련한 ‘전문가 추론’ 혹은 현장의 일선 관계자들이 행하는 ‘영역-특수적 추론’도 요청될 수 있다. 가령 첨단 과학기술 분야에서는 과학자를, 교육 분야에서는 교사와 학생을, 의료 분야에서는 의료진의 시각과 목소리를 추론 과정에 적극 반영하는 것이 필요하다. ‘전문가주의’라는 비판이 제기될 수도 있지만, 이는 그 본질에 대한 오해에 기반하거나 과도한 우려일 수 있다. 적절한 여건과 제도적 환경하에 ‘영역 특수적 전문가 추론’이 도입·운용된다면 실제 현장에 적실하며 실효적으로 규범력을 발하는 ‘살아있는 법(living law; law in action)’의 형성과 건전한 작동을 기대할 수 있다.⁴⁷⁾ 예컨대 전문법의 제·개정 과정에 해당 분야 전문가들이 직접 참여하거나 전문가 공청회를 통해 현장의 목소리를 반영할 수 있는 다양한 민주적 협력 창구를 마련하는 정책들이 이를 실현할 수 있을 것이다.

기존의 사법 추론 편향적 논의는 자연스레 학문으로서의 법학방법론 영역에서도 재판 과정에 초점이 맞춰진 ‘협의의 법학방법론’ 중심의 발전으로 이어졌다. 그러나 ‘사법 추론 일원주의’ 경향을 극복하고 ‘다차원적인 법적 추론’과 ‘광의의 법학방법론’으로 우리의 관심과 논의를 확장할 필요가 있다. 요컨대, 법기관에 의한 사법 및 입법 추론에서부터, 전문가 추론이나 영역-특수적 추론, 나아가 일반 시민들의 실천적 추론에 이르기까지 ‘다차원적인 법적 추론’의 제 양상을 포괄적으로 인식하고 그 상호 관계에 주목해야 한다. 그러한 입체적이고 통합적인 접근을 시도할 때 법원(法源)에 관한 논의도 이론적·실천적으로 더욱 의미 있게 기여할 수 있을 것이다. 이는 궁극적으로 법제도에 대한 공적 신뢰를 회복하고, 법이론과 법실천의 민주화⁴⁸⁾를 이룩하는 데도 접경이 될 수 있다.

47) (Ⅲ-2.에서 논하게 될) 소위 ‘나쁜 관행’ 문제의 해결이나 극복을 위한 과정에서도 일선 현장에서 규범적 질서의 형성과 유지에 주도적 영향력을 발휘할 수 있는 전문가 추론 차원에서의 적극적인 관여가 필요하며 큰 역할을 할 수 있다.

48) ‘법(학)의 민주화’를 포함하여 법이론의 실천적 지향점·궁극적 가치들에 대한 강조는, 이현경, “법원(法源)-법규범의 구별과 메타-법철학”, 553-554면. ; 이현경, “관계론의 철학적 기초와 법관계주의”, 법철학연구 제27권 제2호, 한국법철학회(2024), 470-471면 참고.

나. ‘법원-법규범의 구별’ 문제와 ‘법원-법해석방법론-법규범’의 관계식

다차원적인 법적 추론의 장에서 법의 원천은 어떤 역할과 기능을 수행할까? 이 질문에 답하기 위해서는 단계적인 접근이 요청된다. 우선 ‘법의 원천’과 ‘법규범’을 개념적으로 구별할 필요가 있으며, 이를 ‘법원-법규범의 구별’ 문제라고 불러보자. 법규범은 법원이 ‘법해석’이라는 전환 기제를 통해 도출한 해석의 산물이며, ‘법원-법해석방법론-법규범’의 관계식으로 구체화할 수 있다.⁴⁹⁾ 다시 말해 해석의 대상은 법의 원천이며, 원천에 대한 해석을 통해 도출된 법규범⁵⁰⁾을 개별 사례에 적용할지에 관한 문제는 ‘재판 이론’으로 차별화할 수도 있다. 이러한 전 과정을 통틀어 ‘광의의 법적 추론’ 혹은 법적 의사 결정의 전 과정으로 이해할 수 있다.

규범적 문장인 법률을 법규범과 동일시하는 일반적 인식이 존재한다. 그런데 양자는 구별되며, 전자에 대한 해석이나 추론을 통해 산출되는 결과값을 법규범으로 볼 수 있다.⁵¹⁾ 그렇다면 이 관계식에서 매개항이자 전환 기제 역할을 하는 ‘해석’의 의미는 무엇일까? 사법 추론을 중심으로 한 법학방법론에서는 일반적으로 해석을 문언의 가능한 의미 파악으로 설명한다. 그러나 해석 대상은 법규칙의 법문에 국한되지 않는다. 입법을 포함한 법적 추론의 다양한 차원들을 포괄하기 위해서는 ‘해석’의 의미에 대한 편협한 이해방식을 넘어서는 필요가 있다. 피노는 “법원(法源)을 사용(use)한다는 것은 법원을 해석함을 의미한다.”⁵²⁾고 주장한다. 피노의 견해는 비록 사법적 차원에 초점을 둔 것이지만, 이러한 포용적 접근이 다차원적인 법적 추론의 모든 지평에 ‘법원-법해석방법론-법규범’의 관계식을 적용하는 데도 더 적절할 것이다. 한 걸음 더 나아가, 법해석의 정적 차원을 넘어 역동적인 상호작용의 기능적 측면에 주목한다면 법해석·방법론의 의미와 역할에 관한 추가적인 고려도 필요하다. 이 문제는 기본적으로 ‘영역-특수적’ 접근을 출발점으로 하되 각 추론 영역의 고유한 특징과 목표를 반영한 해석방법론의 개발·구체화로 발전시킬 필요가 있다. 가령 사법

49) 이에 관한 자세한 설명은 이현경, “법원(法源)-법규범의 구별’과 메타-법철학” 참고.

50) Giorgio Pino, 앞의 논문(주34), p.68.

51) ‘규범’과 ‘규범적 문장’을 구별하고, 조건문 형식을 취하는 규범적 문장을 출발점으로 법적 추론 과정 안에서 전통적 추론 규칙의 작동을 검토하는 연구로, 박준석, “규범의 본질에 대한 탐구-조건문의 형식을 중심으로”, 법철학연구 제22권 제2호, 한국법철학회(2019).

52) Giorgio Pino, 앞의 논문(주34).

추론의 경우라면, 대륙법계에서는 사비니(Friedrich Carl von Savigny) 이후 체계화된 네 가지 법해석 캐논-문리해석·체계적 해석·역사적 해석·목적론적 해석-이나 영미 법해석 이론들-문언주의·의도주의·목적주의⁵³⁾-을 참고할 수 있다. 이에 반해 입법 추론의 경우는 상대적으로 이론화가 잘 이뤄지지 못한 면이 있다. 최근 주목받고 있는 입법학이나 입법 논증, 입법 평론에서의 시도가 디딤돌이 될 수 있다. 다만 입법 과정의 특성상 절차적 측면에 강조점을 두는 경우가 많은데, 입법 철학의 가치론적 측면까지 담아낼 수 있는 방법론 개발이 요청된다. 가령 현대 절차적 자연법론자로 평가되기도 하는 풀러의 ‘합법성의 8원칙’은 절차적 특성을 띠고 있지만 궁극적으로 법을 법답게 만드는 법의 내적 도덕성을 구현하는 원칙이기에 가치론적 통합 모델로 참고할 수 있겠다.⁵⁴⁾

다른 한편, 법해석‘방법’에 대한 개발뿐만 아니라 법해석 ‘이론’ 자체에 대한 정당화와 평가 문제도 고려할 필요가 있다. 그린버그(Mark Greenberg)는 법해석 이론을 지지하는 네 가지 논변을 제시한다. 첫째, 민주주의·공정성·법치주의와 같은 도덕적 가치에 호소하는 ‘규범적 논변’이다. 문언주의나 의도주의 지지자들은 모두 민주주의에 기초한 논변을 제시한다.⁵⁵⁾ 강고한 문언주의자인 스칼리아(Antonin Scalia) 판사는 “입법자가 선포한 바가 아니라 입법자가 의미한 바에 따라 법의 의미를 결정하는 것은 민주적 정부나 공정한 정부와 양립할 수 없다.”⁵⁶⁾고 강조했다. 둘째, ‘언어적 논변’은 언어나 의사소통이 어떻게 작동하는지에 대한 주장에 호소한다. 셋째, ‘개념적 논변’은 법해석에 대한 특정한 접근 방식은 ‘해석’·‘법’·‘권위’ 개념에서 나온다고 주장한다. 넷째, 법해석이 추구하는 바가 무엇인지에 따라 올바른 법해석 방법이 달라진다는 ‘목표-관련적 논변’도 있다.⁵⁷⁾ 특히 네 번째 논변은 다차원적인 법적 추론을

53) Mark Greenberg, “Legal Interpretation”, chap.4, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2021.

54) 풀러의 모델은 순수 절차적 방법론과 실질적 방법론 사이의 절충적인 것으로 이해할 수 있다. 그런데 현대 법질서에서의 입법 추론은 여기서 한 걸음 더 나아가 ‘지금 여기’의 공적 가치와 방향을 더 실질적이고 적극적으로 담아낼 수 있는 방법론 개발이 요청된다.

55) William N. Eskridge, Jr., *Dynamic Statutory Interpretation*, Harvard University Press, 1994, p.13. ; William N. Eskridge Philip P. Frickey, “Statutory Interpretation as Practical Reasoning”, *Stanford Law Review*, 1990, p.326. ; Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*, Princeton University Press, 2005, p.248. ; Larry Alexander, “Originalism, the Why and the What”, *Fordham Law Review*, 2013, p.540. ; Frank H. Easterbrook, “Text, History, and Structure in Statutory Interpretation”, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 1994, p.63. 등 참고.

56) Antonin Scalia, *A Matter of Interpretation*, Princeton University Press, 1997, p.17.

전제로 각 추론 영역의 특수성에 적합한 방법론 개발 필요성을 강조하고 그 기저에 법의 민주성 가치를 지향하는 이 글의 논지와도 관련성이 크다.

2. 관행의 규범력과 소위 ‘나쁜 관행’의 문제

가. ‘관행 존중의 원칙’과 ‘추정적 효력 테제’

관행은 참여자들의 상호작용을 통해 형성된 자율적인 규범 질서로 그 민주적 기원을 근거로 우선 존중될 필요가 있다.⁵⁸⁾ 이를 ‘관행 존중의 원칙’으로 불러보자. 즉 관행 정식을 충족한 진성의 법적 관행은 존중받을 자격이 있으며, 일견 그 자체로 효력이 인정된다. 이를 ‘추정적 효력 테제(presumptive validity thesis)’라고 부를 수 있다. ‘추정적 효력 테제’는 ‘관행 존중의 원칙’을 법적 논제로 변환한 것으로, 법적 추론의 맥락에서 ‘법원으로서의 관행’의 효력을 논하는 데에 일차적 기준이 된다. 여기서 ‘추정적’의 의미는 관행에 부여된 효력이 확정적이지 않다는 것으로, 모종의 임계점을 넘은 소위 ‘나쁜 관행’은 효력이 부인될 수 있다.

법철학에서 ‘나쁜 법’ 혹은 ‘악법’의 효력을 둘러싼 논쟁은 친숙하다.⁵⁹⁾ 그런데 소위 ‘나쁜 관행(bad convention)’ 사안은 일상적 법실천의 현장에서 더 자주 가깝게 겪는 문제임에도 불구하고 법이론적 차원에서 이 문제를 다룬다는 것은 생경하게 느껴질 수 있다. 그러나 나쁜 관행의 문제는 법실무에서도 난제로 등장하기에 우리는 이 주제를 폭넓고 깊이 있게 다룰 필요가 있다. 악법의 효력 논쟁이 법철학의 핵심 주제 중 하나이듯, 법적 관행에 대해

57) Mark Greenberg, “Legal Interpretation”, chap.5, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2021.

58) 관행 규범성의 원천(책무 산출의 근거)에 관한 정당화 논변으로는 민주주의 논변 외에도 기능주의 논변, 계약주의 논변, 흄의 공감 이론, 길버트의 합동 결의 논변 등이 가능하다. 이 중 어느 하나에만 의거한 단순-일원주의 모델은 불충분하며, ‘다층적인 정당화 논변’이 요청된다. 이현경, “규범으로서의 관행: 분류적 차원의 고찰”, 법학논총 제34권 제3호, 한양대학교 법학연구소(2017), 284-290면. 참고.

59) 이 주제에 관한 국내 법철학 연구로는 최봉철, “사악한 법의 효력”, 성균관법학 제32권 제4호, 성균관대학교 법학연구원(2020). ; 최봉철, “악법과 법준수의무에 대한 소크라테스의 입장”, 법철학연구 제16권 제3호, 한국법철학회(2013). ; 안준홍, “나쁜 법은 법이 아닌가”, 법철학연구 제15권 제2호, 한국법철학회(2012). ; 하재홍, “소크라테스와 정의롭지 않은 법률의 준수 문제”, 법학연구 제63권 제4호, 부산대학교 법학연구소(2022). 등 참고. 최근 판례를 소재로 법관의 책임 문제를 논한 연구로, 이재승, “긴급조치 제9호를 적용한 법관의 책임: 대법원 2022.8.30. 2018다212610 전원합의체 판결”, 민주법학 제81권, 민주주의법학연구회(2023). 참고.

서도 유사한 문제의식을 품고 법이론적으로 고찰할 필요가 있다. 이른바 ‘나쁜 관행’은 개념적으로 가능한가?⁶⁰⁾ 만약 그러하다면 ‘나쁜 관행’은 효력이 있는가? 법적 추론에서 법원으로서 관행의 효력을 논하는 이 글의 문맥에서 보면, 현상적 차원에서의 단순 묘사를 넘어 개념적이고 이론적인 차원에서도 이 문제를 체계적으로 설명하고 논평할 수 있어야 할 것이다.

나. 소위 ‘나쁜 관행’의 문제: 개념, 종류, 효력

진성 관행의 효력을 규율하는 ‘추정적 효력 테제’는 임계점을 갖는다. 가령 조정 관행의 경우에는 합리적 조정력에 근거한 기능주의 논변이 추정적 효력 테제의 정당화 논변이자 동시에 임계점 역할도 한다. 법의 세계에서는 임계점에 대한 인식과 규범적 판단이 특히 중요하다. 다시 말해 법적 관행의 추정적 효력이 재고되고 재평가받는 반성적 과정이 꼭 필요하다. 책무 산출적 규범성이 수반된 강력한 관행이라 할지라도 이후에 일정한 심사 기준에 따라 ‘나쁜 관행’으로 판정된다면 추정적 효력의 임계점을 초과하여 ‘추정적 효력 테제’가 부인되고 효력이 상실된다. 그 결과 해당 질서에 따를 일반적 준수의 무도 부인될 수 있다. 이것이 바로 ‘추정적 효력 테제’가 만들어내는 실천적 효과다.⁶¹⁾ 법 본성론에서 ‘나쁜 관행’의 문제는 일종의 ‘별첨 부록’으로 생각될 수 있을지 모르지만, 법적 추론과 법실천의 차원에서는 실제로 종종 경험하는 중요한 사안이다. 입법 추론 영역에서는 주로 ‘나쁜 관행의 법제화’ 문제가, 사법 추론에서는 관행과 법규칙 간의 충돌 상황이 대표적이다. 이런 문제들을 그저 사회문화적 병리 현상으로 치부하고 넘어갈 것이 아니라, 법이론적 차원에서도 진지하게 다룰 필요가 있다. 그 해결을 위해서는 법적 추론의 지평에서도 ‘나쁜 관행’의 법원성과 효력에 대한 탐구가 절실하다. 기존 문법에 따라 표현해 보자면, 나쁜 관행의 효력 문제는 ‘해결하기 어려운 사안’의 한 종류로 분류될 수 있으며, 법학방법론적으로도 중요한 논점을 이룬다.

‘나쁜 관행’이란 무엇인가? 소위 ‘나쁜 관행’은 ‘악법’ 문제와 여러 면에서 유

60) 언어분석철학이나 과학철학에서 ‘관행주의’를 말하는 대다수 논자는 관행을 매우 기술적·가치중립적으로 다루며, 따라서 관행의 품질 평가에 관한 시도나 문제의식 자체를 발견하기 어렵다. 그런데 규범학에서도 그러하거나 그러해야 하는 것인가? 바로 이 점에서 ‘나쁜 관행’의 개념 및 효력 문제는 법학에서 더욱 중요하다고 본다. 이런 특징적 경향은 법(철)학 분야에서도 크게 다르지 않다. 철학에서 관행주의에 관한 다양한 논의를 담은 문헌으로는 Yemima Ben-Menahem, *Conventionalism*, Cambridge University Press, 2006.

61) 자세한 설명은 이현경, “법학적 관행 이론 소묘(素描)”, 42-45면 참고.

사점이 있지만 더 복잡적·다층적인 성격을 내포하기에 섬세한 접근이 요청된다. 우선 ‘나쁜 관행’과 ‘무의미한 관행(pointless convention)’을 개념적으로 구별할 필요가 있다. 관행은 정의상 ‘실천됨’을 존재론적 기반으로 하기에 형식·절차적 합법성보다는 사회적 차원의 효력, 즉 실효성이 중요한 역할을 한다.⁶²⁾ 이 점은 ‘상위법 위반’(실정법체계 안에서 최고법인 헌법 혹은 그 상위의 고차법)이라는 단일 기준에 따른 전형적 논의와 차별화되는 특징 중 하나다. 넓은 의미에서 나쁜 관행은 ‘약한 의미에서의 무의미한 관행’부터 ‘가장 강한 의미에서의 나쁜 관행’에 이르기까지 폭넓고 다양한 양상을 띤다.

‘무의미한 관행’은 약한 의미와 강한 의미로 구분할 수 있다. ‘약한 의미에서의 무의미한 관행’은 사람들이 그 관행을 거의 준수하지 않게 되어 준수 의존적 이유가 제거되는 사태다. 관행 성립의 필수요건 중 하나는 일반적 준수 의존성[‘법적 관행 정식’의 조건(3)]인데, 실효적 준수가 없다면 그 관행은 ‘무의미’할 수 있다. 법실증주의자 그린(Leslie Green)도 유행에 뒤쳐진 에티켓 규칙을 예로 들면서 ‘무의미한 관행’이란 표현을 사용한다.⁶³⁾ 다른 한편, ‘강한 의미에서의 무의미한 관행’도 가능하다. ‘법적 관행 정식’ 조건(1)에 따르면 관행은 어떤 가치나 목적, 필요에 대한 규범적 응답으로서 특정한 목표나 가치를 전제하는데, 관행의 내용이나 작동은 애초에 그것이 추구했던 목적이나 가치를 훼손하지 않아야 한다. 만약 현존하는 어떤 관행이 그것의 존재 조건을 이루는 가치·목적에 명백히 반하거나 그런 방향으로 변질되어 작용한다면 그 관행은 합목적적이지 못하며, 따라서 ‘강한 의미에서 무의미한 관행’으로 볼 수 있다. 정리하자면, ‘무의미한 관행’은 대부분 ‘나쁜 관행’에는 이르지 못한 것으로 ‘약한 의미에서의 무의미한 관행’은 (어떤 이유에서건) 사람들이 점차로 준수하지 않아 실효성이 현저히 약화된 관행[‘실효성 심사’]을 뜻한다. ‘강한 의미에서의 무의미한 관행’은 애초에 그 관행이 전제한 목표나 취지에 반하거나 그렇게 변질된 관행[관행 정식의 조건(1) 위배; ‘합목적성 심사’]으로서 이는 ‘가장 약한 의미에서 나쁜 관행’의 위상도 함께 갖는다.

이 문제를 법원성, 나아가 법이 갖춰야 할 요건으로서 실질적 의미에서의 합법성이나 법다움의 관점에서 살펴보자. 임미원 교수는 근대법이 갖춰야 할 세 가지 필요 요소로 ‘합목적적 제도성’, ‘역사적 현존성’, 그리고 ‘이성적 정당

62) 법효력의 세 차원으로 ‘합법성’(법률적 효력 개념), ‘실효성’(사회적 효력), ‘정당성’(도덕적 효력) 구분에 관한 설명은 이상영·김도균, 법철학, 한국방송통신대학교출판문화원(2011).

63) Leslie Green, *The Authority of the State*, Oxford University Press, 1999, p.90.

성’ 혹은 ‘비판적 이성성’을 제시한다.⁶⁴⁾ 이 기준에 맞추어 보면, 관행 질서는 두 번째와 세 번째 요소를 근거로 하여 법원성을 획득한다고 볼 수 있다. 그런데 ‘약한 의미에서의 무의미한 관행’은 대다수 사람의 부준수로 인해 그것의 ‘역사적 현존성’이 현저히 약화된 상황을, ‘강한 의미에서의 무의미한 관행’은 ‘합목적적 제도성’이 위협받는 상황을 가리킨다고 해석할 수도 있다. 또한 ‘비판적 이성성’ 요소는 애초에 관행 질서 자체에 필요적으로 기대되는 규범력의 근거는 아니지만, 그것의 결핍이 극단화되면 소위 ‘나쁜 관행’으로 치달을 위험이 있다.⁶⁵⁾ 지금까지의 논의를 간단히 표로 정리해 보자.⁶⁶⁾

	‘약한 의미’에서의 무의미한 관행	‘강한 의미’에서의 무의미한 관행
내용	사람들이 점차로 준수하지 않아 실효성이 현저히 약화	애초에 그 관행이 전제한 목적·취지에 위배
관행 정식	관행 정식의 조건(3) : ‘일반적 준수 의존성’	관행 정식의 조건(1) : ‘목표·가치의 전제’
판단 기준	실효성 심사	합목적성 심사
위상	고유한 의미에서의 ‘무의미한 관행’	‘무의미한 관행’ & ‘가장 약한 의미의 나쁜 관행’

<표2> ‘무의미한 관행’과 ‘나쁜 관행’

‘무의미한 관행’과 ‘나쁜 관행’은 어떤 연관성이 있을까? 모든 심급의 ‘무의미한 관행’이 곧바로 ‘나쁜 관행’임을 함축하지는 않는다. 만약 양자를 진화적 관계로 이해한다면 ‘무의미한 관행’은 ‘나쁜 관행’으로 심화되는 한 경로가 된다. <표2>를 통해 ‘강한 의미에서의 무의미한 관행’은 ‘가장 약한 의미의 나쁜 관행’이기도 하다는 점을 보였는데, 나쁜 관행은 다른 외적 기준에 의해 판정될 수도 있다. ‘나쁜 관행’인지 여부를 판별할 잠정적 심사 기준을 제시하면 다음과 같다. 이에 따라 만약 어떤 관

64) 임미원, “탈관습적 시대의 규범적 논거들의 계보”, 한양법학 제24권 제1호, 한양법학회(2013), 161면.

65) ‘비판적 이성성’이나 ‘이성적 정당성’의 결핍 문제는 ‘나쁜 관행’ 개념의 구성적 요인으로도 볼 수 있다. 그리고 바로 그 점이 비판적·반성적 성찰 작업이 법적 추론 과정에 반드시 추가되어야 하는 이유이기도 하다. 이는 결국 ‘반성적 관행으로서의 법’[논제2]과 ‘반성적 추론’ 그리고 ‘성찰적 법관행주의’[논제3]라는 이 글의 핵심 논제로 귀결된다.

66) 이현경, “법학적 관행 이론 소묘(素描)”, 45-52면.

행이 ‘나쁜 관행’으로 판정되면 ‘관행 준중의 원칙’과 ‘추정적 효력 테제’의 임계점을 넘어 그 효력이 상실되며, 따라서 준수 의무도 소멸된다.

심사 기준	‘나쁜 관행’이지 않을 조건	
합목적성 심사 [내적기준]	관행이 구현하고자 하는 목적·취지나 가치에 반하거나 이를 왜곡하지 않는다.	
정합성 심사 [외적기준]	공동체 P의 상위 규범질서 및 인접/연합질서와의 원리 및 체계 정합성을 현저히 해치지 않는다.	
공정성 심사 [외적기준]	A	형평과 공정성의 원리에 위배되지 않는다.
		관행을 통한 공통이익(共益, common interest) 실현이 공적 이익(公益, public interest) ⁶⁷⁾ 을 현저히 위협하지 않는다.
		B 민주적 공공성에 현저히 반하지 않는다.

<표3> ‘나쁜 관행’의 판정 기준 및 핵심 내용

“합목적성 심사”는 앞서 ‘가장 약한 의미에서의 나쁜 관행’에서 설명한 바와 같다. “정합성 심사”는 전체 법질서 안에서 관행이 체계적·원리적 정합성을 저해하지 않아야 한다는 요청이다. 가령 위법적이거나 위헌적 내용을 담고 있는 경우를 들 수 있다. 위헌적 법률의 효력을 기각하듯, 헌정 질서에 반하는 법적 관행도 효력이 부인될 수 있다.⁶⁸⁾ ‘공정성 심사’는 관행이 갖는 복합적·혼종적인 특성 및 관행에 특유한 특징을 고려하여, 특별한 의미에서의 실질적 심사를 도입한 것이다. 특정 이해집단 내부에서 은밀하게 형성되거나 소수의 공통 이익 실현으로 인해 공적 이익을 현저히 위협하는 경우, 공지성 조건(publicity condition)을 현저히 위반하여 ‘민주적 공공성’⁶⁹⁾을 심히 해치는 경우를 예로 들 수 있다.

지금까지 ‘나쁜 관행’의 개념, 판정 기준 및 효력에 관하여 살펴보았다.

67) 법학에서 ‘공익’의 개념·내용·위상 등을 폭넓고 깊이 있게 고찰한 연구로는 김도균, “법원리로서의 공익”, 서울대학교 법학 제47권 제3호, 서울대학교 법학연구소(2006). 참고.

68) 다만 유의할 점이 있다. ‘위법적’ 혹은 ‘위헌적’ 관행이라고 표현할 때, 여기서 전제하는 ‘법’과 ‘헌법/헌정’의 개념 및 의미에 대한 추가 논의가 필요하다. 이런 점에 대한 고려를 포함하여, 여기서는 단정적 표현이 아닌 “부인될 수 있다”는 유보적 표현을 사용한다.

69) 필자가 말하고자 하는 ‘민주적 공공성(democratic publicity)’은 ‘publicity’와 ‘publicness’ 두 측면을 다 담고 있다. 다만 ‘③-A’ 기준과의 차별화를 고려할 때, ‘③-B’의 ‘민주적 공공성’은 공지성 요건을 중심으로 한 ‘publicity’를 중심으로 이해하는 것이 낫겠다.

그렇다면 ‘나쁜 관행’ 문제는 법적 추론에서 ‘법원으로서의 관행’ 문제와 관련하여 어떻게 다루어질까? 소극적·예외적 사안으로 나쁜 관행 문제를 이론화 과정에서 생략할 수 없다면, 법 본성론이나 법적 추론의 대안 모델 구상에 있어 어떠한 방식으로 반영하고 구체화할 수 있을까?

3. 법적 추론에서 법원으로서 관행의 역할 및 효력

가. 법적 추론에서 원천의 규범력에 따른 ‘법원-삼분법’과 관행론의 대응
지금까지의 논의를 종합하여 이제 ‘법원으로서의 관행’ 문제에 다시 집중해 보자. 전술했듯이, 법원을 사용한다는 것은 법원을 해석함을 뜻한다. 법령이나 선례, 관습 등 각종 원천들은 드워킨 식으로 말하면 전해석적 단계에서 일종의 ‘법적 자료’에 해당하며 이는 법관의 법해석 작용을 거쳐 법규범으로 전환된다.⁷⁰⁾ 그렇다면 법적 추론 과정에서 법원의 역할은 무엇인가? 법원으로서 관행이 제공하는 행위 이유는 어떤 종류이며, 참여자인 법적 주체의 추론 과정에서 어떠한 역할을 할까?

법의 원천에도 규범적 위계가 존재한다. 법적 추론의 맥락에서 법원의 규범력 정도에 따라 섬세하게 세 종류로 구분해 보자.⁷¹⁾ 첫째, ‘의무적 원천(mandatory source)’은 그 규범력을 끝까지 인정해야만 하는 원천(‘must-sources’)이다. 둘째, ‘기각 가능한 원천(defeasible source)’은 규범력을 일단 인정해야 하는 원천(‘should-source’)이다. 셋째, ‘허용적 원천(permissive source)’은 규범력을 인정하는 것이 허용되는 원천(‘may-sources’)을 말한다.⁷²⁾ 이에 대한 피노의 설명을 참고해 보자.

‘의무적 원천’, ‘허용적 원천’, ‘기각 가능한 원천’의 차이는 법적 논증에서 잘 드러난다. 이런 관점에서 볼 때, ‘의무적 원천’의 사용은 법적

70) ‘법해석주의자’로 일컬어지는 드워킨은 전해석적 단계-해석 단계-후해석적 단계를 구분한다. 드워킨은 법해석주의를 통해 고전적 자연법론이 갖고 있는 한계를 극복한 현대적 비실증주의로 평가되는데, 그의 해석적 법개념은 ‘구성적 해석’ 기법에 근거한다. Ronald Dworkin(장영민 역), 법의 제국, 아카넷(2004), 83-85면, 97면 이하. 드워킨의 구성적 법해석론을 우리 대법원 판결에 적용하여 분석·논평한 연구로, 김도균, “우리 대법원 법해석론의 전환: 로널드 드워킨의 눈으로 읽기-법의 통일성을 향하여”, 법철학연구 제13권 제1호, 한국법철학회(2010). 참고.

71) 페체니크와 세카이라를 참고하였다. Aleksander Peczenik, *On Law and Reason*, Springer, 2008.

72) 조동사 번역서 선정과 이유 구분에 귀중한 조언을 주신 심사위원님께 깊이 감사드립니다.

용 기관에 의해 적절히 정당화될 필요가 없다(그것의 사용은 평상적 업무일 뿐이다). 반면, ‘허용적 원천’의 사용은 일반적으로 전체 결정의 수용 가능성을 강화할 필요성이나 의무적 원천이 비결정적이거나 불완전하다는 사실 등을 참조하여 법적용 기관이 적절하게 정당화하도록 요청된다. ‘기각 가능한 원천’의 사용은 정당화를 요하지는 않지만, 해당 원천을 배제하려면 법적용 기관에 적절한 논증 부담이 있다.⁷³⁾

제2장에서 우리는 관행의 규범적 위계를 논하였다. 그렇다면 ‘법원으로서의 관행’ 논제는 원천의 차등적 규범력에 따른 ‘원천-삼분법’에 어떻게 대응할까? 각 유형의 관행이 제공하는 행위 이유는 법원론의 시각에서 볼 때 어떤 종류에 해당하는가? ‘법원-삼분법’에 대해 좀 더 살펴보자.

첫째, ‘의무적 원천’은 가장 강한 규범력을 갖는 법원이다. 의무적 원천은 행위자에게 행위 이유를 제공[‘이유-제공적 규범성(reason-giving normativity)’]할 뿐 아니라 준수할 책무까지 부과[‘책무-산출적 규범성(obligation-generating normativity)’]한다.⁷⁴⁾ 그것이 제공하는 행위 이유는 ‘반드시 이유로 삼아야 하는 것’이며, 가령 법관의 경우 의무적 원천의 사용은 마땅히 해야 할 통상 업무에 속하기에 별도의 정당화가 필요 없다. ‘법원론’의 시각에서 보면, 형식적 법원으로서의 법률이나 관습법과 같이 목록화할 수 있는 실정법이 이에 속한다. 또한 ‘관행 이론’의 면에서 보면, 관행의 ‘강화 조건’-①공통 지식과 공식적 표명, ②시간적 지속과 반복, ③제도적 지지, ④도덕적 이유의 존재[Ⅱ-1-(2)]-을 충족한 ‘강력한 관행’이 그 후보가 될 수 있다. 특히 제도적 공식성 요건[③]을 최고도로 달성한 ‘법제화된 관행’은 법체계 안에서 이미 실정법적 지위를 획득하였기에 확실한 의무적 원천이 된다. 실질·내용적 정당성 요건을 강하게 갖춘 ‘도덕적으로 바람직한 관행’[④]도 의무적 원천에 포함될 가능성이 높다.⁷⁵⁾ 둘째, ‘기각 가능한 원천’은 이원적 모

73) Giorgio Pino, 앞의 논문(주34), p.84. [강조]는 필자]

74) 관행이 갖는 규범력의 종류 및 위계에 관한 상세한 설명은 이현경, “규범으로서의 관행: 분류적 차원의 고찰”, 법학논총 제34권 제3호, 한양대학교 법학연구소(2017). 참고.

75) 다만 강한 법실증주의 입장을 견지한다면, 만약 어떤 관행이 강화 조건 ①-③의 보충이 전혀 없이 오직 ‘도덕적으로 바람직함’이나 ‘도덕적 이유의 존재’ 단독 요건만 충족할 경우 ‘기각 가능한 원천’에 위치시키거나 ‘의무적 원천’과의 사이에서 고심할 공산이 크다. 이

텔[=‘의무적-허용적 원천’]로는 담기 어려운 중간 영역을 규율하기 위해 추가한 유형이다.⁷⁶⁾ ‘기각 가능한 원천’이 제공하는 이유-제공적 규범성의 내용은 ‘이유로 일단 삼아야 하지만 이유로서 기각될 수도 있는 것’으로서, 만약 더욱 강력한 특별한 사유가 발견되지 않는 한 그 원천의 추정된 효력은 유지된다. 다만 그것에 따라야 할 준수 의무에 대해서는 유보적이다.⁷⁷⁾ ‘관행 이론’의 시각에서 보면, ‘기각 가능한 원천’은 대체로 성숙한 형태의 법적 관행인 경우가 많지만, 그 경계가 엄격한 것은 아니다. ‘의무적 원천’과 ‘기각 가능한 원천’은 규범적 사실⁷⁸⁾의 존재론적 위상을 갖는다. 셋째, ‘허용적 원천’은 행위자에게 그것을 ‘이유로 삼는 것이 허용되는 것’⁷⁹⁾으로 이유 제공적 규범성을 갖지만, 준수할 책무는 부과되지 않는다. 하트는 “법체계는 [판사가] 이러한 원천 [=허용적 원천]을 사용하도록 요구하지는 않지만, 그렇게 하는 것이 지극히 적절한 것으로 받아들여지고 있다.”고 하면서 이는 “판결에 대한 ‘정당한 이유’로 인정”⁸⁰⁾된다고 논하였다. 세카이라도 “허용적 원천은

경우 다른 배경적 요인들이 위상 결정에 영향을 미치게 된다.

- 76) Giorgio Pino, 앞의 논문(주34), p.84. (“이것의 사용은 완전히 의무적인 것은 아니지만 단순 허용되는 것도 아니다. 피할 수 없는 원천은 법 적용 기관에서 고려해야 하는 원천이며, 불이행 시 강력한 이유가 제시되지 않는 한 무효 또는 기타 법적으로 잘못된 결정이 내려질 수 있다.”)
- 77) 이를 이하의 <표4>에서는 ‘△’ 표시하였고, 그 이유는 해당 각주에 상세한 설명을 달았다.
- 78) ‘규범적 사실’이란 ‘사실성’과 ‘규범성’을 겸비한 사태를 말하는데, 엄격한 방법이원론을 취한다면 일견 개념적 모순으로 여길지도 모른다. 그러나 ‘제도적 사실’(John Searl, Neil McCormick), ‘규범적 사실’, ‘도덕적 사실’(Moral Realist) 등과 같은 규범력을 내포한 사실들에 관한 철학적 논의가 적지 않다. 필자도 이런 흐름을 지지하며 궁극적으로 존재-당위 이원론, 사실-가치 이분법 등과 같은 각종의 이분법을 극복하고자 한다. 필자의 ‘법학적 관행 이론’도 일면 이러한 철학적 토대에 기반한다. 이현경, “제도적 사실로서의 법 - 그 철학적 기초와 법이론적 함의”, *홍익법학* 제18권 제2호, 홍익대학교 법학연구소(2017). 참고.
- 79) 기존 용어법을 활용하면 ‘허용적 원천’이 제시하는 이유를 ‘일응의 행위 이유’로 축약하여 표현할 수도 있다. 예컨대 그린도 ‘허용적 원천’에 대해 “법원(法院)이 ‘적용하도록 허용된’ 것이자 동시에 ‘일응적 이유(prima facie reasons for courts)’”라고 설명한다. Leslie Green, “Law and the Causes of Judicial Decisions”, *University of Oxford Legal Research Paper Series* 14, p.19. 그런데 엄밀하게 숙고해보면, 이는 ‘법원으로서의 관행’ 논제와 관련해서는 적확하지 않은 면이 있다. 그래서 심사위원님의 조언에 따라 그 의미를 풀어 설명하는 방식으로 최종본에서는 수정하였다. 익명의 심사위원님께 감사드립니다. 참고로 라틴어 표현 ‘prima facie’는 ‘첫눈에’ ‘일견’ ‘첫인상에 근거하여’라는 의미가 있다. (“나중에 거짓으로 드러날지라도) 처음에 진실로 여겨지는, 일단 볼 때의”라는 뜻을 갖는다.
- 80) H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, 1961, p.247.

법적 추론과 의사 결정에 사용될 수 있지만 꼭 그럴 필요는 없는 원천으로 특징지어지는 경우가 많다.”⁸¹⁾고 설명한다. 허용적 원천은 법실증주의자에게는 주로 법의 흠결 사안에서 법보충의 가능한 자원으로 적극 고려되고 선택되곤 한다. 셰카이라는 “허용적 원천의 중요성은 당해 의무적 원천의 가용성과 결론에 따라 달라진다.”⁸²⁾고 말한다. 가드너(John Gardner)도 “의무적 원천이 결정적 규범을 제시하지 못할 때 허용적 원천이 더 중요한 (공백을 메우는) 역할을 할 수 있다.”⁸³⁾고 논하면서, 법흠결 보충 수단으로서 허용적 원천의 의의를 강조한다.⁸⁴⁾ 이런 특징에 착안하여 관행 이론과 연계해 보면, ‘약한 의미에서의 무의미한 관행’ 및 ‘단순 관행(mere convention)’이 허용적 원천으로 이해될 수 있다. ‘단순 관행’이란 ‘법적 관행 정식’을 충족한 적격의 진성 관행의 별칭으로, 그 성숙도나 규범력의 강도 면에서 ‘강력한 관행’에는 이르지 못한 점을 차별화하기 위한 용어다. 또한, 사람들이 점차로 준수하지 않아서 ‘약한 의미에서의 무의미한 관행’이 된 경우에도, 기존에 진성 관행으로 존속해 왔다는 사실 자체가 ‘정당한 이유’로 인식되어 참여자에게는 모종의 행위 이유로 기능할 가능성도 있다. 개별 행위자의 관점에서는 실효성의 상실 여부나 정도를 명확히 식별할 수 없는 경우도 있을 수 있기에 이는 ‘허용적 원천’으로 분류될 수 있다.

나. 관행의 변천, 그리고 ‘법원으로서 관행’ 삼분법 대응의 의의 및 한계

관행은 목시적인 자율적 질서로, 그 본성상 형성-발전-퇴보-소멸에

81) Fábio Perin Shecaira, “Sources of Law Are not Legal Norms”, *Ratio Juris*, 2015, p.24.

82) Fábio Perin Shecaira, 위의 논문(주81), p.24.

83) John Gardner, “Concerning Permissive Sources and Gaps”, *Oxford Journal of Legal Studies* 8, 1988, p.457.

84) 만약 ‘관행 이론’과 결합하지 않고 오직 법원론 시각에서만 ‘허용적 원천’의 유형을 논한다면 법실증주의 입장에서는 대표적으로 법원리가 이에 해당할 수 있다. 실증주의자에게 법원리는 일종의 실증 도덕으로 이해되며, 그 자체는 법규범이 아니지만 실정법의 흠결 보충을 위한 방편으로 동원될 수 있다. 하지만 법실증주의자에게 법원리는 어디까지나 ‘허용적 원천’이기에 그것을 사용할지 여부, 즉 법원리를 통해 법흠결을 치유할지는 전적으로 선택적이다. 반면, 드워킨과 같은 법원리주의자-법체계는 법규칙과 법원리로 구성되며, 법원리는 법규범의 한 유형이라고 보는 견해-나 비실증주의자에게 법원리는 ‘허용적 원천’이 아닌 ‘의무적 원천’이나 ‘가장 가능한 원천’의 위상을 갖는다고 볼 수 있다.

이르는 각 단계가 시점적·단발적으로 이뤄지기보다는 진화적·점진적 과정으로 이어지는 특징이 있다. 한편으로는, 양(+)의 방향에서 맹아적 관행 규칙에서부터 진성 관행(초기의 단순 형태에서부터 성숙기 관행까지), 나아가 강화 조건까지 충족한 강력한 관행에까지 이르는 변화의 단계가 존재한다. 다른 한편, 관행이 점차로 준수되지 않아 실효성이 약화되어 일반적 준수 의존성이 제거되고 결국 무의미한 관행, 나아가 관행의 소멸로까지 이어지는 음(-)의 방향의 퇴보 과정을 겪기도 한다. 이러한 현상을 ‘관행의 변천’이라 부를 수 있다. 관행의 실제에 제대로 접근하기 위해서는 관행의 전체 생애 주기를 동적으로 파악하는 것이 중요하다.⁸⁵⁾ 그런데 법원론의 시각에서 보면, 관행의 이러한 연속적·진화적인 특징으로 인하여 특히 법적 추론에서 ‘법원으로서의 관행’의 유형과 경계를 이론적으로 명확히 구분하기는 쉽지 않다. 그로 인해 ‘법원-삼분법’에 관행을 일대일 대응 관계로 확정하려는 시도 역시 그 한계를 겹쳐서 인정할 필요가 있다. 하지만 이는 ‘법원으로서의 관행’ 논제의 핵심 개념인 ‘원천’과 ‘관행’ 자체가 갖는 본질적 애매성에서 연유된 것일 뿐 오류나 결함은 아니다. ‘법원으로서의 관행’이 법실천의 다양한 장에서 실제 법적 의사 결정 과정에서 주체에게 행위 향도적 기능과 일견 객관적 지침을 제공할 수 있다는 점에서는 의의가 크다. 특히 법철학, 기초법학 관점에서의 토대 연구로, 법적 추론에서 법원론과 관행 이론을 결합하는 본 연구는 이론과 실무의 조응, 법이론과 법실천의 동행⁸⁶⁾을 가능하게 하는 의미 있는 이론적 시도로 볼 수 있다. 지금까지의 논의를 표로 정리하면 다음과 같다. 이는 입법 및 사법 추론에서 모두 유효하다.

85) 관행의 복잡성과 역동성 파악을 위해서는 방법론적 차원에서도 동적 접근이 요청된다. 이현경, “동적 관행 이론”, 강원법학 제51권, 강원대학교 비교법학연구소(2017), 143면.

	정적 이론 [정태적 모델]	동적 이론 [동태적 모델]
개념관 (conception)	정적 균형	동적 균형
	경직된 관행관	유연한 관행관
연구주제 (theme)	준수의무론	관행의 생성과 소멸 과정, 균형 선택의 문제

86) 이 점을 강조하고 있는 대표적인 최근 연구로는 김재형, “이론과 실무의 조응”, 서울대학교 법학 제65권 제2호, 서울대학교 법학연구소(2024). 참고.

원천	효력 없는 원천	유효한 원천		
		허용적 원천 [선택적]	기각 가능한 원천	의무적 원천 [구속적]
		규범력을 인정하는 것이 허용되는 원천	규범력을 일단 인정해야 하는 원천	규범력을 끝까지 인정해야만 하는 원천
관행	나쁜 관행, 강한 의미의 무의미한 관행	약한 의미에서의 무의미한 관행, (단순) 진성 관행	(성숙) 진성 관행, 강력한 관행 ⁸⁷⁾	강력한 관행 [특히, 법제화된 관행]
이유 제시력	허위의 이유	이유로 삼는 것이 허용되는 것	이유로 일단 삼아야 하지만 이유로서 기각될 수도 있는 것	반드시 이유로 삼아야 하는 것
책무 산출력	X	X	△ ⁸⁸⁾	O

〈표4〉 법원으로서 관행의 규범력과 그 종류⁸⁹⁾

다. 원천의 효력관 및 효력 없는 원천의 문제

앞서 살펴본 법원의 차등적 규범력에 기초한 ‘법원-삼분법’과 관행론의 대응은 모두 효력 있는 원천을 대상으로 한 설명이다. 이런 논의를 가능하게 하는 전제로 어떤 효력관을 취하는지의 문제가 중요하다. 그런데

87) 〈표4〉에서 ‘강력한 관행’을 ‘기각 가능한 원천’과 ‘의무적 원천’ 양쪽에 배치한 이유는 다음과 같다. 첫째, 실제로서 관행 자체의 존재론적 차원에서 보면, 관행은 본질상 그 존속 및 발전에 있어 일련의 연속적 과정의 특성을 내포하기에, 단편적으로 명확한 경계 짓기가 어렵다. 이 점은 둘째, 인식론적 차원에서 보면 현실적으로 결국 판단·추론자의 판단과 평가에 따라 법원론적 위상이 결정될 가능성이 높다. IV-1.에서 다루는 ‘발행지 기재 없는 어음 판결’의 다수의견과 반대의견의 입장 차를 통해서도 이 점을 확인할 수 있다.

88) ‘기각 가능한 원천’의 규범력 정도 및 성격과 관련하여 “△”라는 유보적 표기를 한 이유는 개별 ‘관행 그 자체’의 독자적 차원에서 ‘책무 산출적 규범력’ 문제를 확정하기가 쉽지 않기 때문이다. 성숙기 관행이나 강력한 관행은 (사회학적 차원에서) 공동체법이나 문화규범의 성격을 강하게 내포하기에, 관행 질서가 작동하고 있는 제반 여건 및 관계구조적 환경과의 상호작용 속에서 그 준수 의무의 존부·정도가 인식되고 승인될 가능성이 크다.

89) 〈표4〉에서 ‘관행’으로 표기된 것은 ‘법적 관행’을, ‘원천’은 ‘법의 원천’을 축약한 것이다. 이 글의 논제들에서 관행은 ‘법적 관행 정식’ 조건을 충족한 ‘진성의 법적 관행’을 뜻한다.

순전한 형식주의 관점을 취하지 않는 한, 법적 추론 과정의 어느 지점에서 유효한 원천의 효력을 재고하거나 부정하게 되는 순간이 발생할 수 있다. 따라서 효력 없는 원천에 관한 숙고도 요청된다.[<표4>의 제일 왼쪽 부분] 법원의 효력은 어떠한 개념관을 전제하는가? 법원의 효력 유무와 범주를 구분하는 실익은 무엇인가? 이론적·실천적 차원을 나누어서 이 문제에 접근하면 좀 더 풍부하고 입체적인 설명이 가능할 것이다.⁹⁰⁾

우선 법원(法源)의 효력 관념 및 조건에 관해 논해보자. 이론적 차원에서 ‘법원으로서의 관행’의 효력 여부를 판정하는 방법, 다시 말해 <표4>에서 ‘유효한 원천으로서의 관행’과 ‘효력 없는 원천으로서의 관행’을 가르는 기준은 무엇일까? 우리는 제2장에서 법의 원천과 법규범을 구별하는 ‘원천-규범 구별’ 논제를 논했다. 오늘날 원천 개념에 주목하는 대부분의 논자는 ‘법원’과 ‘법규범’의 개념적 구별에 대체로 동의한다. 다만 그 구체적 방식이나 양자 간 관계성의 양상 및 기제에 대한 설명법에서 차이를 보이며, 그 과정에서 원천의 효력 기준 대한 견해차를 확인할 수 있다.⁹¹⁾ 예컨대 피노는 “엄밀히 말하면, 법규범은 원천에 의해 생산되는 것이 아니라 원천의 해석에 의해 산출된다.”고 한다. 이를 기초로 그는 법원과 법규범의 효력 판별 기준에 대해 다음과 같이 설명한다.

법의 원천과 법규범은 서로 다른 효력 조건을 갖는다: 법원의 효력은 일반적으로 절차의 올바른 실행에 달려있는 반면(‘형식적’ 효력), 법규

90) 법효력에 관한 국내의 토대 연구로는, 심헌섭, “법의 효력에 관한 연구”, 서울대학교 법학제21권 제1호, 서울대학교 법학연구소(1980). ; 최봉철, “법의 효력 요건과 효과를 중심으로”, 법철학연구 제17권 제3호, 한국법철학회(2014). ; 김학태, 법을 통한 과거청산-법효력에 관한 법철학적 근거, 외법논집제18권, 한국외국어대학교 법학연구소(2005). ; 이재승, “법효력의 계속과 차단,” 법철학연구제6권 제1호, 한국법철학회(2003). ; 이동희, “법의 효력,” 법학논총 제24권, 단국대학교 법학연구소(2000). ; 양천수, “민주적 법치국가에서 본 법규범의 효력근거-법철학의 관점에서”, 법과 사회 제38권, 법과사회이론학회(2010). ; 이계일, “포스트실증주의 법사고와 법효력론,” 법철학연구 제13권 제2호, 한국법철학회(2010). ; 변종필, “법의 효력과 근본규범,” 안암법학 제5권, 안암법학회(1997). ; 문종욱, “법효력론과 ‘5·18’ 현재결정,” 법학연구 제12권 제1호, 충남대학교 법학연구소(2001). ; 김대근, “이유로서의 법-법효력의 근거로서 이유의 가능성과 전망,” 법학연구 제35권 제1호, 충남대학교 법학연구소(2024). 등 참고.

91) 피노는 “법의 원천은 법규범을 직접적으로 산출하지 않으며, 오히려 원천은 규범-형식을 생산한다”고 한다. Giorgio Pino, 앞의 논문(주34), p.68.

법의 효력은 그 규범이 계층적으로 더 높은 다른 규범과 양립할 수 없다는 사실에 달려 있다(‘실질적’ 효력). 따라서 (공식적으로) 유효한 법원이 (실질적으로) 무효인 법규범을 전달할 수 있다. 또는, 하나의 동일한 법원이 두 개의 상충하는 해석에 따라 유효한 규범을 산출하거나 무효의 규범을 산출할 수 있다. 바로 이러한 가능성이 ‘위헌 판단 회피 원칙(Constitutional Avoidance)’⁹²⁾의 배경에 있다.⁹³⁾

요컨대 피노는 ‘법원-법규범의 구별’을 기초로, 법원의 효력은 절차적 측면에서 유효성이 판정되는 ‘형식적 효력’ 기준에 따라, 법규범의 효력은 상위 규범과의 내용적 부합 여부에 따른 ‘실질적 효력’ 기준에 따른다고 주장한다. 이런 견해는 효력에 관한 실증주의적 설명법을 법원론과 접목한 것으로 볼 수 있다. 법의 원천에 관한 또 다른 선도적 논자이자 법실증주의를 견지하는 카르펜티에는 ‘원천’을 ‘합법성을 부여하는 사실(legality-endowing facts)’, 즉 어떤 규범에 법적 자질을 주는 사실로 정의하면서 법규범은 오직 그 원천을 추적할 수 있을 때만 가능하다고 한다. 이런 설명은 라즈(Joseph Raz)의 ‘원천 테제’⁹⁴⁾의 기본 틀을 수용·전제하고 있음을 알 수 있다. 카르펜티에는 현대 법체계에서 사회적 원천이 하는 역할로 ‘단순 모델’을 제안한다. 단순 모델은 법적 효력 개념의 애매성을 해소할 뿐 아니라 고전적인 법철학적 수수께끼를 해결하는 데도 도움이 된다고 한다. 단순 모델에 입각하여 그는 법효력에 관한 두 개념관으로 ‘멤버십으로서의 효력’과 ‘일치(conformity)로서의 효력’을 제시한다. ‘일치로서의 효력’은 실질적인 규범적 요구사항을 충족해야 그 유효성을 인정받을 수 있다는 관점이며, ‘멤버십으로서의 효력’은 해당 체계의 성원성을 인정받으면 그 자체로 효력 있음이 인정된다. 그는 헌법은 ‘일치로서의 효력관’에 따라 법이 준수해야 하는 규범적 요구사항의

92) ‘위헌 판단 회피 원칙’이란 제정법 해석에 있어서 위헌 소지를 회피할 수 있는 해석을 우선적으로 채택해야 한다는 원칙으로, 미연방대법원이 19세기 초반부터 적용해 왔다. 조동은, “미국 연방대법원의 위헌 판단 회피 원칙과 그 한국적 시사점-법원의 헌법합치적 해석 및 위헌법률심판 제정의 기준과 관련하여,” 서울법학 제26권 제3호, 서울시립대학교 법학연구소(2018).

93) Giorgio Pino, 앞의 논문(주34), pp.68-69.

94) Joseph Raz(권경휘 역), “권위, 법 그리고 도덕”, 법철학연구 제12권 제1호, 한국법철학회(2009), 504면 (“원천 테제: 모든 법은 원천(源泉)에 기초한(source-based) 것이다.”). 라즈의 원천 테제에 대한 상세한 설명은, 엄순영, “라즈의 원천 테제”, 법철학연구 제18권 제3호, 한국법철학회(2015). 참고.

집합으로, ‘승인율’은 전자의 효력관에 따라 ‘멤버십 기준의 집합’으로 설명한다. 요컨대 그는 원천을 ‘합법성을 부여하는 사실’로 정의하고, 멤버십의 의미에서의 효력관을 수용한다.⁹⁵⁾

이 결론은 법과 법적 효력이 궁극적으로 정당성에 대한 배경적 개념관에 의존하지만, 효력이 어떻게 작용하는지를 이해하기 위해 법의 정당성(law's legitimacy)에 대한 포괄적 이론은 필요하지 않음을 보여준다. 법이 작동하는 방식(“how”)이 그 정당화보다 더 흥미로울 수 있으며, 법과 합법성에 대한 철학적 설명을 위해 그러한 정당화는 필요하지 않을 수 있다.⁹⁶⁾

카르펜티에에 따르면 ‘규범성’이나 ‘정당성’에 대한 이론 없이도 법효력에 관해 논할 수 있다. 왜냐하면 법의 합법성을 부여하는 사실로서의 원천의 효력은 멤버십 자격 여부로만 관정되기 때문이다. 원천의 효력에 관한 이런 실증주의적 설명은 만족스러운가? 생각건대, 이러한 접근과 설명법은 이론적 설명을 단순·명확하게 해주는 것처럼 보이지만, 교차적이고 복합적인 성격을 갖는 관행에 대해서는 부정확하거나 불충분한 면이 있다. 관행은 제도로서의 특성뿐 아니라 공동체법⁹⁷⁾이자 문화 규범으로서의 성격도 강하게 내포한다. 따라서 관행의 최종적 효력 관정을 그 실질적 특질과 무관하게 오롯이 형식적·절차적으로 소속 여부로만 확정하는, 즉 ‘멤버십으로서의 효력관’으로만 담아내기에는 한계가 있다. 물론 이런 소극적·유보적 평가가 자연법론적 논변처럼 정의 이념이나

95) Mathieu Carpentier, “Sources and Validity”, in *Legal Validity and Soft Law*, Pauline Westerman · Jaap Hage · Stephan Kirste · Anne Ruth Mackor (eds.), Springer, 2018. 법철학 이론사적으로 보면, 카르펜티에는 법실증주의자인 켈젠과 하트를 계승한다고 볼 수 있다.

96) Mathieu Carpentier, 위의 논문(주95), p.95.

97) ‘공동체법으로서의 관행’이란 표현은 중의적이다. 첫째, 국가기관이 상명하달식으로 형성하는 제정법이 아니라 공동체 성원들의 자율적 상호작용을 통해 자발적으로 형성된 질서라는 의미에 강조점을 둔다. 둘째, 공식적인 국가법체계 하위의 다양한 비공식적인 규범적 질서를 의미한다. 이런 면모는 사회 각계각층의 관행을 나타내는 언어적 표현을 통해서도 쉽게 확인할 수 있다. 예컨대 출판계 관행·언론계 관행·예술계 관행·스포츠계 관행 등 관행을 말하지 않는 분야를 찾기 힘들 정도로 특히 한국 사회에서 관행 현상은 그 양상이 매우 다양하고 뿌리도 깊다. ‘공동체법’이라는 명명에서의 ‘법’은 공식적인 법제도적 권위를 부여받은 실정법이라기보다는 일종의 ‘살아있는 법’으로서의 광의의 사회학적 법개념 용어법에 착안한 것이다.

도덕에 강하게 호소하거나 ‘정당성’에 대한 필연적 연관성 주장을 함축한다고 보기는 어렵다. 핵심은, 두 버전의 순규범주의 모델이나 접근은 관행의 복합적·혼종적 본질을 고려할 때 효력관으로서 적확하지 않은 점이 있다는 것이다. 요컨대 전통적인 ‘형식적 원천 vs. 실질적 원천’의 이분법이나 ‘멤버십으로서의 효력 vs. 일치로서의 효력’이라는 실증주의적 구분법과 효력관을 ‘법원으로서의 관행’ 사안에 그대로 적용하는 데는 신중함이 필요하다. 그렇다면 나쁜 관행 문제를 포함하여 관행 일반의 효력 여하를 판별할 적절한 기준이나 원칙은 무엇일까? 이 지점에서 우리는 다시 ‘관행 이론’에 좀 더 의지할 필요가 있다.⁹⁸⁾

법적 추론의 차원에서 ‘법원으로서의 관행’의 효력 유무는 어떠한 실천적 의미를 가질까? 효력이 없다는 것은 더 근본적인 차원에서 규범성 자체가 결여된 것으로, 실천적 추론 과정에서 준수 의무는 물론이거니와 행위 이유도 제공하지 않는다. 때로는 외관상 이유 있다고 말해지는 경우도 있을 수 있지만 이는 허위의 이유이며, 진정한 의미에서의 실천적 이유라고 할 수 없다. 따라서 이 경우 행위자의 법적 추론에서 어떠한 규범력도 발생시키지 않는다. 관행 이론의 관점에서 보면, 앞서 <표3>과 <표4>를 통해 그 의미와 기준을 구체화한 ‘나쁜 관행’이나 ‘강한 의미에서의 무의미한 관행’이 이 범주에 속할 수 있다. 우리는 무비판적인 법복종의무와 진지한 수범의무를 구별할 필요가 있다.⁹⁹⁾ 특히 <표4>의 ‘나쁜 관행’ 판정 기준을 심각하게 위반한 질서는 불법적이거나 범죄에 해당할 수 있는 잠재적 위험성도 있기에, 그 규범력과 효력에 관한 탐구를 넘어 궁극적으로 법실천과 그 해결의 차원에까지 논의를 확장할 필요가 있다.

4. 법원 간의 충돌 문제와 그 해결

가. 법원으로서의 관행과 실정법의 긴장 및 충돌

서두에서 우리는 ‘법보다 관행이 더 가깝다?’라는 의문문을 던지고, 이를 구체화할 수 있을 세 논제로 “(a) 법의 사회적 기원과 원천은 관행이

98) 다만 이 글의 목적이 ‘단순 모델’에 대항하는 이론 모델이나 대안적 효력관을 제안하는 것은 아니기에 여기서는 그 한계를 지적하는 것으로 여기서는 충분할 것 같다.

99) ‘진지한 수범의무’와 ‘법 복종 의무’의 구별에 관해서는, 이민열, “법해석에 있어서 정치철학의 투입점-진지한 법준수 의무와 규범의 충위”, 법철학연구 제26권 제1호, 한국법철학회(2023). 참고.

다.[→ ‘법원으로서의 관행’], (b) 법과 관행은 때로는 긴장 및 충돌 관계에 있을 수 있다.[→ ‘관행의 효력 및 법원 간의 규범적 긴장’], (c) 법적 추론 맥락에서 때로는 관행이 법보다 더 강한 규범력을 갖는다.”를 제시했다. 지금까지 (a)를 중심으로 (b)(c)에 대한 문제의식에까지 이르렀다면, 이제 본격적으로 (b)와 (c)를 논하고자 한다. 이와 관련한 법현상으로 종종 우리는 관행이 실정법을 무력화하는 파기적 효력¹⁰⁰⁾을 접하기도 한다.

법적 추론에서 법적 주체는 다양한 종류의 규범적 긴장 상황에 직면한다. 켈젠은 법체계를 폐쇄적인 완결적 체계로 이해하여 실정법질서 안에서 진정한 의미의 규범 충돌이란 존재하지 않는다고 단언한다.¹⁰¹⁾ 그렇다면 현실에서 관찰되는 (b)나 (c)와 같은 경우는 법이론적으로 어떤 설명이 가능할까? 우선 갈등 상황의 양상을 세 경우로 구분해 볼 수 있다. 첫째, 동위에 있는 두 법원 간의 ‘횡적 갈등’이다. 예컨대 법규칙들 간의 충돌이 대표적이다.¹⁰²⁾ 또한 (법철학적 입장에 따라 다른 위계화가 가능할 수 있지만) 법규칙과 법원리 간의 갈등 상황도 있다.¹⁰³⁾ 둘째, 상하 관계에 있는 법원 간의 ‘종적 갈등’이다. 위헌적 법률의 문제나 ‘부정의한 법’의 효력 문제 등이 있다. 셋째, 관행과 실정법 간의 갈등으로, 이는 앞의 두 양상이 혼합된 특징이 있다. 이들 중 특히 마지막, 관행과 실정법 간의 갈등 상황은 (b)(c)를 나타내는 대표적인 경우로 볼 수 있다. ‘법원-법규범의 구별’ 논제에 입각하면, 이는 ‘법원으로서의 관행’과 ‘법원으로서의 실정법령’ 간의 규범적 긴장·충돌로 볼 수 있고 달리 말하면 ‘나쁜 관행’의 문제로 재서술할 수도 있다. 이런 갈등 상황을 흔히 규범 충돌로 묘사하기도 하는데, 문제시되는 국면이 진정 ‘규범 충돌’인지 여부에 대한 정확한 진단부터 이루어져야 비로소 적절한 해법도 구할 수 있을 것이다. 결론부터 말하면, 이는 ‘규범 충돌’이라기보다는 ‘법원 충돌’이다.

제2장에서 우리는 ‘법원-법규범의 구별’ 논제를 통해 법규범은 법원의 해석 결과임을 확인했다. 제3장에서는 ‘법원으로서의 관행’의 여러 유형

100) Pascale Deumier(박수곤 역), “법원(法源)으로서의 관행”, 저스티스 제139호, 한국법학원(2013).

101) Hans Kelsen(김성룡 역), 규범의 일반이론 1, 규범의 일반이론 2, 아카넷(2016). ; Hans Kelsen(윤재왕 역), 순수법학, 박영사(2018). 참고.

102) 주지하듯이 법규칙들 간의 충돌 경우에는 예외 규정을 둔다거나 ‘신법우선의 원칙’, ‘특별법 우선의 원칙’ 등과 같은 법원칙에 따라 충돌 문제를 해결한다.

103) Ronald Dworkin, “The Model of Rules I”, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, 1978.

을 ‘법원-삼분법’에 대응시키고 그 효력을 <표3>에서 정리했다. 이에 따르면, 실정법규칙은 가장 강한 규범력을 보유한 ‘의무적 원천’의 위상을 갖는다. 반면 ‘나쁜 관행’이나 ‘강한 의미에서의 무의미한 관행’은 설령 시초에는 관행 정식을 통과한 진성 관행이었다 하더라도 평가의 시험대에 오른 시점에는 <표3>의 심사 기준에 따라 ‘나쁜 관행’으로 판정된다. 따라서 그것이 제공한다고 여겨지는 모종의 유인도 ‘허위의 이유’에 불과하며 법해석 과정을 통해 유효한 법원으로서의 효력이 부인된다. 가령 법률 L과 관행 C가 충돌한다면, 이는 일차적으로 두 법원 간의 긴장 상황으로 이해할 수 있지만, 관행 C는 ‘정합성 심사 기준’에 위배되어 법원으로서의 효력이 상실되며, 따라서 ‘법원-법해석-법규범’의 관계식에 따라 최종적으로 도출되는 법규범 N은 법률 L의 해석 결과값이 된다고 볼 수 있다. 드워킨 식으로 말하면, 전해석적 단계에서 일견 두 법원 후보가 대립할 수 있지만 해석 단계에서 관행 C의 법원성은 부인되며, 결국 의무적 법원으로서의 법률 L의 해석을 통해 하나의 법규범 N이 도출되는 것이다. 이러한 정교한 설명을 통해 이른바 ‘관행 항변’의 갖는 법이론적 의미를 이해하고 적절히 대처할 수 있으며, 법적 추론에서 광의의 법해석의 역할과 중요성도 재확인할 수 있다. 그렇게 본다면, 규범 충돌의 가능성을 부정한 켈젠의 견해도 다른 방식으로 유연하게 재해석해 볼 수 있으며, (그는 원천 개념을 거부했지만) 법원론과도 양립 가능할 수 있다.

나. 법학방법론적 해법과 그 한계

법원 간의 세 가지 갈등 상황 중 앞의 두 경우-‘횡적 갈등’ 및 ‘종적 갈등’-에 대한 법이론적 해법은 이미 잘 알려진 바 있다. 예컨대 ‘횡적 갈등’으로서 법규칙 간의 충돌은 ‘전부 혹은 전무 방식’으로 하나의 법규칙이 규범 세계에서 완전히 물러나는 식으로 해결하며, 법원리 간의 충돌은 각 사안에서의 비중과 중요도를 고려하여 형량 작업을 통해 해결한다.¹⁰⁴⁾ 그렇다면 세 번째 상황, 즉 ‘법원으로서의 관행’과 ‘법원으로서의 법규칙’의 충돌 문제는 법학방법론적으로 어떻게 설명하고 대처하는가? 예컨대 카르펜티에와 스팍은 사법 관행인 ‘승인율’이 ‘*Contra legem*’이

104) 법규칙 간의 충돌 및 법원리와 법규칙 간의 충돌 상황의 양상, 특징, 해법 등에 관해 상세한 설명은 이상영·김도균, 법철학, 한국방송통신대학교출판문화원(2011) 제3장. 참고.

될 수 있다는 주장¹⁰⁵⁾을 하는데, 두 가지 점에서 주목할 만하다. 첫째, 사법관행으로서 승인율이라는 법원이 법문언에 반하여 ‘법원으로서의 관행’과 ‘법규칙으로서의 법원’ 간의 충돌 상황으로 읽을 수 있다. 둘째, 이런 상황을 ‘*Contra legem*’, 즉 법률 문언에 반하는 해석이라는 대륙법계의 전형적인 법학방법론적 틀에 의거하여 분석했다는 점이다. 관행이라는 독특한 법원을 둘러싼 특별한 갈등 상황을 기존의 법학방법론적 설명틀 안에 끼워 맞추려는 시도는 어딘지 모르게 작위적이고 부적절해 보이는 면이 있다. 이를 새로운 시각에서 바라볼 수 있는 새로운 언어와 분석틀이 필요하지 않을까? 만약 이 문제를 소위 ‘나쁜 관행’이라는 개념을 경유하게 되면 새로운 접근과 이해가 가능할 수 있다. 또한 기존의 전형적인 법학방법론적 분석과 대응만으로는 그 원인과 해법을 온전히 파악하기 어려운 한계 지점에서 이론과 실천의 상관성 및 그 상호작용의 중요성을 재인식하고 강조하는 데에도 도움이 될 수 있을 것이다.

스칸디나비아 법현실주의의 대표자인 로스(Alf Ross)는 법원 간 충돌 문제에 대한 해결책으로 다른 법원으로의 대체를 주장한다.¹⁰⁶⁾ 가령 관행과 법규칙이 충돌하는 경우 관습법으로서의 법원을 새로이 인정함으로써 해결한다는 것이다. 생각건대, 이런 해법은 유용하지만 세 가지 점에서 한계가 있다. 첫째, 관습법의 외피를 띤 ‘법관법’이라는 비판이 가능하다. 이른바 ‘관습 없는 관습법’과 ‘관습법의 역설’ 현상¹⁰⁷⁾은 법원론의 민주주의적 함의를 파괴할 위험이 있다. 둘째, 이 해법이 실효적이라면, 법원 간 서열이나 위계에 대한 이론적 논의가 선행되어야 한다. 셋째, 만약 관행을 형식적·절차적인, 즉 ‘합법성을 부여하는 사실’로서의 사회적 원천의 면에만 초점을 두지 않고 ‘법적 관행 정식’의 조건(1)을 통해 확인한 그 근거의 가치·목표·원리적 측면까지 고려한다면, 가치나 원리 간의 충돌 부분도 간과할 수 없다. 단순히 ‘다른 법원으로의 대체’라는 손쉬운 처방만으로는 이 문제에 대한 제대로 된 해결이 어려울 뿐 아니라 부작용을 낳을 위험도 있다. 결국 좀 더 입체적이고 다면적인 통합적

105) Mathieu Carpentier and Torben Spaak, 앞의 논문(주35).

106) Alf Ross, *On Law and Justice*, Jakob v. H. Holtermann (ed.), Oxford University Press, 2019.

107) 자세한 설명은 이현경, “법철학에서 관습이 왜 중요한가? 관습의 본질과 법규성에 대한 새로운 이해”, 법철학연구 제24권 제2호, 한국법철학회(2021), 제3장 참고.

접근이 요청되며, 이를 위해서는 근본적으로 관행 이론에 의거한 ‘법원으로서의 관행’ 논제의 특수성과 풍부한 자원을 좀 더 이해할 필요가 있다.

다. ‘나쁜 관행’의 규범적 통제와 그 해결: 다면적·입체적 접근

소위 ‘나쁜 관행’의 시각에서 법원 간 규범적 긴장과 충돌 문제를 새롭게 바라볼 경우, 실천적 차원에서 얻게 되는 통찰 중 하나는 나쁜 관행은 그저 개인의 일탈적 행위나 타락만으로 야기되는 것이 아니며 심층의 사회 구조적인 병폐와 결부된 경우도 많다는 점이다. 일부 고질적 사태는 지배의 문제로 이어져 부정의(injustice) 사안으로 접근할 필요도 있다.¹⁰⁸⁾ 따라서 공동체 전체 차원에서 구조적·문화적·인식적 개선이 이뤄져야 하며, 그 과정에서 다차원적인 법적 추론이 중요한 역할을 한다. 만약 이 문제가 법적 분쟁으로 이어질 경우, 사법부는 사법 추론을 통해 그것의 법원성을 부인하거나 무효화 함으로써 변화를 추동할 수도 있다. 입법부도 관련 법령을 제·개정하는 입법 추론에서 심의를 통해 나쁜 관행 여부를 판정하고, 법제화 과정에서 적절한 방식으로 실천적 변화를 이끌 수 있다.¹⁰⁹⁾ 입법 및 사법적 의사 결정이라는 국가적 권위에 기한 공적 추론을 통한 규범적 통제와 함께 사회문화적 차원에서 인식 개선을 위한 공론화도 필요하다. 시민들도 그 문제의 심각성을 인식·공유하고, 정치적 책임을 이행한다는 자세로 각자의 실천적 추론 과정에 반영하여 해결을 위한 협력에 동참해야 한다. 이미 밝혔듯이, ‘나쁜 관행’은 법원으로서 효력이 없다. 따라서 행위자에게 제공되는 모종의 심리적 압박과 부담은 허위의 이유일 뿐이며 그것에 따를 준수 의무도 당연히 부과되지 않는다는 점에 대한 명확한 인식과 사회적 공감대 공인이 중요하다.

다른 한편, 나쁜 관행 문제의 온전한 해결을 위해서는 관행 규범이 갖는 본질과 결에 맞는 현명한 대처가 요구된다. 말하자면, 나쁜 관행에의 부준수 현상이 광범위하게 확산됨으로써 관행성의 핵심인 일반적 준수 의존성이 소거되고 실효성 상실의 국면에 이르러 ‘약한 의미’에서의 무의미한 관행으로 변모되고, 궁극적으로 관행의 소멸로 이어지도록 하는 것이 바람직하다. 이러한 과정은 관행 질서가 형성·강화되는 방향에서의

108) Frank Lovett(조계원 역), 지배와 정의에 관한 일반이론, 박영사(2019), 105-150면. 참고.

109) 이 주제는 이 글 제4장 사례 분석에서 ‘관행의 법제화’ 문제와 함께 자세히 설명한다.

실천적 추론 방식과 경로를 역으로 밝아가는 것으로, 그 과정에서 국가적 차원에서의 제도적 지원과 협조는 매우 중요하다. 다만 개혁이라는 이름 아래 강제적·강압적인 공권력을 앞세운 국가주의적 처방은 오히려 부작용과 폐단을 낳을 가능성이 있기에 포괄적인 조력자의 위치에 머물 필요가 있다.¹¹⁰⁾ 온전한 해결을 위해 더 중요한 것은 공동체 구성원 모두가 문제해결을 위한 정치적 책임¹¹¹⁾을 이행한다는 태도로 각자의 실천적 추론 안에 반영하여 법실천을 개선하고, 이를 통해 공동체적 문화 규범으로서의 관행 질서의 자정작용이 함께 이뤄질 수 있도록 하는 것이다. 다차원적인 법적 추론의 교호작용을 통한 협업이 무엇보다 중요하다.

IV. 사례 적용 및 분석: 다차원적인 법적 추론과 관행의 실천력

법원으로서의 관행은 법실무에서도 여러 면에서 중요한 역할을 한다. 제3장의 논의를 이어받아 법원 간 충돌 사안을 중심으로 서두에서 제시한 ‘법보다 관행이 더 가깝다?’라는 문제 제기의 현실태를 확인해 본다. 법원으로서의 관행 및 나쁜 관행 문제가 실제 법실무에서 어떻게 다루어지는지를 ‘법의 흠결’ 문제와 ‘(나쁜) 관행의 법제화’라는 논점을 중심으로 구체적인 사례를 통해 살펴본다. 그리고 본 연구의 성과를 적용하여 이론적·실천적 의의를 확인하고 시사점을 도출해 본다.¹¹²⁾

1. 관행과 사법 추론: ‘법의 흠결’ 문제

가. 법의 흠결과 법원으로서의 관행

사법 추론의 장에서 ‘법원-법규범의 구별’ 논제 혹은 ‘법원-법해석론-

110) 박효종 교수는 ‘불의한 관행’이나 ‘비효율적 관행’에 대한 교정자나 개혁자로서 국가의 주도적 역할을 강조하면서 “비관행적인 해결책의 강행”을 주장한다. 박효종, 국가와 권위, 박영사(2001), 382면. 그러나 개혁자로서 국가의 독립적 역할과 역량에는 한계가 있다. 한국의 가정의례준칙의 변천·실패 사례, 미국 금주법의 실패 사례와 같은 다양한 법사회학적 실증례를 참고할 수 있다.

111) Iris Marion Young(김도균·조국 역), 차이의 정치와 정의, 모티브북(2017).

112) 제4장(IV)의 내용은 본 연구의 요지를 구체적인 법적 사례에 적용해 보임으로써 이론의 실천력을 보이기 위한 시도이다. 그런데 지면의 한계상 아쉽지만 여기서는 예시 차원에서 간략히 다룰 수밖에 없겠다. 각 사례에 대한 더 심층적이고 포괄적인 (추가 논점까지 더한) 심화된 분석·논평은 별도의 법철학적 평석 논문을 통해 담고자 한다.

법규범’ 관계식의 실천적 효과가 가장 분명하게 드러나는 경우는 ‘법의 흠결’ 상황일 것이다. ‘법의 흠결’이란 “입법자의 계획에 반하는 불완전성”을 뜻한다. 법의 흠결 확정은 사실상 법의 해석과 동시에 이루어지게 되며, 카나리스가 지적한 바와 같이 법의 흠결 확정과 흠결의 보충은 함께 이루어진다.¹¹³⁾ 법의 흠결에는 ‘명시적 흠결’과 ‘은폐된 흠결’이 있다. ‘명시적 흠결’은 달리 말하면 입법 공백을 뜻하며, 해당 사안에 규율할 법규칙이 명백히 존재하지 않는 경우다. 예컨대 형법상 불능미수의 중지가 이에 해당한다. ‘은폐된 흠결’은 해당 사안에 적용할 법규칙은 존재하지만 이를 있는 그대로 적용하게 되면 불합리하거나 부당한 결론이 도출되는 경우를 뜻한다.¹¹⁴⁾ 교과서적 설명에 따르면, 법획득의 방법으로 ‘법발견’과 ‘법형성’을 개념적으로 구분하고, 법형성이 이뤄지는 법흠결의 보충 방법으로 유추·목적론적 축소·법원리에 의한 법보충의 세 가지 방법이 제시된다.¹¹⁵⁾ 만약 ‘법원으로서의 관행’ 논제를 수용한다면, 법흠결 보충에 관한 기존 논의에 어떤 기여를 할 수 있을까? 법관에게 허용된 해석 범위를 넘은 법형성적 활동에 대해 과도한 사법 재량이나 사법 통치라는 비평¹¹⁶⁾에서 자유로우면서도 유연하게 응답할 수 있는 대안적 접근은 없을까? 또한 하트-드워킨 논쟁 이래 ‘해결하기 어려운 사안’과 ‘해결하기 쉬운 사안’이라는 이분법적 도식¹¹⁷⁾도 법원론의 관점에서 새

113) 김영환, 법철학의 근본문제 제3판, 홍문사(2012), 257면.

114) 다만 여기서 소개한 ‘법의 흠결’ 개념과 그 설명은 정확히 말하면 ‘법률의 흠결’ 혹은 ‘법규칙의 흠결’로 재서술할 수 있다. 만약 드워킨과 같이 ‘법’과 법규칙으로서의 ‘법률’을 동일시 하지 않고 법원리로서의 법규범 유형을 주장하는 법원리주의자들의 경우에는 ‘법의 흠결’과 ‘법률의 흠결’을 개념적으로 구별할 것이다.

115) 김영환, 앞의 책(주11), 259면. 여기서 법원리를 법보충 수단으로 배치한 것은 이러한 설명법이 법실증주의적 관점에 따른 것임을 알 수 있다.

116) 법관의 법형성 및 사법 적극주의에 대한 비판적 견해로는, 조홍식, 사법통치의 정당성과 한계 제2판, 박영사(2010). 등 참고. 저자는 “실정법 및 그 해석의 대부분이 도덕적 조정문제를 해결하는 규칙이라는 전제하에, 그 ‘조정 규칙’을 제정하는 권위는 각 국가기관, 즉 입법부·행정부·사법부에 그 각 기관이 가진 민주적 정당성의 크기만큼 비례적으로 할당되어야 한다”고 강조하면서 ‘비례입헌주의’를 주창한다. 조홍식, “勿輕視政治 - 比例立憲主義를 主唱하며”, 서울대학교 법학, 제49권 제3호, 서울대학교 법학연구소(2008).

117) 이분법을 넘어 최근의 삼분법 시도를 소개하고 있는 글로는, 공두현, “판결하기 어려운 사건, 쉬운 사건, 보통의 사건 - 법적 추론과 법적 논증의 영역들”, 저스티스 제192호, 한국법학원(2022). 다만 필자는 ‘이분법’이건 ‘삼분법’이건, 그러한 구분을 이끄는 ‘해결하기 어렵다’-(‘보통이다’)-‘쉽다’라는 기준 자체부터 의문을 제기할 필요가 있다고 생각한다.

롭게 재조명해 볼 수 있지 않을까? 우리는 <표4>에서 원천의 규범력 정도에 따라 ‘의무적 원천’, ‘기각 가능한 원천’, ‘허용적 원천’의 세 유형을 구분했다. ‘법원-삼분법’에 따르면, 법원 충돌 상황에서는 ‘기각 가능한 원천’과 ‘허용적 원천’이 관련되고, 기존 설명법에 따른 ‘법의 흠결’ 사안에서는 주로 ‘허용적 원천’의 역할이 강조된다. 가드너도 법 흠결 사안에서 흠결 보충의 주역으로서 허용적 원천에 관하여 상세히 논한다.¹¹⁸⁾

나. 사례 적용: 대법원1998.4.23.선고 95다36466 판결(‘발행지 기재 없는 어음의 효력’) 재고(再顧)

법흠결의 보충, 즉 사법부의 법형성의 정당화 가능성이 문제된 사례 중 하나로 ‘발행지 기재 없는 어음 판결’(대법원 1998. 4. 23. 선고 95다36466)이 있다. 이 판결은 법형성에 대한 대립적 견해가 표출된 대표적인 사안으로, ‘법문에 반하는 법형성’으로서 ‘목적론적 축소’로 설명하는 입장과 법문의 가능한 의미 안에서 이루어진 ‘축소해석’이라는 견해 대립이 있다. 어느 쪽이든, 법의 흠결 사안에 대한 법관의 법형성의 범주 안에서 이 문제를 다룬다는 것을 알 수 있다.¹¹⁹⁾ 이러한 기존 접근법은 이 사건이 갖고 있는 특별함, 즉 사법 추론에서 ‘법원으로서의 관행’의 역할 및 효력과 관련한 중요한 논점과 논의의 계기를 제공한다는 점을 포착하지 못한다. 당시 어음법 제1조는 어음의 요건 중 ‘발행지 기재’도 명시하는데, 국내 어음 거래의 현실은 발생지 기재가 누락 된 채로 거래되는 경우도 적지 않았다. 즉 명백히 법문에 반하여 발행지 기재 없는 어음의 효력 인정 여부가 주된 논쟁점이었다. 대법원 ‘다수의견’은 다음과 같다.

118) John Gardner, “Concerning Permissive Sources and Gaps”, *Oxford Journal of Legal Studies* 8, 1988.

119) 국내 법철학계에서 법관의 법형성에 관한 연구로는, 양천수, “법률에 반하는 법형성의 정당화 가능성”, 법과사회 제52호, 법과사회이론학회(2016). ; 양천수, “법적 안정성과 해석”, 법학논총 제28권 제2호, 국민대학교 법학연구소(2015). ; 이계일, “법관법 변경의 효력범위설정에 대한 비판적 탐구”, 법철학연구 제24권 제1호, 한국법철학회(2021). ; 이계일, “법관의 법형성의 체계구성에 관한 탐구”, 법과사회 제59권, 법과사회이론학회(2017). ; 이계일, “20세기 전반기 법학방법론에 있어 흠결이론의 전개 양상에 대한 탐구”, 법철학연구 제26권 제2호, 한국법철학회(2023). ; 이계정, “법관에 의한 법형성의 실제, 한계와 입법적 사항의 문제”, 저스티스 제205호, 한국법학원(2024). ; 임미원, “법관의 법형성에 관한 일고찰”, 공법연구 제41권 제1호, 한국공법학회(2012). ; Karl Larenz(김영환 역), “방법론적인 문제로서 법관의 법형성”, 법학논총 제25집 제1호, 한양대학교 법학연구소(2008). 등 참고.

어음에 있어서 발행지의 기재는 발행지와 지급지가 국토를 달리하거나 세력을 달리하는 어음 기타 국제어음에 있어서는 어음 행위의 중요한 해석 기준이 되는 것이지만 국내에서 발행되고 지급되는 이른바 국내 어음에 있어서는 별다른 의미를 가지지 못하고, 또한 일반의 어음거래에 있어서 발행지가 기재되지 아니한 국내어음도 어음요건을 갖춘 완전한 어음과 마찬가지로 당사자 간에 발행·양도 등의 유통이 널리 이루어지고 있으며, 어음 교환소와 은행 등을 통한 결제 과정에서도 발행지의 기재가 없다는 이유로 지급거절됨이 없이 발행지가 기재된 어음과 마찬가지로 취급되고 있음은 관행에 이른 정도인 점에 비추어 볼 때, 발행지의 기재가 없는 어음의 유통에 관여한 당사자들은 완전한 어음에 의한 것과 같은 유효한 어음행위를 하려고 하였던 것으로 봄이 상당하므로, 어음면의 기재 자체로 보아 국내어음으로 인정되는 경우에 있어서는 그 어음면상 발행지의 기재가 없는 경우라고 할지라도 이를 무효의 어음으로 볼 수는 없다.¹²⁰⁾

대법원 ‘다수의견의 보충의견’은 법관의 법형성에 대한 정당화 논증을 다음과 같이 제시한다.

법률을 해석·적용함에 있어서는 법률규정의 문언의 어의(語義)에 충실하게 해석하여야 함이 원칙임은 말할 것도 없다. 그러나 법률 제정 당시에 입법자가 전혀 예상하지 못하였기 때문에 법률로 규정되지 않았거나 불충분하게 규정된 경우가 있을 수 있고, 이 경우에도 법원은 재판을 하지 않으면 아니 되므로 법원의 법형식적 활동이 개입될 수밖에 없다. 뿐만 아니라 법률에 명문의 규정이 있는 경우에도 시대가 바뀌고 사회가 달라짐에 따라 법과 실제 생활과의 사이에 불가피하게 간격이 생길 수 있으며, 이 때에 만일 명문규정의 엄격한 적용만을 고집한다면 그것은 법적 안정성이 유지될지는 모르나 사회생활의 유동·발전에 대한 적응성을 결여하는 중대한 결함이 생길 수 있으므로 이를 실제 생활에 부합하게 해석할 사회적 필요가 생기게 된다. 이와 같은 경우 법원은 형식적인 자구 해석에 얽매일 것이 아니라 그 법이 구현

120) 대법원 1998.4.23.선고 95다36466 전원합의체 판결요지 중 다수의견 (밑줄·강조는 필자)

하고자 하는 입법정신이 무엇인가를 헤아려서 그 입법정신을 실현하는 방향으로 법의 의미를 부여하여야 하며, 그 실현을 위하여 필요한 한도 내에서 명문규정의 의미를 확대해석하거나 또는 축소·제한해석을 함으로써 실질적인 법형성적 기능을 발휘하여야 할 것이다. (...) 사법(私法)은 국민의 사생활관계를 규율하는 법률이므로, **국민의 사법적 거래의 관행**을 뒷받침하여 그 거래를 원활하게 유지하도록 하는 것은 사법의 본래의 영역이며 사명에 속하는 것이다. **국민의 대부분이 명문규정에 별 의미가 없는 것으로 생각하고 그 규정에 맞지 아니한 행위도 유효한 것으로 믿고 그에 따라 행동하는 경우에**, 그것이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위배되어 무효로 되는 등 특별한 사정이 없다면 법원만이 그 행위를 무효로 보아 국민의 거래행위를 제약할 것은 아니라 할 것이다. (...) **실제 어음거래의 관행**을 살펴보면, 다수의견에서 본바와 같이 일반의 어음거래에 있어 발행지가 기재되지 아니한 국내어음도 어음요건을 갖춘 완전한 어음과 마찬가지로 당사자 간에 발행·양도 등의 유통이 **널리 이루어지고 있고**, 어음교환소와 은행 등을 통한 결제 과정에서도 **발행지의 기재가 없다는 이유로 지급거절됨이 없이 발행지가 기재된 어음과 마찬가지로 취급되고 있으므로**, 국내어음에 있어서 발행지의 기재가 없다고 하여도 어음의 유통증권으로서의 **실제 기능에 아무런 영향이 없다** 할 것이다. (...) 만일 발행지의 기재가 없다는 이유만으로 이러한 어음을 무효로 한다면 이는 어음상의 의무자로 하여금 채무의 이행을 지연하거나 면탈하는 구실을 주게 되어 어음채무자에 의하여 악용될 소지가 많다고 본다. 왜냐하면 실제의 거래에서는 (...) 발행지의 기재가 없어도 완전한 어음에 의한 것과 같은 유효한 어음행위를 하려는 의사를 가지고 발행지를 보충하지 아니한 채 어음을 수수하는 것이 **보통임에도 불구하고**¹²¹⁾

반면, 대법원 ‘반대의견’은 발행지 기재 없는 어음의 효력을 부인하고자 한다. 그리고 다수의견의 입장을 법관의 정당화되지 않은 과도한 법형성 내지 법률 수정이라고 규정하면서 비판한다.

121) 대법원 1998. 4. 23. 선고 95다36466 전원합의체판결 중 대법관 이돈희·대법관 신성택·대법관 이용훈의 다수의견에 대한 보충의견 중. (밑줄·강조는 필자)

재판할 사항에 대하여 적용할 법규가 있고 그 의미 내용 역시 명확하여 달리 해석할 여지가 없는 경우에는 다른 것을 다르게 취급하여야 한다는 정의의 요청(이른바 목적론적 축소해석의 경우) 또는 합헌적인 해석의 요청(이른바 헌법합치적 해석의 경우)에 의하여, 그 법규의 적용 범위를 예외적으로 제한하여 해석할 필요가 있는 등의 특별한 사정이 없는 한, 설사 명문의 규정이 거래의 관행과 조화되지 아니하는 점이 있다고 하더라도, 법원으로서서는 모름지기 국회의 입법 작용에 의한 개정을 기다려야 할 것이지 명문의 효력규정의 적용 범위를 무리하게 벗어나거나 제한하는 해석을 하여서는 아니 될 것인바, 어음법은 발행지의 기재가 없는 어음에 관하여 그 효력이 없다고 명문으로 규정하고 있는 한편, 이 명문의 규정에 관하여는 정의의 요청 또는 합헌적인 해석의 요청에 의하여 그 적용 범위를 예외적으로나마 제한하여 해석할 만한 아무런 특별한 사정이 있다고 할 수 없으므로, 다수의견과 같이 위 어음법의 명문규정이 이른바 ‘국내어음’에는 적용되지 아니한다고 하는 것은 법원이 어음법에도 없는 단서 조항 즉 ‘발행지에 관하여 국내어음의 경우에는 그러하지 아니하다.’라는 규정을 신설하는 셈이고, 이는 명문의 규정에 반하는 법형성 내지 법률수정을 도모하는 것으로서 법원의 법률해석권의 범위를 명백하게 일탈한 것이라는 비난을 면하기 어렵다.¹²²⁾

또한 ‘반대의견’은 어음거래 관행의 존재 자체를 부인하는데, 설사 인정하더라도 강행법규인 어음법규정을 개폐할 효력은 없다고 강조한다.

다수의견이 주장하는 거래관행이나 당사자의 의사는 법률행위의 해석의 논거로 될 수 있을지언정 법률행위 등을 규율 대상으로 하는 법규, 그 중에서도 효력규정인 법규의 해석 논거로 삼는다는 것은 법리에 전혀 맞지 아니한다. 특히 위와 같이 어음법이 개정될 때, 사회·경제적 여건의 변화나 국내·외 상거래관행이 있었다고 보지 아니하였기 때문인 것으로 보인다. (...) 발행지란이 보충되지 아니한 채 지급제시된 어음에 대하여 배서인이 이를 결제하거나 소구책임을 지는 것이 어음거래의 관행에 이른 것이라고 볼 만한 아무런 자료나 근거가 없을뿐더러 가사 그러한 관행이 있다고 가정하더라도, 이러한 관행이 강행법규인 어음법에

122) 대법원 1998.4.23.선고 95다36466 전원합의체판결 요지 중 반대의견 (밑줄·강조는 필자)

저촉된다면 이를 허용하여서는 아니 될 것이다. 만약 다수의견과 같이 이를 허용한다면 이는 관행에 의하여 강행법규를 개폐하는 결과를 초래하게 되는 것이고, 이는 성문법주의의 법체제하에서는 도저히 용납될 수 없는 것이다. (...) 입법론과 해석론을 혼동한 것이라고 (...) 다수의견이 특별한 상황의 변화도 없이, 갑자기 성문법주의의 법체제하에서 강행법규적 성격의 법규이며 효력규정인 어음요건에 관한 명문 규정을 정면으로 거스르는 결론을 끌어내려는 것은 부당하다고 아니할 수 없으며, 사실인정의 문제를 법률해석의 문제로 보거나 법률해석의 논거가 될 수 없는 관행과 당사자의 의사를 무리하게 끌어들이 발행지의 기재가 없는 어음도 유효하다고 하는 것은 납득할 수가 없다.¹²³⁾

다. 분석 및 논평

이 판결은 ‘거래 관행’의 존중을 이유로 실정법에 반하여 형성된 관행의 효력을 인정함으로써 성문법의 효력을 무력화시킨 사안이다. ‘법원으로서의 거래 관행’과 ‘법원으로서의 법률’ 간의 규범적 갈등 상황에서 결국 관행의 효력이 법적으로도 승인된 실증 예로 볼 수 있다. 이 판결은 법학방법론 영역에서 고전적 사례라 할 만큼 중요하게 다뤄진다. 그런데 국내 대부분의 문헌은 이 사안을 소개할 때 법관의 법형성 및 그 정당화와 관련한 문제로 논점을 한정한다.¹²⁴⁾ 그러나 ‘관행 이론’과 ‘법원론’의 관점에서, 그리고 ‘법원으로서의 관행’이라는 논제를 중심으로 이 사례를 바라본다면 우리는 좀 더 풍부하고도 유의미한 분석과 논평을 할 수 있을 것이다. 올바른 분석과 진단은 적절한 처방의 필수 전제이기에 해결의 측면에서도 이러한 시도는 중요하다고 볼 수 있다.

이 사례에 법학적 관행 이론과 법원론을 적용해 보면, 적어도 다음의 두 논변 -‘법원 충돌 논변’과 ‘나쁜 관행 논변’-이 가능하겠다. 첫째, 강화 조건을 충족한 ‘강력한 관행’과 ‘실정법령’ 간의 충돌 상황으로 볼 수 있다. 법원론의 시각에서 보면, 이는 두 개의 ‘의무적 원천’ 간의 갈등 상황으로 재서술할 수 있는데, 대법원 다수의견은 법원으로서의 관행이 실정법을 무력화하는 그 파기적 효력을 확인시켜 준다. 둘째, ‘발행지 기

123) 대법원 1998.4.23. 선고 95다36466 전원합의체판결 중 대법관 윤관·대법관 최종영·대법관 천경송·대법관 정귀호·대법관 김형선·대법관 이임수의 반대의견 (밑줄·강조는 필자)

124) 김정오·최봉철·김현철·신동룡·양천수, 법철학: 이론과 쟁점 제3권, 박영사(2022), 309-311면.

재 없는 어음’은 발행지 기재를 명문으로 요하는 어음법 제1조 규정에 반하는 내용으로 형성되었기에 ‘나쁜 관행’의 예로 설명할 수도 있다. 즉 ‘나쁜 관행 논변’에 따라 분석할 수 있다. 하나씩 단계적으로 살펴보자.

1) ‘법적 관행 정식’ 및 ‘강화 조건’

우선 이 사건에서는 어음법 규정에 반하여 형성되어온 ‘거래 관행’이 등장한다. 그렇다면 논의의 첫 단계는 판례에서 말하는 국내어음의 경우 발행지 기재를 하지 않고 유통해 온 이른바 ‘거래 관행’[이하 ‘거래 관행R’로 표기]이 진정한 의미에서의 관행인지를 따져볼 필요가 있다. 반대의견은 그런 관행의 존재 자체를 부인하고 있기에 특히 이 문제는 첫 관문으로 중요한 의미가 있다. 앞서 <표1>에서 우리는 유효한 진성 관행이 성립·존재하기 위한 6가지 조건을 제시했다. 우선 각각의 조건을 충족하는지를 따져보자. ‘거래 관행R’은 ‘거래의 안정’이라는 목표나 가치를 전제로 하는 협력적 실천[조건(1)]으로, 국내 어음 거래의 현실에서 많은 사람들이 그렇게 행하여 왔기에 그러한 일반적 준수를 전제로 대부분의 사람이 그 관행을 준수해 왔다.[조건(2)(3); ‘일반적 준수의존성’] 또한 어음법 1조가 어음의 효력 발생 조건으로 발행지 기재를 요한다는 점을 뒤집어 보면, 반드시 그 ‘거래 관행R’이 되어야 할 필요는 없다는 점을 당연히 추론할 수 있다.[다수의견 중, “발행지의 기재가 없다고 하여도 어음의 유통증권으로서의 실제 기능에 아무런 영향이 없다”]. 특히나 R은 어음법 명문 규정에 반하여 형성된 질서이기에 만약 ‘거래의 안정’이라는 목표를 달성하기 위한 다른 내용을 담은 등가의 R*가 일반적으로 준수되는 상황이 생긴다면 R은 R*로 변경될 수도 있다.[조건(4); ‘임의성’] 또한 이는 “그것이 만약 분쟁화되었을 때 관계인의 직접적인 법적 권리·의무 관계로 전이될 가능성이 큰 경우[=‘전이된 법적 관행’, 조건(5)]로 볼 수 있다. 따라서 ‘거래 관행R’은 ‘법적 관행 정식’의 모든 조건을 충족한 진성 관행으로 인정할 수 있다. 이러한 관행이론적 분석에 따르면, 한편으로는 ‘다수의견’이 말한 관행 성립에 관한 주장[“발행지의 기재가 없다는 이유로 지급거절됨이 없이 발행지가 기재된 어음과 마찬가지로 취급되고 있음은 관행에 이른 정도인 점”; “널리 이루어지고 있고”; “발행지의 기재가 없다는 이유로 지급거절됨이 없이 발행지가 기재된 어음과 마찬가지로 취급되고 있으므로”]에 대한 강화 논변으로, 다른 한편으로 ‘반대의견’의 그러한 관행이 존재하지 않았다는 반박[“발행지란이 보충되지 아니한 채 지급제시된 어음에 대하여

배서인이 이를 결제하거나 소구책임을 지는 것이 어음거래의 관행에 이른 것이라고 불만한 아무런 자료나 근거가 없을뿐더러”]은 타당하지 않음을 논증할 수 있다.

다음으로, ‘거래 관행 R’은 관행의 ‘강화 조건’도 충족한다. 즉 사실적·규범적으로 강력한 관행을 만드는 강화 조건 중 ‘①공통 지식과 공식적 표명’ 및 ‘②시간적 지속과 반복’ 조건을 충족하였기에 ‘강력한 관행’으로 그 위상이 승격된다. 이를 ‘법원론’의 관점에서 보면 <표4>에 따라 ‘기각 가능한 원천’이나 ‘의무적 원천’으로 특징지을 수 있다. 이를 다차원적인 법적 추론의 맥락에서 재저술해 보면, 거래 당사자의 실천적 추론에서 강한 규범력을 발휘하고 사법 추론에서도 다수의견과 같이 ‘거래 관행 R’의 파기적 효력을 인정하는 결론에 이르렀다고 분석할 수 있다. 반면, 반대의견의 시각에서 보면, 판결문에서와 같이 관행의 존재 자체를 부인하거나 설령 그 존재를 인정하더라도 법관의 법형성의 정당성을 부인하는 전형적인 법학방법론적 논증에만 집중하기보다는 ‘법원 충돌’이나 ‘나쁜 관행’ 논변을 통해 그 효력을 부인하는 전략을 시도했으면 더 좋지 않았을까 생각해 본다. 이 논점은 다음 항에서 이어간다.

2) ‘법원 충돌’ 및 ‘나쁜 관행’ 논변

이 사건의 핵심 쟁점이 된 어음법 제1조와 ‘거래 관행R’의 충돌 문제를 살펴보자. 이는 어음법 제1조와 그 명문에 반하는 내용으로 형성·발전해 온 ‘거래 관행R’이라는 두 법원 간의 갈등 상황으로 해석할 수 있다. 여기서 두 법원 간의 위계나 규범력의 정도 차가 문제 된다. 판결문에서도 여러 차례 반복되듯이 성문법체계 국가에서 법령은 ‘의무적 법원’의 전범(典範)이다. 반면 ‘거래 관행R’은 강화 조건을 충족한 강력한 관행으로 <표4>에 따르면 ‘기각 가능한 원천’이나 ‘의무적 원천’의 위상을 갖는다. ‘거래 관행R’의 법원론적 지위를 일의적으로 확정하기 어려운 이유는 관행 질서의 작동은 본질상 복잡적·혼종적일 뿐만 아니라 주변 환경과 맺는 관계구조적 측면에 상당히 의존하기 때문이다. 결국 개별자(token)로서 존재하는 구체적인 각 관행의 특수성과 여건에 따라 그 규범력의 종류와 정도를 판정할 수밖에 없는 측면이 있다. 그렇다면 이 사건에서 ‘거래 관행R’과 어음법 제1조 간의 갈등 상황은 ‘기각 가능한 원천’과 ‘의무적 원천’의 사이 어딘가에 위치하는 ‘거래 관행R’과 ‘의무적 원천’인 어음법령 사이의 ‘형적 갈등’ 상황으로 진단하면 되는 것일까? 아니면, 성문

법주의라는 법체계 특성에 따른 강력한 외적 논거를 근거로 형식적 합법성에 기초한 법규칙의 효력 우위를 주장할 것인가? 바로 이 지점에서 ‘반대의견’과 ‘다수의견’ 및 ‘보충의견’이 대립한다고 볼 수 있다. 생각건대, 법원론의 관점에서 보면 ‘반대의견’은 ‘거래 관행R’이 현실적으로 강한 규범력을 발휘하고 있긴 하지만 성문법 체계라는 특징과 ‘법 그 자체의 안정성’ 확보라는 이념에 비추어 그 위상을 ‘가각 가능한 원천’으로 규정하는 듯하다. 반면, ‘다수의견’은 실효적인 거래 실정에 대한 더 깊은 존중과 ‘법[판결]을 통한 사회 안정’이라는 이념에 무게감을 두고 ‘거래 관행R’의 위상을 ‘의무적 원천’으로 판정한 것으로 볼 수 있다.

또 하나 흥미로운 점은, 양측 모두 ‘안정성’ 가치를 내세운다는 점이다. 법규칙의 우위를 주장하는 반대의견은 전통적 법이념으로서 ‘법적 안정성’을 전면에 내세우면서 법실증주의의 면모를 보여준다. 다수의견의 보충의견은 ‘거래의 안정성’이라는 현실에 대한 존중을 강조하면서 사회적 차원의 또 다른 ‘안정성’을 중요한 가치 기반 논거로 제시한다.

다음으로, ‘나쁜 관행’ 논증의 면에서 판결문에서 제시된 여러 의견을 새로운 관점에서 재해석해 보자. 앞서 <표2>와 <표3>을 통해 소위 ‘나쁜 관행’과 ‘무의미한 관행’의 구별, ‘나쁜 관행’의 요건과 내용, 효력을 논하였다. 이 사안에서는 국내 어음의 경우 발행지를 기재하도록 명하는 어음법 제1조 규정에 명백히 반하는 질서로서 형성된 ‘거래 관행R’은 나쁜 관행의 심사 기준 중 ‘정합성 심사’에 위배된다. 즉 “공동체 P의 상위 규범질서 및 인접/연합질서와의 원리 및 체계 정합성을 현저히 해치지 않는다.”는 요건에 반하여 ‘나쁜 관행’으로 판정할 수 있다. 물론 ‘거래 관행R’은 강화 조건까지 충족하여 일견 ‘의무적 원천’에까지 이른 강한 구속력을 갖는 추정적 효력을 인정받을 수 있었지만, ‘관행 존중의 원칙’과 ‘추정적 효력 테제’의 임계점을 넘어 그 추정력이 박탈되고 따라서 <표4>에 따라 ‘효력 없는 원천’이 된다는 해석도 가능하다. 만약 이러한 ‘나쁜 관행 논변’을 강하게 밀고 나가면 ‘반대의견’의 논거를 보강할 수도 있다. 반면 ‘다수의견’이나 ‘보충의견’의 시각에서 보면 세 가지 가능성을 말할 수 있다. 첫째, ‘거래 관행R’이 추정적 효력 테제의 임계점을 넘지는 않아서 여전히 효력이 인정된다고 주장할 수 있다. 둘째, ‘나쁜’의 의미를 <표3>과는 달리 일상 용례와 같이 ‘도덕적 의미’로 한정하여 ‘나쁜 관행’이 아니라고 평가할 수 있다. 셋째, 질서유지와 ‘거래 안정’이라는 가치를 이념 차원으로까지 승격시켜서 현재의 법적 사태의 정도를 비교하되 ‘거래 관행R’을 존중하는 것이 오히려 전체 법질서의 원리적 정합성[정합성 심

사]을 실현하는 방법이라는 주장도 생각해 볼 수 있다.

이 판례를 둘러싸고 학계나 실무에서 많은 갑론을박이 있지만, 대체로 비판적 평가가 주를 이룬다. 이런 상황에서 ‘법원으로서의 관행’ 문제에 기초한 새로운 논변 개발은 사안의 본질과 실제에 대한 풍부한 이해를 얻기 위한 새로운 시각과 자원을 제공할 수 있으며, 적절한 진단과 처방을 제시하는 데에도 도움이 될 수 있다. 당시 실무 일각에서는 ‘다른 법원으로서의 대체’, 즉 새로운 관습법의 존재를 승인하는 방식으로 논증을 구성해야 했다는 견해도 있었다고 한다.¹²⁵⁾ 이런 접근은 법원 간의 규범력 ‘형량’의 방법 대신 ‘대체’라는 간편한 표현을 사용하고 있긴 하지만, 기본적으로 ‘법문에 반하는 법형성과 그 정당화’라는 전형적인 법학방법론적 논의 틀을 넘어 법원론에서의 통찰을 적극 참고한 것으로 볼 수도 있다. 한 걸음 더 나아가, 관행을 ‘연성법(soft law)’의 이름으로 재서술한다면, 이 사안에서 미래법모델로써 연성법의 가치를 인정하고 그것의 유연한 현실 대응력에 기반한 기능적 실효성을 강조하는 논변도 생각해 볼 수 있다. 그 경우 ‘반대의견’은 연성법의 규범적 통제 범위나 한계를 근거로 새로운 정당화 논증을 보강할 수도 있을 것이다. 어느 경우라도 ‘법원으로서의 관행’은 본질상 강고한 형태의 국가법과 같은 의무적 원천이라기보다는 연성법으로 볼 수 있기에, 법원론과 관행 이론의 결합 안에서 발전시킬 수 있는 대안적 논변으로 볼 수 있다.

2. 관행과 입법 추론: ‘관행의 법제화’ 문제

가. ‘관행의 법제화’: 의미 · 방식 · 유형

‘법원으로서의 관행’은 입법 추론의 영역에서도 중요한 역할을 한다. 두 가지 차원에서 접근할 수 있다. 첫째, ‘무엇을 법제화할 것인가’와 관련하여, 진성의 규범적 관행은 입법 추론 과정에서 강력한 규범적 자원으로서 민주적 법원(法源)으로 기능한다. 이를 ‘관행의 법제화’라고 불러보자. 관행의 법제화 문제는 시간 축을 기준으로 놓고 말하면 ‘법제화까지’와 ‘법제화 이후’를 나누어서 논해볼 수 있다. 또한 관행의 법제화 방식과 메커니즘에 관한 내용도 입법 추론의 맥락에서 중요한 논점이 될 수 있다. 둘째, 이른바 ‘나쁜 관행’의 경우, 한편으로는 그것의 법제화 방향의 문제가, 다른 한편으로는 법제화 이후 실효적 기능화 여부에 대한 평가의 문제를 논할 수 있다. 이하에서

125) 당시 재판 현장에서 이런 소수 견해가 있었음을 알려주신 김대휘 변호사님께 감사드립니다.

는 입법 추론 영역에서 ‘법원으로서의 관행’의 법제화를 해명할 수 있는 이론적 토대를 마련한 후에, 구체적인 사례로서 ‘권리금 관행의 법제화’ 및 ‘사납금제의 역방향 법제화’ 사례에 적용하여 상세히 검토하고자 한다.

목시적인 규범적 질서이자 법원으로서의 관행은 입법 추론을 통해 실정법으로 공식화될 수 있다. 마머(Andrei Marmor)는 관행의 제도적 체계화를 두 방식으로 설명하는데, 이를 간단히 표로 정리해 본다.¹²⁶⁾

	입법적 체계화	백과사전식 체계화
주된 역할	관행의 내용을 결정 · 수정함	관행의 내용을 보고 · 지칭함
성공 시, 관행성의 유지 여부	관행성 소멸	관행성 유지
제도적 규칙과의 관계	관행을 대체함	관행적 규칙은 유지됨
		사전, 문법책

〈표5〉 입법 추론에서 관행의 법제화 방식

그런데 위의 〈표5〉에서 제시된 관행 법제화의 두 방식은 입법기술적인 면에서 그 과정과 특징은 잘 담아내고 있지만, 실질 · 내용적인 측면이나 가치 · 방향성의 면에서는 아무런 설명도 제공하지 못한다. 그러나 우리가 법원으로서의 관행과 실정법의 상호관계를 고민할 때 실제 법실무에서 난제로 인식되는 것은 ‘나쁜 관행’의 법제화 문제일 수 있음을 상기해 보자. 따라서 이 문제까지 포괄할 수 있는 추가적인 이론적 논의가 보충될 필요가 있다. 즉 법제화의 방향 문제이다.

입법 추론을 통해 법원이 법제화되는 유형에는 ‘순방향(+) 법제화’와 ‘역방향(-) 법제화’로 구분할 수 있다. 첫째, ‘순방향(+) 법제화’는 기존 관행의 내용을 있는 그대로 반영하는 것으로, 법 제정 기관의 공식적인 법적 승인을 통해 공식적 법체계 안에서 ‘의무적 원칙’으로 승격되는 사태를 말한다. 사회에서 이미 규

126) Andrei Marmor, *Social Conventions*, Princeton University Press, 2009, pp.50-52. 이 표에서 ‘입법적 체계화’ 및 ‘백과사전식 체계화’의 의미에 대해서는 아래 사례 분석 과정에서 설명한다. 마머는 조정 관행과 구별되는 또 다른 관행 유형으로 ‘구성적 관행’을 제안하고, 표층 및 심층 관행도 제시하면서 관행 그 자체에 관한 연구에 크게 기여했다. 마머의 관행 이론에 관한 대표 문헌은, Andrei Marmor, “On Convention”, *Synthese*, Vol. 107, No. 3, 1996. ; Andrei Marmor, *Positive Law and Objective Values*, Oxford University Press, 2001. ; Andrei Marmor, *Social Conventions*, Princeton University Press, 2009. ; Andrei Marmor, *Foundations of Institutional Reality*, Oxford University Press, 2022. 등 참고.

법력을 발휘하고 실효성을 획득하여 ‘살아있는 법’으로 기능하고 있는 법원을 제도적 체계화를 통해 공식성을 부여함으로써 공적 권위를 승인하는 것이다. 법사상사적으로 보면, 이는 ‘티보-사비니 논쟁’으로 대표되는 근대 법전편찬을 둘러싼 19세기 초 독일에서의 역사법학과와의 논쟁¹²⁷⁾과도 관련된다. 둘째, ‘역방향(-) 법제화’는 문제적인 어떤 관행 질서를 근본적으로 변혁·근절하기 위한 방법으로, 기존 관행 규칙을 금하는 내용으로 법제화하는 것이다. 대표적으로, 소위 ‘나쁜 관행’의 경우 그것의 근절이나 폐지, 혹은 혁파를 위해 ‘역방향 법제화’라는 매우 강력한 제도적 방책을 동원할 수 있다. 이하에서는 최근 한국 사회에서 ‘관행의 법제화’로 볼 수 있는 대표적인 예로 ‘권리금’과 ‘택시 사납금’ 제도를 중심으로 이 문제를 입체적으로 다뤄보고자 한다.

나. 사례 분석 및 논평 1: ‘권리금 관행’의 법제화

우리 사회에서 관행의 법제화에 관한 전형을 보여주는 일종의 ‘완성형’ 사례로는 권리금 제도를 들 수 있다. 오랜 기간 강력한 관행으로 존속해 온 ‘권리금 관행’이 상가임대차보호법의 개정을 통해 ‘권리금 계약’으로서의 법적 위상을 부여받고 법제화된 사안을 말한다. 즉, 기존에 비공식적 질서로 유지되어 온 권리금 관행이 2015년 상가건물임대차보호법 개정을 통해 권리금에 관한 규정¹²⁸⁾ 신설을 통해 공식적인 법체계 안으로 편입된 것이다. 그런데 법제화의 방식과 관련해서 보면, 이 사례는 기존 관행 질서의 내용을 있는 그대로 기록하듯 반영하는 ‘백과사전식 체계화’라기 보다는 어느 정도의 수정·보완 작업을 거쳐 법제화하는 ‘입법적 체계화’의 예로 볼 수 있다. 왜냐하면 과거 권리금 관행은 시장에서의 조정 문제 해결을 위한 해법으로 형성된 조정 관행으로서의 기능적 가치가 인정되지만, 다른 한편으로는 ‘악관행’이라는 비판이 쇄도할 만큼 많은

127) 임미원, “근대 법전편찬의 사상적 기초”, 법학논총 제40권 제1호, 한양대학교 법학연구소(2023). ; 김형석, “역사법학과와 19세기초 독일 법전화 논쟁이 오늘날의 사법에 주는 시사점”, 법학논총 제40권 제2호, 한양대학교 법학연구소(2023). 등 참고. ‘법원으로서의 관행’ 및 관행 법제화 논의가 근대법학의 이념에 갖는 시사점에 관해서는 이 글 제5장[V-3.]에서 논한다.

128) 2025년 5월 13일 상가건물 임대차보호법 개정을 통해 기존에 비공식적인 관행으로 유지되어 온 권리금의 법적 개념 정의 규정을 마련함으로써 관행의 입법적 체계화의 전범을 보여주었다고 할 수 있다. 제10조의 3(권리금의 정의 등) 규정과 함께 제10조의4(권리금 회수 기회 보호 등), 제10조의5(권리금 적용 제외), 제10조의6(표준권리금계약서의 작성 등), 제10조의7(권리금 평가기준의 고시) 등을 신설하여 밀도 있게 법제화하였다.

문제점을 안고 있었다. 하지만 고착화된 복합적인 연쇄 구조 안에서 “어느 누구도 원치 않지만 누구도 그것을 부정하거나 거부할 수는 없는” 매우 강력한 규범력을 발휘해 왔다. 따라서 ‘역방향 법제화’를 통해 일거에 기존의 관행 질서를 금지하여 근절할 수도 없는 난국에서 결국 상가임대차법 개정을 통해 권리금 제도의 존재를 공식적으로 승인하고 ‘권리금 계약’의 형태로 법체계 안에 수용한 것이다. 물론 지금까지도 개별 조항과 관련하여 여전히 많은 문제점이 제기되고 논란이 이어지고 있지만¹²⁹⁾, 적어도 기존의 묵시적인 규범적 질서로서의 권리금 관행을 수정된 방식의 입법적 체계화를 통해 법질서 안에 공식적으로 수용하는, 즉 ‘관행의 법제화’를 이루었다는 점은 분명하다.¹³⁰⁾

다. 사례 분석 및 논평 2: ‘택시 사납금’의 역방향 법제화

가장 최근에 한국 사회에서 이뤄진 ‘역방향(-) 법제화’의 대표적인 예로는 택시 사납금 제도를 들 수 있다. 전술하였듯이, 역방향 법제화란 기존 관행의 문제점을 해결하고자 관행 규칙과 반대되는 내용을 규정하는 방식으로 법제화하는 것이다. 가장 강한 형태로는, 기존 관행을 공식적으로 ‘폐지’하는 효과를 창출하려는 목적으로 실정법에 ‘금지’의 명문 규정을 두는 방식이 있다. 택시 사납금 법제화 사례가 대표적이다. 오랜 기간 관행으로 유지되어 온 택시 사납금제의 폐단을 시정하고자 국회가 ‘여객자동차운수사업법령’ 개정을 통해 사납금제를 폐지하는 명문 규정[“운송사업자는 일정 금액의 운송수입금 기준액을 정하여 수납하지 말고 운수종사자는 이를 납부하지 말 것”]을 신설한 사건을 말한다. 이를 앞서 살펴본 ‘나쁜 관행’의 문제와 연결해서 재서술해 보면, 사납금제 사례는 ‘나쁜 관행의 역방향 법제화’로 특징지을 수도 있다. 흥미로운 것은, 사납금제 사안의 경우에는 ‘역방향 법제화’

129) 최준규, “상가건물임대차보호법 상 권리금 회수기회 보호규정 비판-입법론의 관점에서”, 민사법학 제96권, 한국민사법학회(2021). ; 최준규, “상가건물임대차보호법상 권리금회수기회 보호규정의 문제점: 입법론의 관점에서”, 법경제학연구 제20권 제1호, 한국법경제학회(2023). 등 참고.

130) 국내 법학계에서 권리금 관련 이미 많은 연구가 이뤄졌고 다양한 문헌들이 축적되어 있다. 그러나 이 문제를 ① 권리금의 본질이 ‘법원으로서의 관행’이라는 점, ② ‘관행의 순방향 법제화’라는 시각에서 접근하고 분석한 연구는 없다. 그런 점에서 본 연구의 의의가 있다고 볼 수 있겠다. 필자는 2018년 국회정책토론회에서 주제 발표를 통해 이 문제를 다룬 바 있는데, 그 문제의식과 주제의 중요성을 고려할 때 이후 별도의 글을 통해 심도 있게 밝히고자 한다. 이현경, “권리금 분쟁의 법리적 속성과 해결 원칙: 관행이론의 적용과 ‘2선 당사자론’”, 상가임대차 분쟁의 효과적 해결 방향, 국회정책토론회(2018.12.11.)

이후에도 현실에서는 관행 질서가 ‘변형 사납금제’의 형태로 여전히 시민들의 실천적 추론 안에서 강력한 규범력을 발휘했다는 점이다. 즉 ‘나쁜 관행’을 근절하고자 입법론적 결단을 통한 해결을 도모하였지만, 오히려 부작용만 양산되는 사태가 발생하였다. 이 문제를 해결하기 위해 사법부도 입법추론과 그 결단의 실효성을 확보하기 위한 판결을 내림으로써, 사법 추론을 통한 협력적인 제도적 지원을 하였다. 다음은 대법원 판결문 중 일부다.

일정한 금액을 운송사업자에 입금하고 이를 초과하는 초과운송수입금은 운수종사자 자신의 수입으로 하는 **이른바 사납금제는** 운송수입금이 일정하지 않기 때문에 운수 종사자들의 임금액의 변동이 심하고, 고정금이 크지 않기 때문에 운송수입금이 적은 때에는 운수종사자가 기본적인 생활을 하기 위한 정도의 임금조차 확보하기 어려울 수도 있다는 문제점이 있었고, 이에 여객자동차 운수사업법(이하 ‘여객자동차법’이라 한다)이 1997.12.13. 법률 제 5448호로 개정되어 이른바 전액관리제를 규정하였으나 이를 우회하여 사실상 사납금제를 실시하는 경우가 많았다. 그 후 여객자동차법이 2019.8.27. 법률 제16563호로 개정됨에 따라, ‘운송사업자는 일정 금액의 운송수입금 기준액을 정하여 수납하지 말고 운수종사자는 이를 납부하지 말 것’을 명시적으로 규정하는 제21조 제1항 제2호 및 제26조 제2항 제2호가 신설되어 2020.1.1.부터 시행되었다. 이와 같이 일정 금액의 운송수입금 기준액을 정하여 수수하는 행위가 금지됨을 명확히 하여 사납금제의 병폐를 시정하겠다는 신설 경위와 취지 등에 비추어 보면, 위 각 규정은 강행법규로 보는 것이 타당하므로 설령 이에 반하는 내용으로 사용자와 택시운전근로자 노동조합의 합의가 있었다고 하더라도 그 합의는 무효라고 보아야 한다.¹³¹⁾

택시 사납금 제도는 다양한 요인들이 복잡하게 얽혀있는 ‘복합·고차방정식’으로서 택시업계에서 오랫동안 유지되어 온 독특한 임금 지급 관행으로 평가된다. 우리는 언론 기사를 통해 “사납금 제도라는 택시업계의 독특한 임금 지급 관행”이라는 특징화와 함께 “택시업계의 오랜 관행인 ‘사납금’” 혹은 “택시업계 악습 ‘사납금’”과 같은 표현을 어렵지 않게 확인할 수 있으며,¹³²⁾ 이는 ‘사납금’ 제도 역시 이 글에서의 분석 틀에 따르면 ‘강력한 관행’ 혹은 ‘나쁜 관행’의 틀

131) 대법원 2023. 12. 7. 선고 2023도2318 판결. (밑줄·강조는 필자)

132) 전형배, “법인 택시업계의 오래된 숙제” (2024.8.21.; (<https://www.kado.net/news/articleView.html?idxno=1261331>))

안에서 재조명해 볼 수 있음을 방증한다. ‘권리금 법제화’가 적어도 법제화 자체와 관련해서는 완성형 사례로 볼 수 있다면, ‘택시 사납금 법제화’ 사안은 지금도 혼돈의 논란 한복판에서 고투 중에 있는 현재 진행형 사례로 볼 수 있다.

3. 소결: 다차원적 법적 추론 간의 상호 관계 및 규제적 이상

앞서 검토한 두 사례(권리금 및 택시 사납금제)를 통해 우리는 관행의 법제화 문제가 구체화 되는 다양한 방식과 양상을 살펴보았다. 이를 통해 관행이 갖는 본질적 특성인 복잡성과 역동성의 면모를 입체적으로 확인할 수 있었다. 시간의 풍화와 침식 작용을 견디어내면서 결국 조정 해법으로 마련되어 고착된 강력한 관행은 그 깊이와 폭을 예측하기 힘들 만큼 심대하고 복잡하게 얽혀있는 경우가 많다. 그로 인해 관행 질서의 폐지는 물론이거니와 제도적 체계화를 통해 공식 법체계 안에 수용하려는 시도 자체도 매우 까다롭고 섬세한 입법철학적 기예를 요한다. 앞서 ‘복합·고차 방정식’이라는 비유를 하였는데, 이 문제를 해결하기 위해 풀어야 할 방정식 자체도 선명하지 않으며, 선부른 제도적 접근은 오히려 그 방정식을 더욱 복잡하게 심화시켜서 난이도만 높이게 될 가능성도 적지 않다. 그래서 ‘법원으로서의 관행’이라는 본질과 결에 맞는 올바른 이해에 기반한 적합한 대응이 더욱 중요하다.

정도와 방식, 논의 단계나 층위에 차이는 있지만, 여전히 우리 사회에서 현재 진행형 중인 권리금과 사납금제 사안을 돌아보면서 몇 가지 중요한 시사점과 교훈을 발견한다. 첫째, ‘도덕적으로 바람직한 관행’이나 일견 중립적인 통상적 관행뿐만 아니라 ‘나쁜 관행’ 역시 입법 추론 과정에서 중요한 법원 후보로 기능한다는 점이다. 둘째, ‘나쁜 관행’의 문제 근절을 위한 국가기관의 일방적 처단, 즉 강력한 통제적 권위에 기초한 제도적 결단으로서의 ‘역방향 법제화’는 관행의 본질과 결에 맞는 진정한 해법이라고 보기 어렵다. 택시 사납금제 사안에서 보면, 금지 규정의 신설을 통한 전형적인 역방향 법제화를 통해 기존 관행을 폐지하고자 하는 국가주의적 시도는 문제를 해결하기보다는 오히려 다양한 일탈적·변칙적인 변형태만 양산하였고, 택시 사납금제를 둘러싼 문제 상황을 더욱 복잡하게 만들었다고 평가할 수도 있다. 따라서 셋째, 나쁜 관행의 문제에 대한 올바른 접근법은 법기관이 ‘공동의 협력 프로젝트’를 수행한다는 관점과 자세로 입법 및 사법 추론의 협력적인 상호작용이 요청된다. 이러한 협업은 ‘공유된 권위’ 논변¹³³⁾에 의해 정당화될 수 있다. 사납금 사례에서 보았듯이, 입법 추론에 기한 입법적 결단뿐만 아니라 사법 추론을 통한 판결이 입법과의 상호 시선 왕복을 통해 적절히 조응하고 보완을 시도하고 있음을 확

133) Dimitrios Kyritsis, *Shared Authority*, Hart Publishing, 2015.

인할 수 있다. 하지만 여기에도 한계가 있다. 넷째, 특히나 ‘나쁜 관행’의 문제는 공식적인 국가법기관의 역할만으로는 온전한 해결이 어렵다. 공동체법이자 문화 규범으로서의 본질을 내포한 관행 법원의 특성에 다시금 주목할 필요가 있다. ‘나쁜 관행’의 문제를 투명하게 밝히고 공론화함으로써 해당 분야에서의 특수 사안을 넘어 사회 일반에서 문제점 인식과 공감대 형성이 중요하다. 이를 통해 그러한 법원을 실제 형성하고 준수하면서 직접적 이해관계를 맺어 온 일선 당사자뿐만 아니라 간접적으로라도 그러한 상황을 목과하거나 방입해 온 일반 시민들에 이르기까지, 공동체 성원 전체의 실천적 추론 안에서 인식 개선과 법실천의 변화가 뒷받침될 필요가 있다. 또한 그러한 과정에서 실천하는 개인이 위해를 입거나 부당하고 과도한 부담을 감내해야 하지 않도록 제도적 차원에서의 안전한 여건 마련과 지원도 절실하다. 이러한 공동 프로젝트는 일종의 ‘책임의 연대’ 논변을 통해 정당화될 필요가 있다.¹³⁴⁾ 요컨대 이 글 전반에서 거듭 강조하였듯이, 입법 및 사법 추론, 전문가의 영역-특수적 추론, 그리고 시민들의 법생활 속 실천적 추론이라는 다차원적인 법적 추론이 상호 협력적·통합적으로 기능할 때 진정 ‘법원으로서의 관행’의 본질과 결에 맞는 접근을 완성할 수 있다. 그러한 시도가 제대로 이루어진다면 우리는 ‘민주적 법원’의 의미를 입체적이고 풍부하게 이해할 수 있을 뿐 아니라 ‘법의 민주화’라는 규제적 이상에도 한 걸음 더 다가갈 수 있을 것이다.

V. 성찰적 법관행주의를 향하여

1. ‘반성적 관행으로서의 법’과 ‘반성적 추론’

가. 다시, “법보다 관행이 더 가깝다?": ‘법원으로서의 관행’

서두에서 우리는 “법보다 주먹이 더 가깝다”라는 클리셰(cliché)를 대체하는 현재적 버전으로 “법보다 관행이 더 가깝다”라는 문장을 제시하고, 그것에 의문

134) 소위 ‘나쁜 관행’은 일면 ‘구조적 부정의’ 문제와도 연관된다고 볼 수 있다. 구조적 부정의는 아이리스 영에 의해 그 실제와 양상이 체계적으로 제시된 바 있다. Iris Marion Young (김도균·조국 역), 차이의 정치와 정의, 모티브북(2017). 구조적 부정의 문제를 근본적으로 해결하기 위해서는 공동체 구성원들의 집단적인 ‘정치적 책임’의 문제로 접근할 필요가 있다. 즉 단순히 한 개인의 부정의한 행동에 그 원인을 귀속시키거나 개별 행위에 대한 교정만으로는 한계가 있으며 결국 ‘책임의 연대’를 통해서 극복 가능하다. ‘나쁜 관행’의 실천적 해결’ 문제는 매우 중요한 또 하나의 주제인데 이 글의 초점이나 논의 범위를 벗어난 면이 있어 별도의 글을 통해 체계적이고 포괄적으로 다루고자 한다.

의 제기하는 물음표 “?”를 붙이면서 논의를 시작했다. 이제 글을 마무리하면서 이 투박한 질문에 대해 답을 해야 할 시점에 이르렀다. 결론부터 말하면, 질문 자체가 오류다. 이 비교 구문을 구성하는 두 항인 ‘법’과 ‘관행’은 결코 독립적 실체가 아니며 그럴 수도 없다. 특히나 다차원적인 법적 추론의 맥락에서 관행은 ‘법원(法源)’으로서의 위상을 가지며, 이는 법적 주체 즉 법적 의사결정자의 해석 작업을 통해 법규범으로 전환된다. 이러한 관계론적 설명에 따르면 법의 기원이자 원천으로서의 관행은 대문자 법에 대한 ‘타자’로 존재하는 것이 아니며, 따라서 ‘법보다 관행이 더 가깝다’는 본질적 표현은 부적절하다. 다만, ‘법원으로서의 실정법규칙’과 ‘법원으로서의 관행’으로 이 문장 성분을 정정해 본다면 이는 현실 법세계에서 일상적으로 접하는 무수한 사태에 대한 하나의 그림직한 묘사일 수는 있다. 동시에 입법 및 사법 추론 과정에서 난제로 등장하는 문제 상황을 포착하고 대변하는 상징적 표현으로 볼 수도 있다. 제4장에서 검토한 법적 사례들을 통해서도 이 점을 확인할 수 있었다. 요컨대 ‘법보다 관행이 더 가깝다?’를 정정하여 올바르게 도출해 낸 이 글의 첫 번째 논제는 관행은 법의 원천이며, 끊임없는 교호·길항 작용을 통해 상호 관계를 이어간다는 것이다.

나. ‘반성적 관행으로서의 법’

이제 법의 원천으로서의 관행을 넘어, 법개념 및 법 본성론의 차원으로 한 걸음 더 나아가 보자. 이른바 ‘비판적 법실증주의’를 주창한 투오리(Kaarlo Tuori)는 법의 다층적 본성을 강조하면서 ‘다층적인 규범적 현상으로서의 법’을 주장한다. 그리고 법의 두 측면으로 ‘상징적인 규범적 현상으로서 법질서’와 ‘일련의 구체적인 사회적 실천으로서의 법실천’을 강조한다.¹³⁵⁾ 투오리의 다음 논급은 복합적인 문화 규범으로서의 특수성을 갖는 관행에 관한 이 글의 논지에도 참고할 만한 시사점을 제공한다.

법은 개별 규정이나 법원(法院)의 결정과 같은 구체적인 법적 자료에 의해 완성되는 것이 아니라 ‘표면적’ 충위를 포함한다. 나는 이제 이러한 충위를 법 문화와 법의 심층 구조라고 부른다.¹³⁶⁾

135) Kaarlo Tuori, *Critical legal positivism*, Routledge, 2016.

136) Kaarlo Tuori, 위의 책(주135).

이제껏 수많은 법이론들이 주로 법의 표층에 집중해 왔다면 이 글의 문제의식은 투오리가 말한 법 문화와 법의 심층 구조에까지 시선을 확장하면서 두 층위 간의 상호성에 주목한다고도 볼 수 있다. 그렇다면 이런 중층적인 법의 본성을 담은 적절한 법개념 논제는 무엇일까?

사우스우드(Nicholas Southwood)는 ‘관행적 규범으로서의 법’이란 논제를 토대로 법의 본질적 측면을 관행 규범으로 설명한 바 있다.¹³⁷⁾ 이른바 법관행주의자들 중 일부는 관행을 통해 법의 규범성 해명을 시도하기도 했다. 법철학 논쟁사로 보면, 관행성 테제나 법관행주의의 본격적인 등장은 하트의 승인율에 대한 해명과 드워킨의 실증주의 공격에 대한 재반론 과정을 계기로 한 것이지만, 그 가치는 이론의 세계를 넘어선다. 법의 세계에서 그것이 중요한 진정한 이유 중 하나는, 법은 어느 순간 진공 속에서 갑자기 주어지는 그 어떤 소여(所與)가 아니라, 우리 공동의 삶 속에서 끊임없는 상호작용을 통해서 형성된 자율적인 규범적 질서의 제도화라는 민주적 법관념을 지지하기 때문일 것이다. 원형적 형태의 민주적인 규범적 질서로서의 관행은 그 자체로 법의 기원과 원천이 되기에 충분한 자격이 있다. 즉 민주적 기원을 갖고 공동체법이자 문화 규범의 복합적 속성을 갖는 관행은 강한 구속력의 근원을 제공한다.

그런데 문제는 그러한 민주적 관행 질서가 왜곡되거나 타락한 형태로 변질되고 강화되어 온 경우 역시 현실에서 적잖이 접할 수 있다는 점이다. 소위 ‘나쁜 관행’은 이런 사태를 상징적으로 나타내는 표현적 개념이다. 이 문제에 있어서는 더욱 신중한 접근과 성찰이 요청되며, 만약 이를 결하게 되면 큰 비용을 치르게 된다. 요컨대, 민주적 법원으로서의 관행은 그 자체로 존중되어야 할 가치가 있지만[‘관행 존중의 원칙’], 동시에 관행성이 극단화되거나 부정의로 치닫지 않도록 늘 비판적·반성적 태도를 견지해야 한다. 그리고 이런 점은 법본성론에서도 중요하게 고려될 필요가 있다.

따라서 법의 개념이나 본성론 차원에서는, 사우스우드가 제안한 ‘관행으로서의 법’ 논제에 그치지 않고 그에 대한 비판적 성찰과 규범적 통제를 거쳐 정제된 ‘반성적 관행’으로 수정되어야 한다. 그런 의미에서 ‘관행으로서의 법’ 관념에서의 부족분을 보충하고 이 논제 전체를 이끌어갈 ‘반성적’이란 수

137) Nicholas Southwood, “Laws as Conventional Norms”, in *Dimensions of Normativity*, David Plunkett · Scott J. Shapiro · Kevin Toh (eds.), Oxford University Press, 2019.

식이 추가될 필요가 있다.¹³⁸⁾ 이로써 ‘반성적 관행으로서의 법’이라는 이 글의 두 번째 논제가 완성된다.

다. ‘반성적 추론’의 중요성

이른바 ‘반성적 추론’은 이런 문제의식을 법적 추론의 과정에도 필수적으로 요청하고 반영한 추론 방식을 말한다. ‘법원으로서의 관행’이 법규범으로 전환하는 중간 기제로서의 해석 과정에서 비판적·반성적인 성찰이 중요하다. 왜냐하면 ‘관행성’의 핵심을 이루는 임의성이 자칫 과도한 자의성으로 이어질 수 있는 잠재적 위험을 통제할 필요가 있기 때문이다. 또한 ‘역사적 현존성’과 그로 인해 획득된 사회적 규범력을 기반으로 하는 관행의 법원성 안에 결핍된 ‘비판적 이성성’ 요소를 보충하기 위한 사후적 보완 장치가 요청되기 때문이다. 임미원 교수는 “법은 이성적 정당성뿐만 아니라 합목적적 제도성 및 질서체계로서의 현존성을 갖추어야 한다. 이런 비판적 이성성, 합목적적 제도성, 역사적 현존성의 요소들은 근대 이후 법과 국가의 자기정당화 과정에서 규범적 부침을 겪어왔”¹³⁹⁾다고 강조한다. 만약 근대법이 갖춰야 할 필요 요건으로 인용문에서와 같이 ‘비판적 이성성’·‘합목적적 제도성’·‘역사적 현존성’을 꼽는다면,¹⁴⁰⁾ ‘법원으로서의 관행’이나 ‘관행으로서의 법’ 개념은 ‘합목적적 제도성’

138) 다만 여기서 한가지 부연한다. ‘반성적 관행으로서의 법’이라는 논제 속 핵심어인 ‘반성적 관행’이라는 표현 자체의 철학적 의미를 둘러싼 불확정성이 있으며, 이에 관한 문제 제기가 가능하다. 말하자면, (i) 존재론적 차원에서, 관행 그 자체가 반성적이라는 것인지 혹은 (ii) 인식론적 차원에서, 관행에 대한 반성적 과정을 거친다는 것인지와 관련하여 표현상의 모호함이 있다. 이 문제는 한편으로는 상징적이거나 압축적 형태의 법개념 문제가 대부분 내포하고 있는 필연적 한계일 수 있다. 하지만 좀 더 적극적으로 이 물음에 답해보자면, 이 논제는 존재론적이고 인식론적인 두 측면을 모두 담고 있을 뿐만 아니라 그 공간에는 가치론적 측면이 전제되어 있다. 그 중에서도 특히 인식론적 차원에서의 ‘반성성’을 역할을 강조하게 되면 ‘반성적 추론’이라는 기법으로 표현할 수 있겠다.

139) 임미원, “탈관습적 시대의 규범적 논거들의 계보”, 161면.

140) 임미원 교수는 현대사회를 ‘탈관습적 시대’로 규정한 후 기존의 관행적·관습적 질서의 폐단 극복과 탈관행적·탈관습법적 대응을 주장한다. 임미원, “대법원의 유체인도 판결의 법철학적 고찰”, 법조 제62권 제8호, 법조협회(2013), 265면(“역사적 관습의 영역을 합리화-절차화-제도화시켜 새로운 관습성으로 표현해내는 것이 탈관습적 시대의 사법의 과제가 될 것”). 이런 견해는 ‘반(anti)-관행주의’로 표현해 볼 수 있을 것 같다. 그런데 필자는 관행 질서가 갖는 민주적 기원이나 민주성의 토대, 현장성에 근거한 규범력의 기능적 우월성 등의 면도 고려한다면, ‘반관행주의’ 같은 전면적 부정보다는 비판적·반성적 작업을 필수로 추가·정교화하여 개선한 ‘성찰적 관행주의’ 모델이 더 낫다고 생각한다.

과 ‘역사적 현존성’에 크게 의존하며 ‘비판적 이성성’ 요소는 그 질서의 형성 과정이나 작동 기제 안에서는 기대하기 어려운 면이 있다. 따라서 ‘법원-법규범의 구별’ 논제를 기초로, 결국 추론 과정에서 ‘비판적 이성성’의 보충이 필요한 것이다. 그럴 때에 소위 ‘나쁜 관행’에 대한 규범적 통제나 현실적인 해결도 가능해질 수 있을 것이다. 그것을 가능하게 하는 것이 바로 ‘반성적 추론’이다. ‘반성적 추론’은 주되게는 두 지점에서 실현될 수 있다. 우선 ‘법원-법해석-법규범’의 관계식을 기초로, 전환 기제로서의 법해석을 거쳐 법규범을 도출하는 과정 안에서 중간 성찰을 통해 구현된다. 또한 그렇게 획득한 법규범을 해당 사안에 적용할지의 여부를 결정하는 재판 이론 단계에서도 역할을 한다. 물론 이는 명확히 구분할 수 있는 것은 아니며, 광의의 법학방법론 전반에 걸쳐 상시적으로 이뤄지면서 동시에 다차원적인 법적 추론의 모든 장에서 필수적으로 요청된다.

그런데 현재 시점에서 반성적 추론 기법을 독자적인 추론 모델로 주장하기에는 기존의 귀납 및 연역 추론과 같이 명확하고 차별화된 특징이나 기법을 갖추지 못했다는 한계가 있다.¹⁴¹⁾ 하지만 이런 추론을 통해 달성하고자 하는 목표나 지향점, 실제 법현실에서 법적 추론이 이뤄지는 중요한 일면과 양상을 적절히 담아낸다는 점에서는 특별함이 있다고 본다. ‘반성적 추론’ 모델의 불완전한 지위와 그 독자성에 대한 의구심은 가추의 경우를 떠올리게도 한다.¹⁴²⁾ 그러나 가추가 점차 그 가치를 인정받고 있듯이, ‘반성적 추론’도 지속적인 이론 개발을 통해 하나의 모델로서 입법 및 사법 추론의 법실무에서도 받아들여질 수 있기를 기대한다. 또한 불완전하지만 ‘반성적 추론’이라는 명명을 시도함으로써 법이론과 법실천 영역에서 그 필수적 역할과 중요성을 새기는 데에 조금이나마 기여하고 법의 세계가 진보하기를 희망한다.

2. 성찰적 법관행주의

골도니(Marco Goldoni)는 “법관행주의 학파의 첫 번째 물결은 루이스의

141) 최근 법적 추론의 본성에 관한 여러 견해를 담고 있는 책으로, Mark McBride · James Penner · George Pavlakos(Eds.), *New Essays on the Nature of Legal Reasoning*, Hart Publishing, 2022.

142) 가추의 내용 및 그 독자성 논쟁에 관해서는 공두현, “법적 추론에서의 가추(Abduction)와 개연성”, 저스티스 제173권, 한국법학원(2019). ; 한상훈, “가추법은 독자적 법적 추론 방법인가 - 대법원 2019. 4. 18. 선고 2017도14609 전원합의체 판결과 서울고등법원 2010. 5. 31. 선고 2009노3108 판결을 중심으로”, 저스티스 제181권, 한국법학원(2020). 등 참고.

저서 *Convention(1969)*의 출판 이후에 등장했다.”고 평한다.¹⁴³⁾ 소위 제1 물결 이후 법관행주의는 변천과 발전을 이뤄왔는데, 그렇다면 이 글이 공들여 새로이 그리고자 하는 물결은 무엇일까? 이 주제는 ‘반성적 관행으로서의 법’이라는 법 본성론 논제와 ‘반성적 추론’을 결합한 결과, 하나의 일반 법이론 모델로는 어떻게 발전될 수 있을지의 질문을 포함한다.

주지하듯이 법의 본성에 관한 법철학 입장의 주된 두 흐름은 법실증주의와 자연법론(혹은 비실증주의)이다. 현대 법철학이론사에서 ‘관행’ 개념이 중요하게 등장한 계기는 하트 승인율의 본성 해명 및 드워킨의 공격에 대한 재반론 과정에서였다.¹⁴⁴⁾ 또한 드워킨이 하트류의 법실증주의를 ‘관행주의’로 특징화하면서,¹⁴⁵⁾ 영미법철학계에서 ‘관행주의’는 법실증주의의 한 버전이나 속편으로 이해되어 온 경향이 있다. 하지만 관행주의는 결코 법실증주의의 전 유물이 아니며, 기술 이론에 머물러야 하는 것도 아니다. 하나의 철학적 태도로서 ‘관행주의’의 본래 의미¹⁴⁶⁾에 집중한다면, 법관행주의를 그 안에 다양한 견해들을 담을 수 있는 유연하고 포용적인 그릇으로 이해할 수 있다. 그런데 ‘법관행주의’로 분류되는 여러 입장들¹⁴⁷⁾이 존재하지만, 관행주의 담론 안에서 그 근본적인 기초 개념인 ‘관행 그 자체’에 대한 비판적 고찰까지 담은 견해를 찾기는 쉽지 않다.¹⁴⁸⁾

143) Marco Goldoni, “Multilayered Legal Conventionalism and the Normativity of Law,” in *New Essays on the Normativity of Law*, Hart Publishing, 2011, p.159.

144) 대표적으로 콜먼과 포스테마의 작업이 그러하다. 콜먼의 ‘관행성 테제’에 관해서는, Jules L. Coleman, *The Practice of Principle*, Oxford University Press, 2001. ; Jules L. Coleman, “The Conventionality Thesis”, *Philosophical Issues*, 2001. 참고. 관행에 관한 포스테마의 주요 문헌으로는, Gerald J. Postema, “Coordination and Convention at the Foundations of Law”, *The Journal of Legal Studies*, 1982. ; Gerald J. Postema, “Conventions at the Foundation of Law,” in *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, Peter Newman (Ed.), 1998. 등 참고.

145) Ronald Dworkin(장영민 역), *법의 제국*, 아카넷(2004), 제4장 관행주의. 참고.

146) 레스콜라에 따르면, ‘관행주의’란 어떤 현상이 관행으로부터 발생하고 관행에 의해 결정된다는 교의를 의미한다. 즉 어떤 종류의 근본 원리들이 사회 안에서의 명시적 혹은 묵시적 합의들에 근거를 두고 있다는 철학적 태도를 관행주의라 한다. Michael Rescorla, “Convention”, substantive revision, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2024, p.4.

147) ‘법관행주의’를 둘러싼 다양한 관점의 논문을 엮은 책으로는, Lorena Ramírez-Ludeña · Josep M. Vilajosana (eds.), *Legal Conventionalism*, Springer, 2019. ‘법관행주의’를 유형화하는 가장 최근의 시도로는, Federico José Arena, “Conventionalism”, in *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, Mortimer Sellers & Stephan Kirste(eds.), Springer, 2023. 참고.

148) 양선숙 교수님도 이 점을 분명히 지적한다. 양선숙, “법, 규범성, 그리고 규칙 준수의 동기에 대한 관행론적 이해,” 법철학연구 제15권 제3권(2012), 48면(“통상적 관행론은 나쁜 관행과

대부분의 논자는 관행을 현존하는 단면적인 사회적 실재로 단정짓고는, 곧바로 설명하려는 대상이나 현상에 집중하는 경향이 강하다. 포스테마나 마머와 같이 관행의 본성 해명에까지 나아간 일부 선행 연구에서도 관행의 품질에 대한 평가 문제는 발견하기 어렵다. 하지만 우리는 ‘법원으로서의 관행’ 논제나 (투박한) ‘관행주의’¹⁴⁹⁾라는 첫 관문에서 멈추지 않고 그 너머에 반성적 성찰을 결합하는 두 번째 관문까지 나아가고, 이를 대안적 이론 모델에 반영할 필요가 있다.

최근 관행주의에 대한 새로운 시각을 보여주고 이에 관한 단행본도 출간한 오웬은 관행에 구속될 본래적 가치가 있다고 주장하면서 ‘겸허한 관행주의(modest conventionalism)’를 제안한다.¹⁵⁰⁾ 이 모델은 관행에의 맹목적 복종을 시사하는 ‘무차별적 관행주의(brute conventionalism)’와는 달리, 관행에 의해 규범성이 창출될 뿐 아니라 관행에 구속되고 복종하는 것이 규범적·실천적으로 매우 선한 가치를 창출한다는 것이다. 즉 관행 준수가 갖는 고유한 실천적 가치를 여러모로 강조함으로써 관행주의를 새로운 방식으로 옹호한다. 오웬의 이런 접근은 한편으로는 월드런(Jeremy Waldron)이 제창한 ‘규범적 법실증주의’나 ‘윤리적 법실증주의’를 떠올리게 한다.¹⁵¹⁾ 생각건대, 오웬의 주장은 분명 중요한 통찰을 담고 있지만, 우리는 여기서 한 걸음 더 진보할 필

좋은 관행을 구분할 수 없다. CR을 만족하여 ‘관행’으로는 분류되지만 규범성을 갖는다고는 할 수 없는 행동규칙이 가능하다. 만약 우리에게 법 이론으로서의 관행론이 있어야 한다면, 그것은 관행 일반에 대한 이론에서 그치는 것이 아니라 ‘좋은 관행’을 적절하게 설명하는 것이어야 할 것이다.”).

- 149) “(투박한) ‘관행주의’”라고 모호하게 표현한 이유는 대립항으로서 철학 영역에서의 주류적인 ‘논리·분석적 관행주의’나 (오웬의 표현을 빌자면) ‘무차별적 관행주의(brute conventionalism)’까지를 포함한 여러 형태를 염두에 둔 것이다. 그런데 ‘투박한’에 괄호() 표시를 한 것은, 이러한 버전들과 이 글에서 제안하는 ‘성찰적 법관행주의’ 사이에도 폭넓은 스펙트럼의 가능성이 있기에, 둘 간의 극적인 대비 효과를 뒤로하고 보다 포용적으로 관행주의 일반을 담기 위함이다.

150) David Owens, *Bound by Convention*, Oxford University Press, 2022.

- 151) Jeremy Waldron(송성국 역), “규범적 (또는 윤리적) 실증주의”, 법철학연구 제20권 제3호, 한국법철학회(2017). 법실증주의를 채택하는 것이 실천적 차원에서 더 나은 효과를 발생시킨다는 것이다. 기존 법실증주의가 기술 이론에 머물렀다면, 윤리적·규범적 법실증주의는 실천적 함의를 내포하는 차별점이 있다. 참고로, 최근 국내 법철학계에서는 조홍식 교수님이 칸트의 법철학을 ‘규범적 법실증주의’의 관점에서 재조명하는 연구를 심도 있게 수행하고 있다. 조홍식, “칸트의 규범적 법실증주의—하트의 관점에서 시도하는 칸트 텍스트의 분석”, 서울대학교 법학 제63권 제4호, 서울대학교 법학연구소(2022). 참고.

요가 있다. 법실증주의, 나아가 법관행주의라는 법철학적 입장 그 자체도 상시적인 자기검열과 비판적 성찰의 대상이 되어야 한다. 앞서 ‘관행으로서의 법’ 앞에 ‘반성적’의 제약 필터를 더하여 완성했듯이, ‘법관행주의’ 앞에도 그 전체를 이끌고 규범적으로 통제할 수 있는 요소를 추가할 필요가 있다. 결론적으로, ‘반성적 관행으로서의 법’ 논제는 ‘비판적 관행주의(critical conventionalism)’ 혹은 ‘성찰적 관행주의(reflective conventionalism)’라는 이름의 일반법이론 모델로 발전될 수 있으며, 이는 항상 다차원적인 법적 추론에서 법실천과 함께 구현되어야 한다. ‘성찰적 관행주의’는 ‘규범적 관행주의’의 한 형태로 분류할 수도 있지만, 거기서 한 층 심화·발전된 것이다. 법실증주의에 국한해 본다면 ‘비판적 법실증주의’¹⁵²⁾와 문제의식을 일면 공유하고 있다고 볼 수 있으며, ‘반성적 법실증주의’도 참고할 만하다.¹⁵³⁾ 결론적으로, 이 글의 제3논제로 주창하는 ‘성찰적 법관행주의’는 루이스의 관행 분석을 계기로 시작된 (골도니의 표현을 빌리면) “법관행주의의 첫 번째 물결” 이후 어찌면 가장 중요한 발전적 전환의 새 물결이 아닐까 생각해 본다.

3. 근대 법학의 이념과 성찰적 법관행주의, 그리고 법의 지배 정신

마지막으로 지금까지의 논의를 정리하면서, 그것이 근대 법학의 법의 지배 이념에 갖는 시사점을 간단히 짚어보자. ‘법원으로서의 관행’[논제1]에서부터 ‘반성적 추론’을 거쳐 ‘반성적 관행으로서의 법’[논제2]와 ‘반성적·성찰적 법관행주의’[논제3]를 제창한 이 글의 견해는 근대 법학의 이념과 법의 지배 정신과 관련하여 어떠한 함의와 가치를 가질까?¹⁵⁴⁾

152) 국내에서 ‘비판적 법실증주의’에 관한 연구로는, 심헌섭, “비판적 법실증주의”, 분석과 비판의 법철학, 법문사(2001). ; 김대휘, 법철학과 법이론 입문 제2판, 성안당, 2023. ; 김대휘, “비판적 법실증주의 법이론”, 기초법학연구 제3호, 서울대학교 법학연구소 법이론연구센터(2024). ; 김현철, “비판적 법실증주의를 다시 생각함”, 법철학연구 제27권 제1호, 한국법철학회(2024). 프랑크푸르트 학파의 비판이론을 받아들여 특별한 버전의 ‘비판적 법실증주의’를 제창하고 완성도 있는 연구를 수행한 주목할 만한 책으로는, Kaarlo Tuori, *Critical legal positivism*, Routledge, 2016. 참고.

153) Adam Dyrda, “Reflective Legal Positivism”, *ARCHIWUM FILOZOFII PRAWA I FILOZOFII SPOŁECZNEJ*, 2022. 다르다는 정합성이라는 이상에 비취볼 때, 드워킨의 해석주의 모델과 비교하면서 자신이 주장하는 반성적 법실증주의 모델의 우월성을 논증하고자 한다.

154) 이 부분 내용과 관련하여 중요한 지적을 해주시고 큰 도움을 주신 익명의 심사위원님과 장영민 교수님께 지면을 빌려 깊이 감사드립니다.

가. 근대 법학의 이념과 실제: ‘사이’에서 ‘너머’로

근대법질서와 근대 법학은 실천이성 능력을 갖춘 합리적 주체로서의 인간, 즉 합리적 인간상¹⁵⁵⁾을 전제한다. 이를 기초로 인간 이성에 기반하여 실정법의 제정 및 준수와 집행이 이뤄진다는 가정 아래 설계되었다. 역사적으로 이는 특히 근대 유럽의 법전편찬으로 이어졌고 ‘티보-사비니 논쟁’으로 대표되는 자연법학과 역사법학 간의 논쟁을 초래했다. 법사상사적으로 보면, 18세기 말 당시 자연법학과는 근대적 통일법전 편찬이 자연적·보편적 이성법과 계몽주의의 요청이라고 주장했고, 역사법학과는 민족정신과 법의 역사성을 토대로 체계적인 판데텐 법학 및 법학적 실증주의를 전개했다. 반면 두 진영과 모두 거리를 두었던 헤겔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)은 근대의 법전화 작업을 평등주의적 관점에서 이해하였다. 즉 법전편찬은 근대 시민사회의 평등한 개인들의 욕구와 상호 관계에 제도적인 보편성 및 명확성을 부여하고 규범적으로 승인한다는 의미가 있다고 보았다. 다시 말해 “근대의 입법-법전화는 단지 주관적이고 특수하게 현존하는 관행-관습에 객관적 외관형식을 부여하는 수집편찬의 의미가 아니”라는 것이다.¹⁵⁶⁾ 이러한 근대 법전화 논쟁과 그 기저의 이념적·가치론적 갈등은 법관행주의에 많은 시사점을 안겨준다.

그렇다면 ‘법원으로서의 관행’과 ‘관행의 법제화’를 논한 이 글의 관행주의적 접근은 근대의 이성주의 전통과 근대 법학의 평등주의 이념에 전면적으로 반하는 것일까? 지면의 한계상 간략히 답해보자면, 우선 관행주의는 기본적으로 근대 사회계약론의 근본 전제들이 갖는 허구성에 비판적이며, 계약주의를 넘어서고자 한다. 가령 추상화된 독립적·합리적·이성적 개인이라는 관념과 각종의 이분법적 전제들을 극복하고자 하며, ‘이념으로서의’ 평등주의 지향 아래 기획·설계된 근대법질서 하에 오히려 은폐되거나 누락된 많은 존재자들과 사태들로 이루어진 ‘실제’와 현실 세계의 목소리에 주목한다.¹⁵⁷⁾ 다만 근대 사회계약론과 입법 운동이 타파하고자 했던

155) 라드부르흐는 ‘근대법의 인간상’을 다음과 같이 설명한다. “중세 시대의 법적 인간상은 의무와 공동체와 결합된 인간상이었다면, 르네상스와 종교개혁과 로마법 계수를 통해서 공동체로부터 해방된 개인, 의무가 아니라 이익에 의해 지배되는 개인이라는 인간상이 근대법의 출발점이 되었다. 이전과 과정은 상인계층의 필요에 의해 이루어졌는데, 새로이 확립된 법적 인간상은 이윤추구와 경제적 이해타산으로 일관되게 사유하고 행동하는 상인상을 따라 조형된 것” Gustav Radbruch, “법에서의 인간상”, 1929.

156) 임미원, “근대 법전편찬의 사상적 기초 - 자연법학, 역사법학, 헤겔의 견해와 관련하여”, 법학논총 제40권 제1호, 한양대학교 법학연구소(2023).

157) 근대법학의 법리적 틀만으로는 설명할 수 없는 생생한 분쟁의 현장과 세상의 다종다기한 법현상들은 기존의 법리만으로는 채울 수 없는 여백과 결핍에 대한 적절한 대응을 필요로

불건적 구체제의 법분열 상태나, 불평등과 무질서로 점철된 관행 질서를 있는 그대로 수집·보고하는 방식의 법제화는 지지하지 않는다. 오히려 그러한 무분별한 백과사전식 체계화¹⁵⁸⁾가 초래할 결함을 보완하기 위해 반성적 추론을 필수적으로 요하는 것이다. 즉 적절히 개선된 법관행주의는 근대법질서를 형성했던 근본 전제들의 시대적 소명과 특별한 역할을 긍정하고 존중하지만, 이와 함께 한편으로는 합리적 이성주의가 놓치거나 간과해온 실제 삶의 현실에 주목하고 근대 법학의 추상화된 이념적 토대를 재고한다. 다른 한편으로는 근대적 세계관과 인간학적 전제를 갱신하는 과학의 새로운 발견과 성과에 주목하면서 동시에 탈근대 사회의 변화된 법질서에 적합한 유연한 접근을 추구한다. 그리고 특히나 ‘비판적·성찰적 법관행주의’는 관행 질서의 본래적인 민주적 토대와 기원은 살리되 그것이 내포하는 (그리고 근대법이 보완·극복하고자 했던) 불확명확성·불확정성의 단점은 유연성의 장점으로 승화시킨다. 또한 경로의존성과 임의성의 극단적 무절제함이 초래할 수 있는 위험은 적절히 통제함으로써 근대 법학의 이념과 실제 ‘사이’의 간극을 좁히고 조화를 도모하면서도 그 ‘너머’의 진정한 평등 사회 실현을 꿈꾼다고 볼 수 있다.¹⁵⁹⁾

나. 연성법과 법의 지배의 정신

‘법의 지배’는 정치적 도덕의 이상 중 하나로 거버넌스 시스템에서 법 그 자체와 법체계 기관의 우위를 의미한다.¹⁶⁰⁾ 법의 지배 정신과 관련해서 보면 관행의 규범성과 법원성을 인정한다는 것은 논의의 끝이 아니라 시작이라고 볼 수 있다. 가령 영미법계에서는 의회의 입법고권이 확립된 강력한 관행이지만 그것이 현실의 구체적 사안까지 지배력을 미치는 데에는 많은 중간 성찰이 필요하다.¹⁶¹⁾ 이 점은 ‘법원-법규범의 구별’ 논제를 통해 ‘법원으로서의 관행’이 구체적

한다. 같은 취지로 권영준, 민법학의 기본원리, 박영사(2020). 참고.

158) IV-2. <표5>에서 다룬 관행 법제화의 두 방식(‘입법적 체계화’와 ‘백과사전식 체계화’) 참고.

159) 필자가 그동안 고민해 오고 현재 연구 논문으로 준비하고 있는 법철학 주제 중 하나는 “법이념론의 갱신(更新)”에 관한 것이다. 오늘날 탈근대·미래사회에서는 기존의 근대 법학이 전제해 온 법이념 자체에 대한 근본적 반성과 재조정, 갱신이 필요하다고 생각한다. 법이념에 대해서는 Gustav Radbruch(윤재왕 역), 법철학, 박영사(2021). ; 심현섭, 분석과 비판의 법철학Ⅱ: 법이념·순수법학·법이론, 법문사(2024). 등 참고.

160) Jeremy Waldron, “The Rule of Law”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2016.

161) 드워킨의 관행주의·실용주의, 켈젠의 순수법학 상의 동학·법단계설에서 법관의 법의 구체화와 ‘동시에’ 이루어지는 법창조, 하트의 재량 등의 논의가 이런 점을 잘 말해준다.

사안에 적용가능한 법규범으로 전환되기 위한 중간 기제인 법해석 과정에서 비판적·반성적 성찰이 필요함을 강조한 것과 통한다. 그런데 바로 이 지점에서 드워킨은 ‘관행’과 ‘원리’를 대조하면서, 관행이 옹호하는 법문을 무력화하고 원리가 가진 ‘적절성 감각’을 기초로 사안을 끌고 가 버리는 원리의 견인력을 강조하기도 한다.¹⁶²⁾ 그는 원리를 주장하면서 그것이 의회가 법을 만든다는 법의 지배의 정신에 더 부합한다는 다소 역설적일 수도 있는 주장을 한다. 관행주의에 비판적인 드워킨의 관점을 좀 더 밀고 나가보면, 관행은 일응의 판단 근거는 될 수 있지만 최종 결정권은 없을 수 있으며 결국 원리를 기반으로 정합성(integrity)을 살리면서 하나의 목소리로 말하는 ‘법의 구현’이 근대적 법치의 이념이라는 해석이 가능하다. 이를 담보하지 못하는 관행에의 의존이 주는 (경우에 따라서는) 보수성이나 (더 나아가서는 반동성) 문제될 수 있다. 그런데 이런 지적은 세 가지 점에서 결함이 있다. 첫째, 드워킨과 그 계승자들은 관행에 대한 정적 관념을 전제한다. 즉 드워킨의 관행주의 비판은 관행을 확립되고 고정된 실체로서 발견의 대상으로 인식하는 특정 개념관에 기초한다.¹⁶³⁾ 관행에 대한 동적 접근은 관행에 덧씌워진 이런 부당한 비판에 대응한다. 둘째, 관행주의가 보수성이나 반동성의 수단으로까지 오인될 수 있을 관행 그 자체에 내포된 ‘관행성’의 일면을 완전히 부인하기는 어렵다. 다만 그 잠재적 위험을 명확히 인식하고 규범적으로 통제하기 위한 추론과 법이론 모델이 ‘반성적 추론’과 ‘성찰적 법관행주의’의 취지다. 셋째, 드워킨이 원리의 중요성을 강조하면서 ‘관행’을 대립항으로 설정하고 비판했지만, 오히려 관행과 원리는 ‘연성법’이라는 범주 안에서 가치와 방향을 공유하고 경성 법증주의의 한계를 보완하고 진정 삶을 담아낼 수 있는 미래법모델로 재조명·재평가될 수 있다.

(논문투고일: 2025.2.28, 심사개시일: 2025.3.19., 게재확정일: 2025.3.27.)



이현경

관행, 법의 원천, 법원으로서의 관행, 나쁜 관행, 관행의 법제화, 반성적 관행으로서의 법, 법적 추론, 반성적 추론, 성찰적 법관행주의

162) Ronald Dworkin, "The Model of Rules II", *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, 1978.

163) 앞서 관행에 대한 ‘정적 접근’과 ‘동적 접근’을 구별하고, 후자의 중요성을 강조한 바 있다.

【참 고 문 헌】

I. 단행본

- 권영준, 민법학의 기본원리, 박영사(2020).
- 김대휘, 법철학과 법이론 입문 제2판, 성안당(2023).
- 김영환, 법철학의 근본문제 제3판, 홍문사(2012).
- 김정오·최봉철·김현철·신동룡·양천수, 법철학: 이론과 쟁점 제3판, 박영사(2022).
- 김종철·심우민, 입법의 시간, 박영사(2022).
- 김학태, 법의 해석과 적용, 한국외국어대학교출판부 지식출판원(2017).
- 박영도, 입법학 입문 증보판, 법령정보관리원(2014).
- 박효중, 국가와 권위, 박영사(2004).
- 심현섭, 분석과 비판의 법철학Ⅱ: 법이념·순수법학·법이론, 법문사(2024).
- 오세혁, 법학방법론, 박영사(2024).
- 이상영·김도균, 법철학, 한국방송통신대학교출판문화원(2011).
- 조홍식, 사법통치의 정당성과 한계 제2판, 박영사(2010).
- 최봉철, 현대법철학, 법문사(2007).
- 한국법철학회(김도균 엮음), 한국 법질서와 법해석론, 세창출판사(2013).
- 한국법철학회(이계일 엮음), 법학방법론, 세창출판사(2017).
- 홍완식, 입법학논고, 피앤씨미디어(2021).
- Frank Lovett(조계원 역), 지배와 정의에 관한 일반이론, 박영사(2019).
- Gustav Radbruch(윤재왕 역), 법철학, 박영사(2021).
- Hans Kelsen(윤재왕 역), 순수법학, 박영사(2018).
- Hans Kelsen(김성룡 역), 규범의 일반이론 1, 2, 아카넷(2016).
- Hans Kelsen(윤재왕 역), 순수법학, 박영사(2018).
- Gilbert Harman(김성한 역), 도덕의 본성, 철학과 현실사(2005).
- Iris Marion Young(김도균·조국 역), 차이의 정치와 정의, 모티브북(2017).
- Lon L. Fuller(박은정 역), 법의 도덕성, 서울대학교출판문화원(2015).
- Ronard Dworkin(장영민 역), 법의 제국, 아카넷(2004).

II. 논문

- 공두현, “법적 추론에서의 가치와 개연성”, 저스티스 제173권, 한국법학원(2019).
- 공두현, “판결하기 어려운 사건, 쉬운 사건, 보통의 사건 -법적 추론과 법적 논증의 영역들”, 저스티스 제192호, 한국법학원(2022).
- 김기창, “성문헌법과 ‘관습헌법’”, 공법연구 제33집 제3호, 한국공법학회(2005).
- 김대근, “이유로서의 법”, 법학연구 제35권 제1호, 충남대학교 법학연구소(2024).
- 김대휘, “法源論에 관한 研究”, 박사학위 논문, 서울대학교(1992).
- 김대휘, “비판적 법실증주의 법이론”, 기초법학연구 제3호, 서울대학교 법학연구소 법이론연구센터(2024).
- 김도균, “법원리로서의 공익”, 서울대학교 법학 제47권 제3호, 서울대학교 법학연구소(2006).
- 김도균, “우리 대법원 법해석론의 전환: 로널드 드워킨의 눈으로 읽기-법의 통일성 (Law’s Integrity)을 향하여”, 법철학연구 제13권 제1호, 한국법철학회(2010).
- 김영환, “한국에서의 법학방법론의 문제점-법발견과 법형성”, 법철학연구 제18권 제2호, 한국법철학회(2015).
- 김재형, “이론과 실무의 조응”, 서울대학교 법학 제65권 제2호, 서울대학교 법학연구소(2024).
- 김재형, “입법과 사법의 경계: 법률해석의 한계”, 민사법학 제108권, 한국민사법학회(2024).
- 김학태, “법을 통한 과거청산 -법효력에 관한 법철학적 근거, 외법논집 제18권, 한국외국어대학교 법학연구소(2005).
- 김현철, “비판적 법실증주의를 다시 생각함”, 법철학연구 제27권 제1호, 한국법철학회(2024).
- 김형석, “역사법학과와 19세기초 독일 법전화 논쟁이 오늘날의 사법에 주는 시사점”, 법학논총 제40권 제2호, 한양대학교 법학연구소(2023).
- 문종욱, “법효력론과 ‘5·18’ 현재결정”, 법학연구 제12권 제1호, 충남대학교 법학연구소(2001).
- 박준석, “관행과 법의 지배”, 법철학연구 제16권 제3호, 한국법철학회(2013).
- 박준석, “규범의 본질에 대한 탐구 - 조건문의 형식을 중심으로”, 법철학연구 제22권 제2호, 한국법철학회(2019).
- 변종필, “법의 효력과 근본규범”, 안암법학 제5권, 안암법학회(1997).

- 심헌섭, “법의 효력에 관한 연구”, 서울대학교 법학 제21권 제1호, 서울대학교 법학연구소(1980).
- 심헌섭, “비판적 법실증주의”, 분석과 비판의 법철학, 법문사(2001).
- 안준홍, “나쁜 법은 법이 아닌가”, 법철학연구 제15권 제2호, 한국법철학회(2012).
- 양선숙, “법, 규범성, 그리고 규칙 준수의 동기에 대한 관행론적 이해”, 법철학연구 제15권 제3권, 한국법철학회(2012).
- 양천수, “민주적 법치국가에서 본 법규범의 효력근거 —법철학의 관점에서”, 법과 사회 제38권, 법과사회이론학회(2010).
- 양천수, “법적 안정성과 해석”, 법학논총 제28권 제2호, 국민대학교 법학연구소(2015).
- 양천수, “법률에 반하는 법형성의 정당화 가능성: 이론적·실정법적 근거와 인정범위 그리고 한계”, 법과사회 제52호, 법과사회이론학회(2016).
- 엄순영, “라즈의 원천 테제”, 법철학연구 제18권 제3호, 한국법철학회(2015).
- 오세혁, “우리나라 법학방법론의 전개”, 법철학연구 제11권 제2호, 한국법철학회(2008).
- 오세혁, “법학방법론의 현대적 의미”, 중앙법학 제25권 제3호, 중앙법학회(2023).
- 이계일, “포스트실증주의 법사고와 법효력론”, 법철학연구 제13권 제2호, 한국법철학회(2010).
- 이계일, “법관법 변경의 효력범위설정에 대한 비판적 탐구”, 법철학연구 제24권 제1호, 한국법철학회(2021).
- 이계일, “법관의 법형성의 체계구성에 관한 탐구”, 법과사회 제59권, 법과사회이론학회(2017).
- 이계일, “20세기 전반기 법학방법론에 있어 흄결이론의 전개 양상에 대한 탐구”, 법철학연구 제26권 제2호, 한국법철학회(2023).
- 이계정, “법관에 의한 법형성의 실제, 한계와 입법적 사항의 문제-호적정정 결정과 특별한정승인 판결의 재음미”, 저스티스 제205호, 한국법학원(2024).
- 이동희, “법의 효력”, 법학논총 제24권, 단국대학교 법학연구소(2000).
- 이민열, “법해석에 있어서 정치철학의 투입점—진지한 법준수 의무와 규범의 충위”, 법철학연구 제26권 제1호, 한국법철학회(2023).
- 이재승, “법효력의 계속과 차단”, 법철학연구 제6권 제1호, 한국법철학회(2003).
- 이재승, “긴급조치 제9호를 적용한 법관의 책임: 대법원 2022.8.30. 2018다212610 전원합의체 판결”, 민주법학 제81권, 민주주의법학연구회(2023).

- 이현경, “법학적 관행 이론 소묘(素描) - 관행규범성에 대한 다각적 고찰을 중심으로”, 법철학연구 제20권 제3호, 한국법철학회(2017).
- 이현경, “규범으로서의 관행: 분류적 차원의 고찰”, 법학논총 제34권 제3호, 한양대학교 법학연구소(2017).
- 이현경, “제도적 사실로서의 법 - 그 철학적 기초와 법이론적 함의”, 홍익법학 제18권 제2호, 홍익대학교 법학연구소(2017).
- 이현경, “제도적 사실로부터 제도적 규범질서로: 맥코믹의 제도적 법개념 발전과정과 변천에 관한 고찰”, 법학논총 제30권 제2호, 국민대학교 법학연구소(2017).
- 이현경, “조정 관행의 개념적 구조와 요소-관행 개념 재구성과 대안 이론을 위한 분석적 기초”, 법철학연구 제20권 제1호, 한국법철학회(2017).
- 이현경, “법철학에서 관습이 왜 중요한가? 관습의 본질과 법규성에 대한 새로운 이해”, 법철학연구 제24권 제2호, 한국법철학회(2021).
- 이현경, “관습법 회의론에 대한 비판적 고찰 및 관습법의 현대적 변용 - 관습법철학 I”, 연세법학 제42권, 연세법학회(2023).
- 이현경, “법원(法源)-법규범의 구별'과 메타-법철학”, 법철학연구 제27권 제1호, 한국법철학회(2024).
- 이현경, 철학적 기초와 법관계주의”, 법철학연구 제27권 제2호, 한국법철학회(2024).
- 임미원, “법관의 범형성에 관한 일고찰 -<구 조세감면규제법> 한정위헌 결정과 관련하여”, 공법연구 제41권 제1호, 한국공법학회(2012).
- 임미원, “대법원의 유체인도 판결의 법철학적 고찰”, 법조 제62권 제8호, 법조협회(2013).
- 임미원, “탈관습적 시대의 규범적 논거들의 계보”, 한양법학 제24권 제1호, 한양법학회(2013).
- 임미원, “근대 법전편찬의 사상적 기초 -자연법학, 역사법학, 헤겔의 견해와 관련하여”, 법학논총 제40권 제1호, 한양대학교 법학연구소(2023).
- 조동은, “미국 연방대법원의 위헌 판단 회피 원칙과 그 한국적 시사점”, 서울법학 제26권 제3호, 서울시립대학교 법학연구소(2018).
- 조홍식, “勿輕視政治 - 比例立憲主義를 主唱하며”, 서울대학교 법학 제49권 제3호, 서울대학교 법학연구소(2008).
- 조홍식, “칸트의 규범적 법실증주의-하트의 관점에서 시도하는 칸트 텍스트의 분석”, 서울대학교 법학 제63권 제4호, 서울대학교 법학연구소(2022).
- 최병조, “第1條(法源)”, 민법주해 1: 총칙(1) 제2판(양창수 편저), 박영사(2022).

- 최봉철, “폴러의 합법성론”, 법철학연구 제7권 제2호, 한국법철학회(2004).
- 최봉철, “법의 효력: 요건과 효과를 중심으로”, 법철학연구 제17권 제3호, 한국법철학회(2014).
- 최봉철, “사악한 법의 효력”, 성균관법학 제32권 제4호, 성균관대학교 법학연구원(2020).
- 최봉철, “악법과 법준수의무에 대한 소크라테스의 입장”, 법철학연구 제16권 제3호, 한국법철학회(2013).
- 최준규, “상가건물임대차보호법 상 권리금 회수기회 보호규정 비판 - 입법론의 관점에서”, 민사법학 제96권, 한국민사법학회(2021).
- 최준규, “상가건물임대차보호법상 권리금회수기회 보호규정의 문제점: 입법론의 관점에서”, 법경제학연구제20권 제1호, 한국법경제학회(2023).
- 하재홍, “소크라테스와 정의롭지 않은 법률의 준수 문제”, 법학연구 제63권 제4호, 부산대학교 법학연구소(2022).
- 한상훈, “가추법은 독자적 법적 추론방법인가”, 저스티스 제181권, 한국법학원(2020).

III. 외국 문헌

- Adam Dyrda, “Reflective Legal Positivism”, ARCHIWUM FILOZOFII PRAWA I FILOZOFII SPOŁECZNEJ, 2022.
- Aharon Barak, Purposive Interpretation in Law, Princeton University Press, 2005.
- Aleksander Peczenik, On Law and Reason, Springer, 2008.
- Alf Ross, On Law and Justice, Jakob v. H. Holtermann (ed.), Oxford University Press, 2019.
- Amanda Perreau-Saussine, James B. Murphy (Eds.), The Nature of Customary Law, Cambridge University Press, 2007.
- Andrei Marmor, “On Convention”, Synthese Vol. 107, No. 3, 1996.
- Andrei Marmor, Positive Law and Objective Values, Oxford University Press, 2001.
- Andrei Marmor, Social Conventions, Princeton University Press, 2009.
- Andrei Marmor, Foundations of Institutional Reality, Oxford University Press, 2022.

- Antonin Scalia, *A Matter of Interpretation: Federal Courts and the Law*, Princeton University Press, 1997.
- David J. Bederman, *Custom as a Source of Law*, Cambridge University Press(2010).
- David Lewis, *Convention*, Blackwell Publishing, 1969.
- David Owens, *Bound by Convention*, Oxford University Press, 2022.
- Dimitrios Kyritsis, *Shared Authority*, Hart Publishing, 2015.
- Fábio Perin Shecaira, “Sources of Law Are not Legal Norms”, *Ratio Juris*, 2015.
- Fábio Perin Shecaira, *Legal Scholarship as a Source of Law*, 2nd edition, Springer, 2024.
- Federico José Arena, “Conventionalism”, in *Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy*, Mortimer Sellers & Stephan Kirste(eds.), Springer, 2023.
- Frank H. Easterbrook, “Text, History, and Structure in Statutory Interpretation”, *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 1994.
- Frederick Schauer, “On the Relationship between Law and Legal Reasoning”, *New Essays on the Nature of Legal Reasoning*, Mark McBride · James Penner · George Pavlakos (Eds.), Hart Publishing, 2022.
- Giorgio Pino, “Sources of Law”, in *Oxford Studies in Philosophy of Law Volume 4.*, John Gardner · Leslie Green · Brian Leiter (eds.), Oxford University Press, 2021.
- Gerald J. Postema, “Coordination and Convention at the Foundations of Law”, *The Journal of Legal Studies*, 1982.
- Gerald J. Postema, “Conventions at the Foundation of Law,” in *The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law*, Peter Newman (Ed.), 1998.
- H.L.A. Hart, *The Concept of Law* 3rd edition,, Oxford University Press, 2012.
- James Bernard Murphy, *The Philosophy of Customary Law*, Oxford

- University Press, 2014.
- Jeremy Waldron, “The Rule of Law”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016.
- Jeremy Waldron(송성국 역), “규범적 (또는 윤리적) 실증주의”, 법철학연구 제20권 제3호, 한국법철학회(2017).
- John Gardner, “Concerning Permissive Sources and Gaps”, Oxford Journal of Legal Studies 8, 1988.
- Joseph Raz, “Authority, Law and Morality”, The Monist, 1985.
- Joseph Raz, The Concept of Legal System 2nd edition, Clarendon Press, 2003.
- Joseph Raz(권경휘 역), “권위, 법 그리고 도덕”, 법철학연구 제12권 제1호, 한국법철학회(2009).
- Jules L. Coleman, The Practice of Principle, Oxford University Press, 2001.
- Jules L. Coleman, “The Conventionality Thesis”, Philosophical Issues, 2001.
- Kaarlo Tuori, Critical legal positivism, Routledge, 2016.
- Karl Larenz(김영환 역), “방법론적인 문제로서 법관의 법형성”, 법학논총 제25집 제1호, 한양대학교 법학연구소(2008).
- Larry Alexander, “Originalism, the Why and the What”, Fordham Law Review, 2013.
- Leslie Green, “Positivism and Conventionalism”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence Vol. XII, No. 1, 1999.
- Leslie Green, The Authority of the State, Oxford University Press, 1999.
- Leslie Green, “Law and the Causes of Judicial Decisions”, University of Oxford Legal Research Paper Series 14.
- Marco Goldoni, “Multilayered Legal Conventionalism and the Normativity of Law,” in New Essays on the Normativity of Law, Hart Publishing, 2011.
- Mathieu Carpentier, “Sources and Validity”, in Legal Validity and Soft Law, Pauline Westerman · Jaap Hage · Stephan Kirste · Anne Ruth Mackor (eds.), Springer, 2018.
- Mathieu Carpentier and Torben Spaak, “Sources of Law”, in Jurisprudence in the Mirror, Kenneth Einar Himma, Giorgio Pino, Luka Burazin (eds.), Oxford University Press, 2024.
- Mark Greenberg, “Legal Interpretation”, Stanford Encyclopedia of

- Philosophy, 2021.(<https://plato.stanford.edu/entries/legal-interpretation/>)
- Mark McBride · James Penner · George Pavlakos(Eds.), *New Essays on the Nature of Legal Reasoning*, Hart Publishing, 2022.
- Michael Rescorla, “Convention”, substantive revision, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2024.(<https://plato.stanford.edu/entries/convention/>)
- Neil MacCormick, *Institutions of Law*, Oxford University Press, 2007.
- Nicholas Southwood, “Laws as Conventional Norms”, in *Dimensions of Normativity*, David Plunkett · Scott J. Shapiro · Kevin Toh (eds.), Oxford University Press, 2019.
- Raimo Siltala, “Legal Conventionalism: Law as an Express of Collective Intentionality”, *Law, Truth, and Reason*, Springer, 2011.
- Ronard Dworkin, “The Model of Rules II”, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, 1978.
- Lorena Ramírez-Ludeña · Josep M. Vilajosana (eds.), *Legal Conventionalism*, Springer, 2019.
- Pascale Deumier(박수곤 역), “법원(法源)으로서의 관행”, *저스티스 제139호*, 한국법학원(2013).
- Roger Shiner, *Legal Institutions and the Sources of Law*, Springer, 2005.
- William N. Eskridge, Jr., *Dynamic Statutory Interpretation*, Harvard University Press, 1994.
- William N. Eskridge Philip P. Frickey, “Statutory Interpretation as Practical Reasoning”, *Stanford Law Review*, 1990.
- Yemima Ben-Menahem, *Conventionalism*, Cambridge University Press, 2006.

IV. 기타

- 대법원 1998. 4. 23. 선고 95다36466 전원합의체판결.
- 대법원 1999. 11. 12. 선고 98다25979 판결.
- 서울남부지방법원 2023. 1. 19. 선고 2022노528, 2022노553(병합) 판결.
- 대법원 2023. 12. 7. 선고 2023도2318 판결.

헌법재판소 2025헌라1 결정.

Lawrence Solum 법이론 블로그; (<https://lsolum.typepad.com/legaltheory/2022/03/pino-on-sources-of-law.html>)

언론 기사: “관행과 범죄 사이: 관행에 관대한 당신께 묻는다”, 2016.6.3.;
(<https://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=10100>)

언론 기사: “[漢字, 세상을 말하다] 관행(慣行)”, 2018.04.21.;
(<https://www.joongang.co.kr/article/22555977>)

언론 기사: 전형배, “법인 택시업계의 오래된 숙제”, 2024.8.21.;
(<https://www.kado.net/news/articleView.html?idxno=1261331>)

이현경, “권리금 분쟁의 법리적 속성과 해결 원칙: 관행이론의 적용과 ‘2선 당사자론’”, 상가임대차 분쟁의 효과적 해결방향, 국회정책토론회 (2018.12.11.)

Abstract

The Normative Status and Validity of Conventions in Multidimensional Legal Reasoning

Lee, HyunKyung

This article discusses the normative status and validity of conventions in multidimensional legal reasoning, and proposes key theses that have implications for two areas of legal philosophy: the nature of law and legal reasoning. As two theoretical resources for this endeavor, I will address 'source of law' and 'legal convention theory' respectively, and methodologically, I will argue through a combination of the two. Finally, as detailed thematic propositions that embody these goals, I propose (1) 'convention as a source of law' [Thesis 1] and 'law as reflective convention' [Thesis 2] as dimensions of legal conceptualization; (2) 'reflective reasoning' as a model of legal reasoning; and (3) 'reflective legal conventionalism' [Thesis 3] as a model of legal theory that integrates both dimensions.

To this end, Chapter 1 poses the provocative question "Is convention closer than law?" in order to call for greater attention to and interrogation of the interrelationship between law and convention in various areas of legal practice. Chapter 2 discusses the concepts and nature of 'source' and 'convention', two fundamental concepts central to the first thesis of this article, 'convention as a source of law'. Building on this, Chapter 3 discusses the role and validity of conventions in multidimensional legal reasoning. First, it highlights the multidimensionality of legal reasoning and argues that it should be extended beyond the existing 'monism of judicial reasoning' to 'multidimensional legal reasoning'. Second, it proposes the 'principle of respect for conventions' and the 'presumptive validity thesis' in relation to the

normative power and effectiveness of conventions, and then examines the problem of so-called 'bad conventions', arguing that they require special consideration and theorisation. Third, it categorises sources into three types according to different degrees of normative power (①mandatory sources; 'must sources', ②defeasible sources; 'should sources', and ③'permissive sources'; 'may sources') and then assigns normative conventions to each type. It then points out the significance and limitations of the 'source of law' trichotomy. Fourth, it addresses the issue of normative conflict as a deepening of 'convention as source of law' [thesis 1]. In doing so, it highlights the limitations of traditional legal methodological solutions to the problem of normative control of 'bad convention' by discussing conflicts between convention and statutory law. Building on these discussions, Chapter 4 applies and analyses the theory to specific cases and examines the implications and practicality of the main theses of this research. Divided into the areas of legislative and judicial reasoning, representative cases from each area are selected, analysed and commented upon. The issues of 'codification of convention' and 'bad convention' are addressed, highlighting the importance of interaction and cooperation between the different dimensions of legal reasoning. Finally, Chapter 5 concludes by reiterating the issues raised in the introduction and proposing a conceptualisation of law as reflective convention, a model of legal reasoning called 'reflective reasoning', and 'reflective legal conventionalism'.



► Lee, HyunKyung

Convention, Sources of Law, Convention as Source of Law, Bad Convention, Codification of Convention, Law as Reflective Convention, Reflective Reasoning, Reflective Conventionalism